



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
قسم الفقه المقارن

الشهادة والقضاء والتحكيم والذبائح والصيد دراسة فقهية مقارنة

الفرقة الرابعة
شعبة الشريعة الإسلامية، والقانون

تأليف/

أ. د/ سعد الدين مسعد هلالى

أ. د/ مراد محمود حيدر

٢٠٢٥ هـ - ١٤٤٦

أولاً:

الشهادة والقضاء والتحكيم

تأليف/

الأستاذ الدكتور/ سعد الدين مسعد هلالي

أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بالكلية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

مقدمة مباحث الشهادة والقضاء والتحكيم:

العدل اسم من أسماء الله، وصفة من صفاته سبحانه، وهو شرع الله في خلقه، أمر به في مواطن كثيرة منها قوله جل شأنه: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (النحل: ٩٠).

كما أمر القرآن الكريم رسولنا العظيم أن يعلن ما أمره الله به من إقامة العدل بين الناس فقال: "فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ" (الشورى: ١٥).

وأمر القرآن الكريم عموم المؤمنين إلى قيام الساعة بأداء الأمانات واتخاذ العدل أساساً في أحكامهم بين الناس، فقال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" (النساء: ٥٨).

وأخبرنا القرآن الكريم أن جميع الرِّسَالَاتِ السماوية السابقة كانت داعية لإقامة العدل بين الناس، فقال سبحانه: "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ" (الحديد: ٢٥).

ونهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن تأخذهم الحمية أو تمتلئ قلوبهم عداوة، وإن حدث لسبب أو آخر فلا يمنع ذلك من تحقيق العدل الذي

يتجاوز العداوات، فقال تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" (المائدة: ٩).

وكما بيّن القرآن الكريم منزلة وفضل العدل، وأنه أساس الحكم بين الناس،
فإن الأحاديث النبوية الشريفة قد بيّنت ذلك أيضًا، فأخرج البخاري عن
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلمهم الله في ظله
يوم لا ظل إلا ظله"، وذكر أولهم: "إمام عادل"، وأخرج مسلم عن عبد الله
بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المقسطين
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم
وأهلهم وما ولّوا".

وقد أنزل الله تعالى للإنسانية كتابه الكريم، كما قال سبحانه: "هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان" (البقرة: ١٨٥)؛ ليعين الإنسان، مع سُنّة النبي
صلى الله عليه وسلم، في كلّ عصر ومصر أن يضع أنظمتة الحضارية،
ومن أعظمها قيمة نظامه القضائي الأكثر أهميّة لإقامة العدل بين الناس،
ومن ذلك اختيار القضاة وتعيينهم، ورسم طرق رفع الدعوى، وسبيل
الفصل فيها على وجه يحقق العدالة، وورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما
أخرجه أصحاب السُنن الأربعة وصححه الحاكم عن بريدة بن الحصيب،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد
في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق
فلم يقض به وجاز في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى
للناس على جهل فهو في النار"، وأخرج البيهقي عن ابن عباس، أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي واليمين على من
أنكر"، ومن هنا كانت الشهادة أو البينة مقترنة لأحكام القضاء.

والقضاء وحده قد لا يسعف المجتمع في فض خصوماته، ومن ثمَّ فقد أتاحت النصوص الشرعية للمتخاصمين الالتجاء إلى التحكيم، وبخاصة في المنازعات الأسرية، والدولية، وعموم المنازعات؛ فقال سبحانه: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا" (النساء: ٣٥)، وقال تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" (الحجرات: ٩)، وقال تعالى: "والصلح خير" (النساء: ١٢٨).

وقد حظيت مسائل الشهادة والقضاء والتحكيم باهتمام الفقهاء الأوائل باختلاف مذاهبهم، وأفرد الكثير من الباحثين المعاصرين تلك المسائل بمصنفات خاصة؛ لما لها من أهمية وخطورة تتجدد بتجدد الأيام.

ونحن نسير على الدرب الذي سار عليه المخلصون في عرض أبواب الفقه عرضاً منهجياً مقارناً في أحكام الشهادة والقضاء والتحكيم يعتمد على إبراز مسائلها، وتحرير محل النزاع في كل مسألة ما أمكن، وبيان أقوال الفقهاء وأدللتهم؛ لتمكين القارئ الكريم، والباحث الأمين من ترجيح ما اطمئن إليه قلبه من رأي فقهي يرى مقام دينه فيه، ويرجو لقاء الله عليه دون إضرار بأحد؛ لعموم قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" (البقرة: ٢٨٢)، وعموم ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار"، ودون وصاية من أحد؛ لعموم قوله تعالى: "يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون" (النحل: ١١١)، وأخرج أحمد عن وابصة بن معبد، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال له: "يا وابصة، استفت قلبك واستفت نفسك - ثلاث مرات - البر ما اطمأنت

إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك"، وأخرج نحوه عن أبي ثعلبة الخشني، وفيه: "وإن أفتاك المفتون".
وليعلم كلُّ أحد اختار رأيًا فقهيًا أن اختياره لنفسه، وليس على غيره الذي له نفس الحق، حتى لايفتن أحد على أحد، ولا يزايد أحد على أحد في دين الله. وعلى مَنْ اختار رأيًا فقهيًا أن يُظهر أسباب اختياره له، من حيث قوة الدليل وظهوره، وعدم معارضته لاختيار وليّ الأمر؛ لأنه من أهل الاجتهاد، وعملاً بالقاعد الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، ورعاية للمصلحة المرسلة التي جاء بها الهدي القرآني والنَّبوي، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وينقسم حديثنا عن الشَّهادة والقضاء والتحكيم في دراستنا الفقهية المقارنة إلى ثلاثة مباحث، كما يلي:

المبحث الأول: التعريف بالشهادة، وبيان بعض أحكامها الفقهية المقارنة

المبحث الثاني: التعريف بالقضاء، وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة

المبحث الثالث: التعريف بالتحكيم، وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة

والله ولي التوفيق

المؤلف أ. د/ سعد الدين مسعد هلال

المبحث الأول

التعريف بالشهادة وبيان بعض أحكامها الفقهية المقارنة

يشتمل هذا المبحث على التعريف بالشهادة، وبيان بعض أحكامها الفقهية المقارنة من خلال المسائل الخمس الآتية:

المسألة الأولى

التعريف بالشهادة وسببها ومشروعيتها وطبيعتها

نتكلم عن التعريف بالشهادة، وحكمة تسميتها، وبيان مشروعيتها، وسببها، وطبيعتها، في العناصر الخمسة الآتية:

أولاً: تعريف الشهادة

الشهادة في اللغة تطلق على الخبر القاطع، أو الحضور، أو المعاينة، أو العلانية، أو القسم، أو نحوها.

والشهادة في اصطلاح الفقهاء محل اختلاف بحسب اختلافهم في ضوابطها، على الوجه الآتي:

(١) عند الحنفية: الشهادة هي الإخبار الصادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.

(٢) عند المالكية: الشهادة هي إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه.

(٣) عند الشافعية: الشهادة هي إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.

(٤) عند الحنابلة: الشهادة هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.

ويلاحظ من خلال التأمل في تعريفات الفقهاء المختلفة للشهادة ما يلي:

(١) عند الحنفية والمالكية: يجب أن تكون الشهادة عند حاكم أو قاضي.

(٢) عند الحنفية والشافعية والحنابلة: يجب أن تكون الشهادة بلفظ أشهد أو شهدت.

(٣) اتفق الفقهاء على أن الشهادة: إخبار بحق للغير على الغير.

ثانيًا: حكمة التسمية بالشهادة

سميت الشهادة بهذا الاسم؛ لأنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة. وتسمى أيضًا بالبينّة؛ لأن الحقوق تبين بها.

أخرج الحاكم وصححه، كما أخرجه البيهقي وضعف أحد رواته عن ابن عباس قال: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: "يا ابن عباس لاتشهد إلا على ما يضيء كضياء الشمس. وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس".

وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان" وابن عدي في "الكامل" بإسناد ضعيف. قال ابن حجر في "بلوغ المرام من أدلة الأحكام": وصححه الحاكم فأخطأ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: سأله عن الشهادة: "ترى الشمس"؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: "على مثلها فاشهد، أو دَع".

ثالثًا: مشروعية الشهادة

يدل على مشروعية الشهادة الكتاب والسنة والمعقول، كما يلي:

(١) دليل الكتاب: منه قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" (البقرة: ٢٨٢)، وقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق: ٢).

(٢) دليل السنة: أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الشيخان عن الأشعث بن قيس قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاخترنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "شاهداك أو يمينه". قلت: إذا يحلف ولا يبالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صبر يقطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". وفي رواية عند البخاري: "من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديق ذلك هذه الآية: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" (آل عمران: ٧٧) وليس للأشعث بن قيس.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على الطرف الأضعف مركزاً في الدعوى؛ فأخرج الشيخان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

وأخرج الترمذي بسند فيه مقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه - محمد - عن جده - هوعبد الله بن عمرو بن العاص - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في خطبته: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

(٣) دلائل المعقول: لا يختلف عاقل على أن الحاجة داعية إلى العمل بالشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس في الجملة، فوجب الرجوع إليها؛ لإثبات الحقوق.

رابعًا: سبب الشهادة

يرجع سبب الشهادة إلى أمرين:

الأمر الأول: طلب المدعي؛ لعموم قوله تعالى: "ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" (البقرة: ٢٨٢).

الأمر الثاني: خوف فوت الحق حسبة؛ لعموم قوله تعالى: "كونوا قوامين بالقسط شهداء لله" (النساء: ١٣٥)، وعموم قوله تعالى: "كونوا قوامين لله شهداء بالقسط" (المائدة: ٨)، وعموم قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" (الطلاق: ٢).

خامسًا: طبيعة الشهادة

الأصل في الشهادة أنها تقوم على الصدق والأمانة، سواء في مواجهة مسلم أو غيره، أو في مواجهة قريب أو غيره. قال تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" (الطلاق: ٢)، وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر؟ فقال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".

وأخرج الشيخان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" - ثلاثًا - قالوا: بلى. قال: "الإشراك بالله، وعقوق

الوالدين"، وجلس، وكان متكئاً فقال: "ألا وقول الزور"، وفي رواية: "ألا وشهادة الزور"، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

وبناء على ذلك، فإن الشاهد في شهادته لا يعرف إلا الله، ولا يضع في حسابه مجاملة لأحد، أو انتقاماً من أحد، لا أباً ولا أمّاً ولا أخاً ولا زوجة، ولا حتى النفس في مجاملتها أو الانتقام لها من عدو أو خصم. قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً" (النساء: ١٣٥).

وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" (المائدة: ٨).

المسألة الثانية

حكم الشهادة التكليفية تحملاً وأداءً

الشهادة لها مرحلتان: تحمل وأداء. أما التحمل فهو التحصيل، وأما الأداء فهو البذل، ولكل حكمه كما يلي:

أولاً: تحمل الشهادة في الحقوق وفي الحدود

يختلف حكم تحمل الشهادة بحسب نوع المشهود عليه، هل هو حق أو هو حد؟

والمقصود بالحقوق: ما تتعلق به مصلحة آدمي كالنكاح والإقرار، وسائر عقود المعاملات، والقصاص، وموجبات التعزير.

والمقصود بالحدود: ما تتعلق به مصلحة دينية، أو ما يتعلق بحق الله سبحانه دون الرجوع إلى مصلحة معينة للآدميين مثل حد الزنا.

ونبين حكم تحمل الشهادة في الحقوق وفي الحدود، فيما يلي:

حكم تحمل الشهادة في الحقوق الآدمية:

يختلف حكم تحمل الشهادة في الحقوق الآدمية باختلاف حكم الإشهاد، هل هو واجب أم جائز؟

فإن قلنا إن الإشهاد واجب فيكون تحمل الشهادة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقيين. وإذا لم يوجد إلا نصاب الشهادة - في حال حدوث الحق - كان تحملها واجباً عينياً إلا عند الضرر؛ لعموم قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" (البقرة: ٢٨٢).

وإن قلنا إن الإشهاد جائز وليس واجباً فيكون تحمل الشهادة جائزاً أو سنة على الكفاية في ذاته إلا إذا انضم إليه ما يوجبه كالخوف من ضياع الحق.

ويختلف حكم الإشهاد في حقوق الآدميين باختلاف نوع العقد، بالتفصيل الآتي:

عقد الزواج:

يرى أكثر أهل العلم: وجوب الإشهاد في عقد الزواج؛ لحديث الطبراني عن عائشة وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين، وأخرجه الدار قطني عن عائشة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وأخرجه البيهقي عن عائشة وعلي وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

ويرى الإمام مالك: أن الإشهاد في عقد الزواج ليس واجباً إذا تم إعلانه، فإذا لم يكن الإعلان وجب الإشهاد عند الدخول.

ويرى الإمامية: أن الإشهاد في عقد الزواج ليس واجباً مطلقاً. يقول الهذلي ت ٦٧٦ هـ في "شرائع الإسلام في الفقه الجعفري": "لا يشترط في شيء من الأنكحة حضور شاهدين، ولو أوقعه الزوجان سرّاً جاز، ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل".

عقد الطلاق والرجعة:

يرى أكثر أهل العلم: أن الإشهاد في عقد الطلاق أو الرجعة سنة.

ويرى بعض المالكية والإمام الشافعي: أن الإشهاد في عقد الطلاق أو الرجعة واجب، ولكنهما يصحان بدونه؛ لعموم قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق: ١-٢).

ويرى بعض الشافعية ومذهب الإمامية: أن الإشهاد في الطلاق واجب ولا يصح بدونه.

(ج) عقود البيع والمداينات:

يرى أكثر أهل العلم: أن الإشهاد في عقود البيع والمداينات مستحب؛ لقوله تعالى: "فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أؤتمن أمانته" (البقرة: ٢٨٣).

ويرى الظاهرية، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد بن جبر: أن الإشهاد في عقود البيع والمداينات واجب؛ لظاهر الأمر به في قوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" إلى أن قال سبحانه: "ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" إلى أن قال سبحانه: "وأشهدوا إذا تباعتم" (البقرة: ٢٨٢).

حكم تحمل الشهادة في حقوق الله "الحدود":

تحمل الشهادة في حقوق الله تعالى ليس واجبًا في ذاته بالإجماع؛ للدعوة إلى الستر وغض البصر. وإنما هو جائز أو مستحب بحسب النية فيه؛ لعموم قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" (النور: ٤)، وقوله تعالى: "لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" (النور: ١٣)، وقوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن

شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً" (النساء: ١٥).

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه. ومَن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومَن فرَّج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومَن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة"، كما أخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نَفَس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومَن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

ثانيًا: أداء الشهادة في الحقوق وفي الحدود

يختلف حكم أداء الشهادة في الحقوق وفي الحدود، ونبين ذلك فيما يلي:

حكم أداء الشهادة في الحقوق الآدمية:

أجمع الفقهاء على أن أداء الشهادة في الحقوق الآدمية فرض كفاية في حكم الأصل، بحيث إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقيين، وإذا امتنع الجميع أثموا.

وإذا تعينت الشهادة على عدد بلغ نصابها كرجلين صارت فرض عين عليهما.

ويدل لذلك: عموم قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" (الطلاق: ٢)، وقوله تعالى: "ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا" (البقرة: ٢٨٢)، وقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" (البقرة: ٢٨٢).

وهل يشترط لأداء الشهادة في حقوق الأدميين المطالبة بها؟

إذا كانت الحقوق في الديون والديات فلا يجوز التقدم بالشهادة قبل طلبها؛ لإمكان التسامح والتكريم بين الناس.

أما إذا كانت الحقوق في الديانات العامة أو الجامعة كالطلاق والرجعة والرضاع فيجب بذلها حسبة؛ لما أخرجه مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة"، قالوا: لمن؟ قال: "الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

حكم أداء الشهادة في الحدود أو حقوق الله:

اختلف الفقهاء في حكم أداء الشهادة في الحدود أو حقوق الله تعالى الخالصة أو الغالبة مثل الزنى والسرقه، وذلك على ثلاثة مذاهب للفقهاء في الجملة:

المذهب الأول: يرى أن الشاهد مخير بين أداء الشهادة في الحدود أو حقوق الله الخالصة أو الغالبة وبين عدم أدائها، والترك أولى. وهو قول الحنفية والمالكية.

وحجتهم: أنه قد تعارض حسبتان أو مقصدان شرعيان: حسبة الشهادة لله، وحسبة الستر، وكلاهما مندوب إليه؛ كما قال تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" (الطلاق: ٢)، وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: "مَنْ ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة"، وأخرج مالك والنسائي والطبراني عن هزّال الأسلمي، أنه قال لماعز بن مالك: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بحديثك، فأتاه فأخبره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مراراً، فجعل يردد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: "أبه جنون؟" قالوا: لا، قال: "أبكر أم ثيب؟" قالوا: بل ثيب. فأمر به فرجم، قال: "ويحك يا هزّال، لو سترته بردائك كان خيراً لك".

المذهب الثاني: يرى أنه يحرم أداء الشهادة في الحدود في حكم الأصل. ذكره المواق في "التاج والإكليل" عن بعض المالكية.

وحجتهم: أن الشرع أمر المسلم بالستر على نفسه وعلى غيره، فيكون الأداء ممنوعاً. قال تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" (النور: ١٩).

وأخرج مالك والحاكم - بسند فيه مقال - عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجُلد، ثم قال: "أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، مَنْ أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه مَنْ يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله"، وأخرج مالك في "الموطأ" من مراسيل زيد بن أسلم، كما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألمَّ بها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل"، وأخرج

مالك والنسائي والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له "هزّال"، كان قد أمر "ماعز بن مالك" أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بفعلته، فلما أقام عليه الحد، قال: "ويحك يا هزّال، لو سترته بردائك كان خيراً لك".

المذهب الثالث: يرى أن أداء الشهادة في الحدود وفي حقوق الله تعالى يرجع إلى تقدير الشاهد واعتقاده بتوبة المخطيء أو عدم توبته. فإن رأى توبته لم يرفع شهادته، وإلا وجب عليه رفعها. وهو مذهب الحنابلة.

وحيثهم: الجمع بين مقصد الستر وبين مقصد الأمن من إشاعة الفاحشة.

المسألة الثالثة

شروط تحمل الشهادة

يشترط في تحمل الشهادة عدة شروط تفيد علم الشاهد وإحاطته بحمل الشهادة بما يقنع القائمين على العدالة، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:

- (١) العقل بالإجماع؛ لاستحالة تحمل المجنون ونحوه شيئاً من العلم.
- (٢) البصر، عند الحنفية. ويرى الجمهور: جواز شهادة الأعمى فيما يجري فيه التسامع، كالنسب والوفاة والزواج.

(٣) العلم بمحل الشهادة بالإجماع؛ لأن العلم هو مناط الشهادة، فقد أخرج الحاكم وصححه، والبيهقي وضعف أحد رواته، عن ابن عباس قال: ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: "يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء الشمس" وأوماً رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس. وأخرج الحاكم وصححه، وتعبه الذهبي وقال: "بل هو حديث وإ"، كما أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، وابن عدي في "الكامل" بإسناد ضعيف، عن ابن عباس أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة؟ فقال: "هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دَع".

(٤) لا يشترط في تحمل الشهادة شروط البلوغ والعدالة والإسلام، في الجملة؛ لأن تحمل الشهادة لا يعدو أن يكون معرفة أو علماً بأمر حدث.

المسألة الرابعة شروط أداء الشهادة

يشترط في أداء الشهادة عدة شروط تحقق مقصودها من العمل بموجبها، وتتنوع هذه الشروط إلى أربعة أقسام بحسب مرجعها، كما يلي:

(١) شروط ترجع إلى الشهادة

(٢) شروط ترجع إلى المشهود عليه

(٣) شروط ترجع إلى الشاهد

(٤) شروط ترجع إلى النصاب أو العدد في الشهادة

ونبين ذلك بشيء من التفصيل فيما يلي:

أولاً: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى الشهادة نفسها

يشترط في الشهادة عند أدائها ما يلي:

(١) اتفاق الشاهدين على محل الشهادة بالإجماع؛ ليتحقق مقصود الشهادة.

(٢) أن تؤدي الشهادة بلفظ أشهد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية؛ لأنه المتبادر إلى الذهن بالأمر بالشهادة.

والأظهر عند المالكية: أنه يكفي ما يدل على حصول علم الشاهد؛ لأنه المقصود، كقوله: رأيت أو سمعت، ولا يشترط أن يقول: أشهد.

ثانيًا: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى المشهود به

يشترط في المشهود به ما يلي:

(١) أن يكون المشهود به معلومًا، فالشهادة بمجهول لا تقبل بالإجماع؛ لأن شرط صحة قضاء القاضي أن يكون المشهود به معلومًا ليتحقق مقصود القضاء.

(٢) أن يكون المشهود به متقومًا شرعًا، سواء أكان مالا أم منفعه بالإجماع؛ لأن القضاء بغير المتقوم عبث.

ثالثًا: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى الشاهد (أهلية الشاهد)

يشترط في الشاهد عند أداء شهادته عشرة شروط، بالتفصيل الفقهي الآتي:

العقل في الشاهد

يشترط في الشاهد أن يكون عاقلًا بالإجماع؛ لعجز المجنون ونحوه عن أداء الشهادة.

بلوغ الشاهد سنّ التكليف

يرى جمهور الفقهاء: اشتراط بلوغ الشاهد سنّ التكليف، فلا تقبل شهادة الأطفال والصبيان؛ لعموم قوله تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" (البقرة: ٢٨٢)، وما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه عن عائشة، كما روي عن علي، وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستقيظ،

وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". ولأن شهادة غير البالغ قد لا تلقى قبولاً لفض الخصومات.

ويرى المالكية والحنابلة في رواية، وهو قول عبد الله بن الزبير: جواز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وذلك على وجه الاستثناء احتياطاً للدماء.

حرية الشاهد

انتهى زمن الرق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر سنة ١٩٤٨م الذي صادقت عليه دول بلاد المسلمين، ولأن التاريخ الفقهي لا يسقط بالتقادم، فمن حق الدارسين معرفة آراء الفقهاء في اشتراط الحرية للشاهد.

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية: اشتراط الحرية في الشاهد، فلا تقبل عندهم شهادة المملوك وإن كان عدلاً؛ لأنهم يرون الشهادة ولاية، وهو ليس أهلاً لتلك الولاية، ولأن المملوك مشغول بخدمة سيده، فلا يتفرغ لأداء الشهادة.

ويرى الحنابلة والظاهرية: عدم اشتراط الحرية في الشاهد، فتصح عندهم شهادة المملوك؛ لأنه مكلف كالحر، ولأن شرط العدالة يجب شرط الحرية. واستثنى الحنابلة الحدود والقصاص فلم يجيزوا شهادة المملوك فيها؛ لقيامها على الدرء بالشبهة.

إبصار الشاهد: يشترط الحنفية والشافعية في الشاهد أن يكون مبصراً، فلا تقبل شهادة الأعمى عندهم؛ لعدم تحقق اليقين فيما يشهد به. واستثنى

الشافعية وزفر من الحنفية: الشهادة على ما يثبت بالاستقاضة أو التّسامع كالنّسب والزواج، فإنهم أجازوا شهادة كفيف البصر في ذلك.

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والظاهرية صحة شهاد كفيف البصر بحكم عدالته التي تجبُ تهمة عدم الإبصار، ولأنّ السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين.

نطق الشاهد

يشترط في الشاهد عند أدائه للشهادة أن يكون ناطقًا بما يشهد به، فلا تُقبل شهادة الأخرس؛ لعدم استبانة مراده، وذلك عند جمهور الفقهاء.

ويرى المالكية: صحة شهادة الأخرس، في حال إمكان معرفة دلالة إشارته.

ويرى الحنابلة: صحة شهادة الأخرس إذا كتبها بخطه، وليس فقط بإشارته.

ذكورة الشاهد في الحدود والقصاص

يشترط جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة ذكورة الشاهد في الشهادة على الحدود والقصاص دون سائر الحقوق والمدائيات؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الزهري قال: "مضت السُّنة بأنه لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص".

ويرى الظاهرية: قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص، ولكن على مبدأ قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" (البقرة: ٢٨٢)، وما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم في

حديث خروجه في عيد أضحى أو فطر إلى المصلى، وقد مرَّ على النساء فأمرهن بالصدقة، وفيه أنه قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" قلن: بلى.

قال ابن حزم في "المحلى": "ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان. فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلاً واحداً وست نسوة، أو ثمان نسوة فقط".

وحجة الظاهرية: الجمع بين عموم قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" (النور: ٤)، وبين عموم قوله تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان" (البقرة: ٢٨٢).

ذكورة الشاهد في عقد الزواج

يشترط جمهور الفقهاء الذكورة فيمن يشهد على عقد الزواج، فلا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً؛ لما أخرجه الطبراني عن عائشة وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين، وأخرجه الدار قطني عن عائشة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وأخرجه البيهقي عن عائشة وعلي وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهدي عدل".

ويرى الحنفية، والحنابلة في رواية، والظاهرية: عدم اشتراط الذكورة في الشهادة على عقد الزواج، فتصح شهادة رجل وامرأتين. وزاد الظاهرية جواز شهادة أربع نسوة على عقد الزواج؛ عملاً بعموم قوله تعالى: "فإن

لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (البقرة: ٢٨٢)، وحديث البخاري عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل".

انعدام التهمة: يشترط جمهور الفقهاء لقبول الشهادة انعدام التهمة بين الشاهد وبين المشهود عليه، سواء كانت تلك التهمة بالمحاباة كشهادة الخادم لمخدومه، أو بالانتقام كشهادة من بينهم عداوة أو بغضاء؛ لما أخرجه أحمد بإسناد قوي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت"، والغمر هو الحقد، والقانع هو الخادم المنقطع للخدمة.

ويرى الظاهرية: أنه ينظر في العداوة إن كانت تخرج صاحبها إلى ما لا يحل فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد وفي كل شيء، وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل تقبل شهادته.

أما تهمة المحاباة فلا وجه لها عند الظاهرية في حال عدالة الشاهد التي تجب تلك التهمة؛ لأن العدل يتقي الله، فلا تتأثر شهادته بمحبة أو بغضة .

شرط العدالة: يشترط في الشاهد عند أدائه للشهادة أن يكون عدلاً؛ لأن عدالته أصل في تلقي شهادته بالقبول، وأساس في إفادة إخباره بالأمانة.

واختلف الفقهاء في تعريف العدالة بين موسع وبين مضيق، وهم يعنون - في الجملة - مستور الحال، بعدم مجاهرته بالإصرار على الصغائر،

وعدم العلم بارتكابه كبيرة، فلا تقبل شهادة الفاسق لمكان خيانتة، ولعموم قوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" (الحجرات: ٦).

وإذا تاب الفاسق قبلت شهادته عند جمهور الفقهاء، وهو ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة والظاهرية في الجملة، سواء أكانت المعصية من موجبات الحدِّ أم من موجبات التعزير، إلا في حدِّ القذف الذي وقع بينهم فيه خلاف؛ لظاهر النهي القرآني عن قبول شهادته على الأبد ووصفه بالفسق، ثم استثنى التائبين، فاختلف الفقهاء في عود هذا الاستثناء على كلِّ من قبول الشهادة ووصف الفسق، أو على وصف الفسق دون قبول الشهادة؟ وذلك في قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" (النور: ٤-٥).

ونجمل آراء الفقهاء في حكم قبول شهادة التائب من خطيئة قذف المحصنات في المذهبين الآتين:

المذهب الأول: يرى قبول شهادة التائب المحدود في القذف. وهو قول جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

وحجتهم: عموم قوله تعالى: "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" (النور: ٥)، وذلك بعد النهي عن قبول الشهادة من القاذف، فالاستثناء من النفي إثبات، ويعود على ما سبق من ترك الشهادة وإثبات الفسق، ويكون المعنى في الظاهر: إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، وليسوا بفاسقين.

ولأن القاذف لو تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته عند الجميع، ولا جائز أن يكون إقامة الحد عليه هي الموجبة لرد الشهادة؛ لأنه فعل الغير به، وهو مُطَهَّرٌ أيضاً، فلا يصلح مناطاً لرد الشهادة.

المذهب الثاني: يرى عدم قبول شهادة المحدود في قذف حتى وإن تاب. وهو قول الحنفية.

وحجتهم: أن الله تعالى ردَّ شهادته على التأييد نصاً، وأن الاستثناء الوارد للتائبين يرجع إلى صفة الفسق لأنه أقرب مذكور، ولا يرجع إلى الشهادة لبعدها عن الاستثناء، فالمحدود في القذف إذا تاب لا يسمى فاسقاً، ومع ذلك فلا تقبل شهادته، وذلك من تمام الحد.

وذكر ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري": عن المعتزلة: أن مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار. وقالت الخوارج: إنه كافر إلا أن يسلم مُجَدِّداً؛ استدلالاً بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب تُهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد".

ويرى جمهور الفقهاء: أن هذا الحديث محمول على كمال الإيمان، وليس المراد منه نفي أصل الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريت الزاني والسارق وشارب الخمر إذا انتحلوا دعوة الإسلام.

شرط الإسلام في أداء الشهادة على مسلم

اختلف الفقهاء في اشتراط صفة الإسلام للشاهد في النزاعات التي يكون أحد أطرافها مسلماً، ويرجع السبب في هذا الاختلاف إلى أربعة أمور، هي:

١-الاختلاف في مفهوم النص المبين لصفة عدالة الشهود في خطاب المسلمين، هل يمنع غيرهم من الشهادة عليهم أم لا؟.

٢-الاختلاف في النص الوارد بشأن قبول شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في السفر من حيث النسخ وعدمه، وإذا لم يكن منسوخاً فهل هو قاصر على الوصية، أو يتعداها إلى سائر العقود عند الحاجة؟.

٣-الاختلاف في تكييف الشهادة، هل هي ولاية أو إخبار؟.

٤-الاختلاف في طبيعة اختلاف الدّين، هل هو من أسباب العداوة في الدنيا، أم أنه تنوع عقائد مع اتحاد المصالح الإنسانية والتعاون على الإعمار.

ويمكن إجمال أقوال الفقهاء - في هذه المسألة - في ثلاثة مذاهب، كما يلي.

المذهب الأول: يرى عدم جواز قبول شهادة غير المسلم على المسلم بحال مطلقاً، سواء في الوصية في السفر أو في غيرها. وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وروي عن زيد بن أسلم والزهري وقتادة وعطاء. وحجتهم:

(١) أن دلالة النصوص في الكتاب والسنة مانعة في ظاهرها من قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين، ومن ذلك قوله تعالى: "واستشهدوا

شهيدين من رجالكم" (البقرة: ٢٨٢)، فخرج بذلك رجال غير المسلمين؛ لأن الخطاب للمسلمين. وقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق: ٢)، وغير المسلم ليس بعدل؛ لعدم إيمانه بالحق في نظر المسلمين، كما أنه ليس منهم.

وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم"، وفي رواية: "ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة أمتي تجوز على من سواهم".

(٢) أن قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابكم مصيبة الموت" (المائدة: ١٠٦) منسوخ بقوله تعالى: "وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: ٢٨٢)، كما ورد في كتب التفسير عن زيد بن أسلم وغيره. وعلى التسليم بعدم نسخ الآية فليس المراد بقوله: "أو آخران من غيركم" غير المسلمين، وإنما المراد من غير قبيلتكم أو عشيرتكم.

(٣) أن الشهادة تتضمن نوع ولاية، وهي لا تجوز من غير المسلم على المسلم؛ لعموم قوله تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء: ١٤١).

(٤) أن اختلاف الدين أمانة ظاهرة على العداوة، وهي تهمة ترد الشهادة. ويدل على تلك العداوة عموم قوله تعالى: "لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ" (المتحنة: ١).

وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت"، والغمر هو الحقد، والقانع هو الخادم المنقطع للخدمة.

المذهب الثاني: يرى قبول شهادة غير المسلمين وأيمانهم على المسلمين في الوصية خاصة، وبشرط الحاجة، كانعدام وجود المسلمين مع وجود غيرهم. وإلى هذا ذهب الحنابلة، وبه قال الظاهرية ولكنهم قيدوا الحاجة بحال السفر خاصة، وروي هذا عن عائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى الأشعري.

وحجتهم: أن دلالة عموم النصوص في الكتاب والسنة وإن كانت مانعة في ظاهرها من قبول شهادة غير المسلمين عليهم - كما ثبت في دليل المذهب الأول - إلا أن القرآن الكريم نص صراحة على جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية في السفر، فكان هذا كالاستثناء من حكم الأصل، فاقصر عليه؛ عملاً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ" (المائدة: ١٠٦).

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس، "أن هذه الآية الكريمة نزلت في رجل خرج من بنى سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض

ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما (إناء للشرب والطعام) من فضة مخصوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحلف تميم وعدي وكانا نصرانيين - ووجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم". (وصار إسلام تميم في السنة التاسعة من الهجرة، وأما عدي فمات على نصرانيته).

والآية محكمة غير منسوخة كما حكاها المفسرون عن عائشة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم من السلف، والقول بإحكام الآية أولى من القول بنسخها؛ لما في القول بالإحكام من الأعمال بكل الأدلة.

ولا يقال إن المقصود بغيركم هو مَنْ كان من غير قبيلتكم أو عشيرتكم؛ لأن سياق الآية جاء في خطاب المؤمنين "يا أيها الذين آمنوا"، فيكون المراد من غيركم، أى من غير المسلمين.

وإنما اقتصر العمل بهذه الآية عند الحاجة وليس في عموم الأحوال؛ لما رواه ابن حزم عن ابن عباس أنه ذكر في تفسير هذه الآية: "هذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين فأمر الله - عز وجل - أن يشهد رجلين من غير المسلمين".

المذهب الثالث: يرى قبول شهادة غير المسلمين وأيمانهم على المسلمين في جميع الحقوق الإنسانية عند الحاجة بالضوابط العامة في الشهود دون أن يكون منها صفة الإسلام. وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم، حيث جاء في "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (٥ / ٥٧٦): "قال أبو العباس أحمد

بن تيمية: ولو قيل تقبل شهادتهم - أي غير المسلمين - مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان وجهاً، وتكون شهادتهم بدلاً مطلقاً".

وجاء في "الطرق الحكيمة" لابن القيم (ص ٢٧٩): "وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم - أي غير المسلمين - في هذا الموضع - أي الوصية في السفر - هو ضرورة يقتضي هذا التعليل قبولها ضرورة حضراً وسفراً.. ولو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه، ويكون بدلاً مطلقاً".

وحجة هذا المذهب:

(١) أن النصوص المبينة لصفة عدالة الشهود في خطاب المسلمين لا تمنع غيرهم من الشهادة عليهم، فقوله تعالى: "شَهِدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ" (البقرة: ٢٨٢) وقوله تعالى: "وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ" (الطلاق: ٢) خطاب للغالب وليس تقييداً بصفة الإسلام.

وأما العدالة فهي الإنصاف وتكون من المسلم وغير المسلم في المعاملات دون خصوص العقيدة التي لا تصنف الناس إلى عدل وغير عدل؛ لأن الإسلام جعل اختيار الدين حقاً إنسانياً كما قال تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: ٢٥٦)، وقال تعالى: "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ" (الكهف: ٢٩).

وأما حديث: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة أمتي تجوز على مَنْ سواهم" فقد أخرجه البيهقي بسند ضعيف فلا يحتج به، وعلى التسليم بصحته فالمقصود منه الشهادة في الأمور المالية أو الدينية دون الحياتية.

(٢) قياس الشهادة على اليمين، فإذا صحت اليمين بالله تعالى من غير المسلمين صحت شهادتهم؛ حيث أجاز الشافعية والحنابلة لغير المسلم أن يحلف ويكون حنثه بالإطعام والكسوة دون الصوم، وذلك خلافاً للحنفية والمالكية الذين اشترطوا صفة الإسلام لانعقاد اليمين؛ لكونها من الديانات.

ويدل لصحة اليمين من غير المسلم قوله تعالى: "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين" (المائدة: ١٠٦)، وجعل القسم بعد الصلاة لتعظيم اليمين. واختلفوا في تلك الصلاة فقل: صلاة العصر؛ لأنه وقت يعظمه أهل الأديان، وهو رواية عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وقتادة وابن سيرين. وقيل: صلاة من صلاة المسلمين، وهو قول الزهري. وقيل: صلاة أهل دين الشاهدين، وهو رواية عن ابن عباس والنخعي وقتادة.

كما يدل على صحة اليمين من غير المسلمين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأيمان اليهود في حديث القسامة، فيما أخرجه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل ومحبيصة عندما خرجا إلى خيبر، فأخبر محبيصة أن عبد الله قتل واتهم في ذلك يهود خيبر، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكروا قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبيصة ومن معه: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟". قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: "أفتحلف لكم يهود؟". قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى

أدخلت الدار . فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تحلف لكم يهود" دليل على قبول أيمانهم في الإثبات، والشهادة من الإثبات.

(٣) أن آية المائدة الواردة في قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية في السفر تشمل الوصية وغيرها من العقود الحياتية، كما تشمل السفر والحضر؛ إذ لا خصوصية في الوصية، ولا خصوصية في السفر، وإنما الأمر يرجع إلى الحاجة والمصلحة حتى لا يضيع حق المسلم إذا لم يشهده سوى غير المسلمين.

(٤) أن الشهادة إخبار عن أمر وقع، والخبر مقبول من المسلم وغيره بحكم الأصل، وليست الشهادة ولاية بدليل قبولها في شهادة غير المسلم للمسلم، فكما قبلت فيما له فإنها تقبل فيما عليه.

وعلى التسليم بأن الشهادة نوع ولاية فلا مانع أن تكون بين المسلمين وغيرهم في الأموال والمصالح الحياتية، كما في الكفالة والضمان.

وأما قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" فهو متعلق بيوم القيامة؛ لسياق الآية: "قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء: ١٤١).

(٥) أن طبيعة اختلاف الدين ترتب تنوعاً في العقائد ولا ترتب عداوة في المصالح الحياتية؛ لحاجة الناس بعضهم لبعض، ولعموم قوله تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا" (البقرة: ١٩٧) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: ٢).

الرأي المختار: هو ما لا يسع المسلم خلافه، وهو اختيار الدولة ونظامها العام؛ عملاً بالقاعدة الفقهية "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، وقد اختار وليُّ الأمر ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم من جواز قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية وفي غيرها من سائر عقود المعاملات في ساحة القضاء ومجالس التحكيم الأهلية؛ ولأن رابطة المواطنة التي أحيَتْ حرية العقيدة أزلت الأثر السَلبي لاختلاف الدِّين على مصالح الناس المشتركة. وقد نص قانون الإثبات المصري في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م في المادة (٨٦) بقوله: "على الشاهد أن يحلف يمينا أن يقول الحق وأن لا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك".

رابعاً: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى نصابها أو عدد الشهود

النصاب العددي في الشهادة يختلف بحسب محل الشهادة، كما يلي:

(١) أربعة رجال في الزنى عند أكثر أهل العلم، فلا تقبل شهادة النساء فيه؛ لعموم قوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء" (النور: ٤)، وقوله تعالى: "لولا جاءو عليه بأربعة شهداء" (النور: ١٣)، وقوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" (النساء: ١٥)، والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ الشهداء أن يكونوا من الرِّجال.

ويرى الظاهرية، وانتصر له ابن حزم في "المحلَّى": قبول شهادة النساء في الزنى وغيره من الحدود، ولكن على مبدأ أن شهادة المرأة مثل نصف

شهادة الرجل. وأخرج من طريق محمد بن المثني، عن عطاء بن رباح، قال: لو شهد عندي ثمانى نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها. ومن طريق عبد الرزاق عن عطاء بن أبي رباح، قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء، وتجاوز على الزنى امرأتان وثلاثة رجال.

(٢) ثلاثة رجال في شهادة الفقر لمن كان غنياً عند الحنابلة؛ خلافاً للجمهور. فإذا ادعى مَنْ عُرِفَ بغنى أنه فقير لأخذ زكاة فلا يجوز إعطاؤه منها إلا أن يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَابِ من قومه يشهدون: لقد أصابت فلاناً فاقة؛ استدلالاً بما أخرجه مسلم وأبو داود وابن خزيمة عن قبيصة بن مخارق الهلالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسه، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَابِ من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحِتْ يَأكُلُهَا صاحبها سحتاً". وفي رواية: "سداً من عيش" بدلاً من: "قواماً من عيش".

(٣) رجلان فيما سوى الزنى من القصاص وسائر الحدود كالسرقة والقتل. هذا ما ذهب إليه الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة.

وقال أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة: يدخل في ذلك كل ما يطلع عليه الرجال غالباً مما ليس بمال كالنكاح والطلاق والظهار والنسب والإسلام والموت والوكالة والشهادة على الشهادة، ونحوها؛ لقوله تعالى

في الطلاق والرجعة: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" (الطلاق: ٢)، وفي النكاح قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل"، كما أخرجه الطبراني عن عائشة وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين، وأخرجه الدار قطني عن عائشة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وأخرجه البيهقي عن عائشة وعلي وابن عباس.

وقال الحنفية: تجوز شهادة رجل وامرأتين فيما سوى الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق.

ويرى الظاهرية: جواز شهادة النساء منفردات في النكاح وغيره، بناءً على قاعدة: "شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل في كل شيء".

(٤) رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك في الحقوق المالية كالبيع والحوالة عند الفقهاء في المذاهب الأربعة المشهورة.

ويرى الظاهرية: قبول شهادة النساء منفردات، وفقاً لقاعدتهم: "شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل في كل شيء".

(٦) النساء منفردات في الولادة والاستهلال والرضاع وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب بالإجماع؛ للحاجة في ذلك، واختلف الفقهاء في عدد الشاهدات، على خمسة أقوال:

القول الأول: تقبل شهادة امرأة واحدة في الولادة ونحوها سواء أكانت تلك المرأة قابلة (الطبيبة التي تقوم بالتوليد) أم غيرها. وهو مذهب الحنفية في الجملة؛ لما أخرجه الدارقطني بسند فيه انقطاع، عن حذيفة أن النبي

صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة. وأخرج عبد الرزاق والدارقطني عن علي، أنهما أجازا شهادة القابلة.

القول الثاني: تقبل شهادة امرأة واحدة إن كانت قابلة أما غيرها فلا تقبل إلا مع غيرها. وهو رواية عن أحمد، وبه قال الحسن البصري وروي عن ابن عباس.

القول الثالث: تقبل شهادة امرأتين في الولادة ونحوها على الأقل. وهو مذهب مالك والرواية الثانية عند الحنابلة؛ لأنهنّ لما قمن في انفرادهن مقام الرجال وجب أن يقمن في العدد مقام الرجال، وأكثر عدد الرجال اثنان فافتضى أن يكون أكثر عدد النساء اثنتين.

القول الرابع: تقبل شهادة ثلاث نسوة في الولادة ونحوها على الأقل. وهو مروي عن أنس، وحكي عن عثمان البتي؛ لأن الله تعالى ضم شهادة المرأتين إلى الرجل في الموضع الذي لا ينفردن فيه، فوجب أن تستبدل المرأة بالرجل في الموضع الذي ينفردن فيه فيصرن ثلاثاً.

القول الخامس: تقبل شهادة أربع نسوة في الولادة ونحوها على الأقل. وهو قول الشافعي، وروي عن عطاء. قال الشافعي في "الأم": "لأن الله - عز وجل - حيث أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين، أو شاهد وامرأتين، فأقام الثنتين مقام رجل حيث أجازهما. فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال لم يجز - والله أعلم - أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله - عز وجل - في الشهادات، فيجعلون كلّ امرأتين تقومان مقام رجل، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع. وهكذا المعنى في كتاب الله - عز ذكره - وما أجمع عليه المسلمون".

(٦) رجل واحد في رؤية الهلال. وهو أحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد، وبه قال الحنفية إن كان بالسما علة من غيم أو غبار أو نحوهما؛ لما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه.

وذهب المالكية والقول الثاني عند الشافعية والحنابلة إلى اشتراط شاهدين في ثبوت رؤية الهلال، وبه قال الحنفية في حال الصحو؛ لما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وانسكوا لها، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".

وقال المالكية والحنابلة: تقبل شهادة الطبيب الواحد في الشجاج، والبيطار في عيوب الدواب.

المسألة الخامسة

حكم أخذ الأجرة على الشهادة

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشهادة، وذلك على ثلاثة مذاهب في الجملة:

المذهب الأول: يرى جواز أخذ الأجرة على الشهادة عند تحملها وأدائها إن كان في ذلك كلفة على الشاهد. وهو قول جمهور الفقهاء، قال به المالكية والشافعية ووجه الحنابلة.

وحجتهم: عموم قوله تعالى: "ولا يضار كاتب ولا شهيد" (البقرة: ٢٨٢). وأخرج أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس، وأخرجه الطبراني والدارقطني عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار"، وفي لفظ للطبراني عن جابر بن عبد الله: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وللدارقطني والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "لا ضرر ولا ضرار. من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه".

المذهب الثاني: يرى تحريم أخذ الأجرة على حمل الشهادة وأدائها إن تعينت عليه. وهو مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور.

وحجتهم: عموم قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" (الطلاق: ٢)، فأجر الشهادة على الله تعالى.

المذهب الثالث: يرى جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً حتى ولو لم يكن في تحملها أو في أدائها كلفة. وهو قول بعض الشافعية ورواية ثالثة للحنابلة.

وحجتهم: أن إنفاق الإنسان على عياله فرض عين، والشهادة فرض كفاية، وقياساً على أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة.

الرأي المختار: حق لكل مكلف في المسائل الديانية أن يختار الرأي الفقهي الذي تستريح إليه نفسه، ويطمئن إليه قلبه الذي يلقي الله عليه،

مراعياً في ذلك قوة الدليل، ومآلات الاختيار على المستويين الخاص والعام، ومقاصد الدين من إقامة العدل، وعدم الضرر أو الإضرار، وقبل ذلك ومعه عدم المساس بالسيادة القانونية والقضائية، مثل تجريم بيع الصوت الانتخابي؛ عملاً بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، وما أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت، قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".

المبحث الثاني

التعريف بالقضاء وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة

نتكلم في هذا المبحث عن تعريف القضاء وأحكامه العامة في المسائل الخمس الآتية:

المسألة الأولى

تعريف القضاء وبيان مشروعيته

نتكلم عن تعريف القضاء، وبيان مشروعيته في العناصر الثلاثة الآتية:

أولاً: تعريف القضاء في اللغة

يطلق لفظ القضاء في اللغة على الحكم، وأصله قضاي؛ لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت، قال ابن بري: "صوابه بعد الألف الزائدة طرفاً همزت".

والقضاء: الحتم والأمر، وقضى أي حكم، ومنه القضاء والقدر، وقوله تعالى: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" (الإسراء: ٢٣)، أي أمر ربك وحتم.

ويغلب إطلاق القضاء على الفصل في الحكم، وهو قوله تعالى: "وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ" (الشورى: ١٤)، أي الفصل والحكم بينهم.

وقد يكون القضاء بمعنى الفراغ، تقول: قضيت حاجتي، ومنه قوله تعالى: "قَلَمًا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا" (الأحزاب: ٣٧).

وقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإنهاء، تقول: قضى محمد دينه، ومنه قوله تعالى: "وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ" (الحجر: ٦٦)، أي أنهيناها إليه وأبلغناه ذلك.

وقد يكون القضاء بمعنى الوصية أو الإعلام، تقول: قضى عليه عهدًا، أي أوصاه وأنفذه، وبه يفسر قوله عز وجل: "وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب" (الإسراء: ٤)، أي عهدنا، أو أعلمناهم إعلامًا قاطعًا.

وقد يكون القضاء بمعنى البيان، ومنه قوله تعالى: "وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ" (طه: ١١٤)، أي من قبل أن يبين لك بيانه.

وقد يكون القضاء بمعنى الموت، تقول: قضى عليه أي أماته، ومنه قوله تعالى: "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ" (الأحزاب: ٢٣).

وقد يكون القضاء بمعنى الحكم الذي هو المنع، ومنه سمي القاضي حاكمًا لمنعه الظالم من ظلمه.

وبالجملة فإن القضاء في اللغة يقع على معان كثيرة متقاربة كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منه، قال تعالى: "فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ في يومين" (فصلت: ١٢)، أي أراد قطعهن وأحكم خلقهن وفرغ منهن.

وقال أهل الحجاز: القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لها.

يقول الشربيني الخطيب في "مغني المحتاج": "وسمي القضاء حكمًا؛ لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء في محله؛ لكونه يكفُ الظالم عن ظلمه. أو من إحكام الشيء، ومنه: حَكَمه اللجام، لمنعه الدابة من ركوبها رأسها والتصرف على هواها".

ثانيًا: تعريف القضاء في اصطلاح الفقهاء

اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف القضاء اصطلاحًا، وإن كانت لا تخرج عن المعاني اللغوية التي سبق ذكرها، مع تقييد خاص.

(١) في الفقه الحنفي: يقول الكاساني في "بدائع الصنائع": "القضاء هو الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل"

ويقول ابن عابدين في "حاشيته": "القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي، وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية - أي الفقهية عند القاضي - المتلقاه من الكتاب والسنة".

(٢) في الفقه المالكي: يقول ابن رشد في "بداية المجتهد": "القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي - أي فقهي - على سبيل الإلزام".

ويقول أبو الحسن التَّسُولِي المالكي في "البهجة شرح التحفة": "قال القرافي: الحكم - أي القضائي - هو إنشاء إلزام أو اطلاق، فالإلزام كالحكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة، وقد يكون بعدم الإلزام كالحكم بعدم لزوم ما ذُكِر. والاطلاق كالحكم بزوال الملك عن أرض زال إحيائها، أو زوال ملك الصائد عن صيد".

(٣) في الفقه الشافعي: يقول الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج":
"القضاء هو فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى"، أي
الذي يراه القاضي باجتهاده حكماً لله تعالى، أي حكماً بالحق.

وقال الشيخ الشرقاوي في "حاشيته على التحرير": "القضاء هو إلزام مَنْ
له الإلزام بحكم الشرع"، أي الذي يراه القاضي باجتهاده حكم الشرع
والحق.

(٤) في الفقه الحنبلي: يقول الشيخ البهوتي في "كشاف القناع": "القضاء
هو الإلزام بالحكم الشرعي - أي الفقهي عند القاضي - وفصل
الخصومات".

ويقول المرداوي في "شرح منتهى الإرادات": القضاء هو تبين الحكم
الشرعي - أي الفقهي عند القاضي - والإلزام به، وفصل الخصومات.

وبالتأمل في تلك التعريفات رغم اختلاف ألفاظها فإنها متفقة في كون
القضاء يظهر حكم الحق في نظر القاضي وفقهه، ويلزم المتخاصمين
به، ولما كانت خاصية القضاء في الإلزام: رأينا اهتمام أكثر التعريفات
بتلك الخاصية، فنصوا عليها، كما هو واضح فيها.

وعمل القاضي من إظهار الحق المسمى بحكم الشرع من وجهة نظر
القاضي الفقهية، والإلزام به لفض المنازعات لا يكون إلا بعد رفع
الخصومة إليه سواء من أحد المتخاصمين أو من غيرهما في مسائل
الحسبة، في حال أن يكون لها وجه، ولذلك نرى الأمير اليميني الصنعاني
في "سبل السلام" يعرف القضاء بأنه: "إلزام ذي الولاية بعد الترافع".

ثالثاً: مشروعية القضاء

تظاهرات الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على مشروعية نصب القضاء، ومن ذلك ما يلي:

(١) دليل الكتاب: منه قوله تعالى: "يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحَسَابِ" (ص: ٢٦)، فقد أمر الله تعالى نبيه داود بعد أن نصبه خليفة في الأرض أن يحكم ويقضي بين الناس في خصوماتهم ومنازعاتهم، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، عند جمهور الفقهاء.

وقوله تعالى: "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ" (المائدة: ٤٩)، وهذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس في خصوماتهم بما أنزل الله من أحكام، وهذا الأمر يسرى على من يلي أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى: "قُلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء: ٦٥).

وقوله تعالى: "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ" (النساء: ١٠٥).

وفي كل ذلك دلالة واضحة على أن القضاء والحكم بين الناس بالحق والعدل سمة من سمات المجتمع المسلم.

(٢) دليل السنة: أحاديث كثيرة، منها: ما رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم عن بريدة بن الحصيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رَجُلٌ عرف الحق وقضى به في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجَارٌ في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار"، وفي الحديث تحذير لمن يحكم بجهل أو على خلاف الحق مع معرفته به.

وأخرج الشيخان عن أمِّ سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار"، وفي رواية: "فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه"، واللحن هو الميل عن جهة الاستقامة، والمراد أن بعض المتخاصمين يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره، وفي الحديث بيان لمشروعية القضاء، وأن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما حكم له به على غيره إذا كان ما ادعاه باطلاً في نفس الأمر، ويجوز للحاكم أن يحكم بما ظهر له ويلزم بذلك المدعي عليه، وينفذ حكمه ظاهراً ولكنه لا يحل به الحرام إذا لم يكن للمدعي حق فيما ادعاه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، ويرى أبو حنيفة أن الحكم ينفذ ظاهراً وباطناً فيما ينعقد بحكم القاضي فلو حكم الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له.

وأخرج الشيخان عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"، ومعنى قوله: "إذا حكم الحاكم"، أي أراد الحكم؛ لقوله "فاجتهد" لأن الاجتهاد يكون قبل الحكم، ومعنى قوله: "أخطأ"، أي لم يوافق ما هو عند الله تعالى من الحكم.

والحديث يدل دلالة واضحة على مشروعية القضاء، وفضله بسبب ما فيه من الاجتهاد، والبحث عن الحق، وإقامة العدل بين الناس.

ونقل الصنعاني في "سبل السلام" عن "مختصر شرح السنة للبربهاري ت ٣٢٩هـ": "أن المجتهد هو مَنْ جمع خمسة علوم: علم كتاب الله، وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوال علماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس، وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحاً في نص الكتاب أو السنة أو الإجماع. ويجب أن يعلم مَنْ عِلْمُ الكتاب: الناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والخاص والعام، والمحكم والمتشابه، والكراهة والتحريم والإباحة والندب.

ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف، والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب والعكس حتى إذا وجد حديثاً لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه مَحْمَلِهِ، فإن السُّنَّةَ بيان للكتاب فلا تخالفه. وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ.

وكذا يجب أن يعرف مَنْ علم اللغة ما أُتِيَ في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب.

ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام، ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع.

فإذا عرف كلَّ نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد".

(٣) دليل الإجماع: حكى عامة الفقهاء في المذاهب المختلفة إجماع الأمة على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس في خصوماتهم.

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن مشروعية تنصيب القضاء على سبيل الوجوب؛ لعدم قيام مصالح الناس إلّا به. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن قدامة في "المغني": "لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟".

وذهب بعض القدرية والخوارج وأبو بكر الأصم ت ٢٢٥هـ إلى: أن تلك المشروعية على سبيل الجواز؛ لإمكان استقامة الناس بدون القضاء، فالصحابه - رضي الله عنهم - بقوا بدون خليفة مدة التشاور أيام سقيفة بني ساعدة حتى تمت البيعة لأبي بكر، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول الكاساني في "بدائع الصنائع": "ولا عبرة بخلاف بعض القدرية في عدم وجوب نصب الإمام أو القاضي؛ لإجماع الصحابة على ذلك، ولمساس الحاجة إليه".

(٤) دليل المعقول: هو أن الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يستطيع أن يعيش وحده منفردًا دون احتياجه لغيره من بني جنسه، ولا تستقيم حياته إلا أن يعيش في جماعة، ومن هنا كان احتمال وجود الخلافات والمنازعات قائمة لتعارض الأهواء والرغبات والحقوق والمصالح بين أفراد الجماعة، فقد يستولى أحد على حق غيره أو يبخل بالحق الذي عليه لغيره، فإن لم يكن للجماعة قانون أو شرع يحتكم إليه تصارع الناس وعاشوا حياة الغابة، القوى يأكل الضعيف، وهذا إن وقع في حياة غير البشر فلا يصح أن يقع من البشر الذين اختصهم الله بعقل مفكر، وكرمهم على سائر المخلوقات، واختصهم بتحمل الأمانة والتكليف، فكان لابد من احتكامهم لما يقيم العدل بينهم، وتنصيب إمام لهم يقوم على هذا العدل ويحرسه.

ولمّا كان الإمام وحده لا يستطيع القيام بتلك المهام منفردًا اقتضى ذلك أن يستعين ببعض معاونين، ومنهم القضاة الذين ينوبون عنه في الفصل بين الخصومات والمنازعات، ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قاضيًا إلى اليمن، كما بعث عتاب بن أسيد قاضيًا إلى مكة.

المسألة الثانية

أحكام القضاء التكليفية

نتكلم عن أحكام القضاء التكليفية، في العناصر الأربعة الآتية:

أولاً: الحكم التكليفي لاختيار وقبول القضاء

يختلف الحكم التكليفي لفريضة القضاء باختلاف جهتي الاختيار والقبول، فإن نظرنا إلى جهة الحاكم أو الإمام المسئول عن اختيار القضاة: كان الفرض عينياً على الحاكم أن يُقَلِّدَ شخصاً يصلح للقضاء، أو يتولاه هو بنفسه، ولا يجوز له أن يترك المجتمع دون مَنْ يقيم العدل في خصوماتهم ومنازعاتهم.

وإن نظرنا إلى جهة الناس الصالحين لتولي القضاء وقبول مهامه: كان الفرض محتملاً لأن يكون عينياً أو كفائياً.

فيكون قبول القضاء فرض عين في شأن مَنْ يصلح لتولي القضاء إذا لم يكن هناك مَنْ يصلح لتوليه غيره، وفي هذه الصورة يكون تعيين فرضية القضاء من ناحية الإمام في الاختيار، وناحية الصالح للقضاء في القبول.

يقول ابن قدامة في "المغني": "قد نقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يتعين عليه، فإنه سئل هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم. قال ابن قدامة فهذا يحتمل أنه يحمل على ظاهره في أنه لا يجب عليه؛ لما فيه من الخطر بنفسه، فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، ولذلك امتنع أبو قلابة، منه وقد قيل له: ليس غيرك. ويحتمل أن يحمل على مَنْ لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره، فإن الإمام أحمد قال: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟".

ويكون قبول القضاء فرض كفاية في شأن الصالحين لتولي القضاء إذا كان المطلوب للقيام به بعضهم؛ لأن الفرض الكفائي هو ما يطلبه الشرع على سبيل الجزم من مجموع المكلفين لا من جميعهم، إذ المطلوب

حصوله دون النظر إلى شخص واسم الفاعل، وهذا الفرض إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقيين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين على فعله، إن علموا بحاجة القضاء إليهم، وتركوه عمدًا.

ثانيًا: حكم الأولى في شأن الصالحين لتولى منصب القضاء

إذا كان قبول القضاء فرض كفاية في شأن الصالحين لتوليّه إذا كان المطلوب بعضهم، فما هو حكم الأولى في شأن كلّ واحد ممن يصلح له، وقوي على القيام به، وأداء الحق فيه، مع وجود غيره من الصالحين لأمره؟ ثلاثة مذاهب للفقهاء في ذلك:

المذهب الأول: يرى أن الأولى هو استحباب قبول منصب القضاء لمن عُرض عليه. وإليه ذهب عبد الله بن مسعود، وعقبة بن عامر، وهو أحد القولين عند الحنفية.

وحجتهم: أن في العمل القضائي فضل عظيم، ولذلك جعل الله فيه أجرًا مع الخطأ، وأسقط عنه إثم الخطأ. ولأن فيه أمرًا بالمعروف، ونصرةً للمظلوم، وأداءً للحق إلى مستحقه، وردًا للظالم عن ظلمه، واصطلاحًا بين الناس، وتخليصًا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب، ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأمرهم، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا إلى اليمن قاضيًا، وبعث أيضًا معاذًا قاضيًا إلى اليمن.

قال ابن قدامة في "المغني": "وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لأن أجلس قاضيًا بين اثنين أحب إليّ من عبادة سبعين سنة".

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجلٌ آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها".

وأخرج أحمد عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أتدرون من السابقون إلى ظل الله - عز وجل - يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم".

وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص، قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اقض بينهما يا عمرو. قلت: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: "وإن كان"، قلت: فإذا قضيت بينهما، فما لي؟ قال: "إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت وأخطأت فلك حسنة".

المذهب الثاني: يرى أن الأولى كراهة قبول منصب القضاء عند وجود آخرين يصلحون له. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وروي عن ابن عمر وأبي قلابة.

وحجتهم: أن في العمل القضائي غرر شديد، وخطر عظيم، وعرضة للوزر الكبير إذا لم يؤد الحق فيه. كما أن في ترك العمل القضائي السلامة والنَّجاة من الاغترار بزهوة. يقول ابن قدامة في "المغني": "كان يقال أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهية، ولذلك كان السلف - رحمة الله عليهم - يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره".

قال ابن الأثير في "جامع الأصول في أحاديث الرسول": "أراد عثمان ابن عفان - رضي الله عنه - تولية ابن عمر القضاء فأباه، وقال لعثمان: لا أقضي بين رجلين، فقال عثمان: فإن أباك كان يقضي؟ فقال ابن عمر: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل - عليه السلام - وأني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيمٍ"، وسمعتَه يقول: "مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِذْهُ"، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيًا فأعفاه. وقال: لا تخبر أحدًا".

ويحكي ابن قدامة في "المغني" عن خاقان بن عبد الله، أنه قال: "أريد أبو قلابة على قضاء البصرة فهرب إلى اليمامة، فأريد على قضائها فهرب إلى الشام، فأريد على قضائها، وقيل له: ليس ههنا غيرك؟ قال: "فأنزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مثلي مثل ساجد وقع في البحر فسبح يومه، فانطلق ثم سبح اليوم الثاني فمضى أيضًا، فلما كان اليوم الثالث ففترت يده".

ويقول الصنعاني في "سبل السلام": استدعى المأمون الإمام الشافعي لقضاء الشرق والغرب فامتنع، كما استدعى المنصور من قبله الإمام أبا حنيفة لتولى القضاء فامتنع، فحبسه المنصور وضربه. والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون".

وفي "مناقب أبي حنيفة للموفق المكي": أن أبا حنيفة لما أراه أبا هبيرة - والي العراق من قبل بني أمية - على قضاء الكوفة رفض وأصرَّ على رفضه رغم حبسه وضربه بالسوط حتى تورَّم رأسه، ويروى أنه كان يُخْرَج

به كل يوم فيضرب عشرة أسواط حتى بلغ مجموع ذلك عشرة ومائة سوط، ولما خُلِّي سبيله مؤقتًا هرب إلى مكة، وأقام بها حتى خلافة العباسيين.

كما رفض الإمام أبو حنيفة القضاء في خلافة المنصور الخليفة العباسي لما عرضه عليه، ولما أصرَّ الخليفة وحلف عليه أن يتولاه، حلف أبو حنيفة هو الآخر على عدم توليه وقال: اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا مَنْ يخاف الله، والله ما أنا بمأْمون الرضا، فكيف أكون بمأْمون الغضب، وإني لا أصلح لذلك، فقال له الخليفة: كذبت أنت تصلح، فقال أبو حنيفة: قد حكمت على نفسك، فكيف يحل لك أن تولي قاضيًا على أمانتك وهو كذاب؟

كما طُلب من زفر صاحب أبي حنيفة أن يتولى القضاء فرفض، ولما أراد الأمير أن يكرهه على ذلك اختفى مدة، فأمر الحاكم بهدم منزله عقابًا له. وأخرج الذهبي في "سير أعلام النبلاء"، أن الإمام الشافعي قال لأحمد بن حنبل: إن أمير المؤمنين - يعني محمد الأمين ت ١٩٨ هـ وهو ابن هارون الرشيد - سألني أن ألتمس له قاضيًا لليمن، وأنت تُحبُّ الخروج إلى عبد الرزاق - هو إمام الحديث وصاحب "المصنّف" - فقد نلت حاجتك، وتقضي بالحق؟ فأجابه الإمام أحمد بن حنبل بقوله: يا أبا عبد الله إن سمعت منك هذا ثانية لم تُرثني عندك.

وأخرج أحمد وأصحاب السنن في بيان خطر عمل القاضي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ وَلِيَ القضاء فقد ذبح بغير سكين".

يقول الصنعاني في "سبل السلام": "يدل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول: مَنْ تَوَلَّى القضاء فقد تعرض لذبح نفسه فليَحْذَره، وليتوقه، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكتها بتوليها القضاء، وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح فري الأوداج الذي يكون في الغالب بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. وقيل: ذبح ذبحاً معنوياً وهو لازم له؛ لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنيا لإرادته الوقوف على الحق وطلبه واستقصاء ما تجب عليه رعايته في النظر في الحكم، والموقف مع الخصمين، والتسوية بينهما في العدل والقسط، وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة، فلا بد له من التعب والنَّصَب".

وحكي ابن قدامة في "المغني" عن بعض العلماء اعتراضهم على هذا الاستدلال، وقالوا: "لا دلالة في الحديث على ذم القضاء، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة فقط، فكأنَّ مَنْ وليه قد حُمِلَ على مشقة كمشقة الذبح بغير سكين".

وأما امتناع السلف عن تولي القضاء فلا يدل على كراهته؛ لاحتمال أن يكون الامتناع للبعد عن سلطان الحاكم، أو للتفرغ للعلم أو غير ذلك.

المذهب الثالث: يرى أن الأولى في قبول عمل القضاء أو تركه يختلف باختلاف الحال. وإلى هذا ذهب بعض المالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في قول أبي عبد الله بن حامد.

فإن كان من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله فيجوز له قبوله، ويجوز له الاعتذار عنه.

وإن كان رجلاً خاملاً لا يرجع إليه في الأحكام، وليس معروفاً فالأولى له توليه ليرجع إليه في الأحكام، ويقوم به الحق، وينتفع به الناس.

وإن كان مشهوراً في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى فالأولى الاشتغال بذلك؛ لما فيه النفع مع الأمن من الغرر.

وإذا كان ذا حاجة، وله في القضاء رزق فالأولى له الاشتغال به، فيكون أولى من سائر المكاسب؛ لأنه قربه وطاعة.

وإذا خاف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده أو على الناس إن لم يتول القضاء وجب عليه قبوله.

ثالثاً: حكم طلب القضاء

يقول ابن قدامة في "المعني": "يكره للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله؛ لأن أنسا - فيما أخرجه الترمذي - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شَفْعَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَكْرَهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يَسُدُّهُ".

وأخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن سُمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكُلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها".

وأخرج مسلم عن أبي ذر، أنه قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: "إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذ بحقها، وأدّى الذي عليه فيها".

وأخرج الشيخان عن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمّمي، أو من قومي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولّاك الله عز وجل، وقال الآخر: مثل ذلك، فقال: "إنا والله لا نولّي على هذا العمل أحدًا سألّه، ولا أحدًا حرص عليه".

قال النووي في "شرح صحيح مسلم": "هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، لاسيما لمن كان فيه ضعف. قال العلماء: والحكمة في أنه لا يُولّي مَنْ سأل الولاية أنه يوكل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة، سالف الذكر، وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئًا، ولا يُولّي غير الكفاء، ولأن فيه تهمة للطالب والحريص".

وقال الصنعاني في "سبل السلام": "إنما نهى عن طلب الإمارة؛ لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف، وقدرة بعد عجز تتخذها النفس المجبولة على الشرّ وسيلة إلى الانتقام من العدو، والنظر للصدّيق، وتتبع الأغراض الفاسدة، ولا يوثق بحسن عاقبتها، ولا سلامة مجاورتها، فالأولى أن لا تُطلب ما أمكن، وإن كان قد أخرج أبو داود بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة، ومَنْ غلب جوره عدله فله النار".

ويرى بعض المالكية، كما في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": أن طلب تَوَلَّى القضاء من الحاكم واجب لمن توفرت فيه شروط القضاء، إن خاف ضياع الحق له أو لغيره إن لم يتولاه.

ويرى ابن فرحون المالكي في "تبصرة الحكام": "أن طلب القضاء يعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: يكون واجبًا، أو مستحبًا، أو حرامًا أو مكروهًا، أو مباحًا.

فيكون واجبًا إذا كان من أهل الاجتهاد ولا يوجد قاض، أو يوجد لكن لا تجوز ولايته، أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره.

ويكون مستحبًا إذا كان هناك عالم خامل الذِّكر ليس معروفًا، فلا يرجع الناس إليه لمعرفة الأحكام لعدم شهرته، فيستحب له طلب القضاء لنشر العلم ونفع الناس به، أو كان هو الأصلح من غيره.

ويكون حرامًا إذا كان جاهلاً لا تتوفر فيه شروط القضاء، أو كان عالمًا مع اتصافه بالفسق والظلم.

ويكون مكروهًا لمن كان يسعى بطلبه القضاء، ويوجد من هو أصلح منه، أو كان يسعى لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس، ولو قيل إنه يحرم في هذه الصورة - كما يقول ابن فرحون - لكان وجهه ظاهرًا لقوله تعالى: "تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" (القصص: ٨٣). ومن صور الكراهة التي ذكرها ابن فرحون: ما إذا كان غنيًا عن أخذ الرزق على القضاء وكان مشهورًا

بعلمه بين الناس لا يحتاج أن يشهر نفسه بالقضاء، ثم قال: ويحتمل أن يلحق هذا بقسم المباح.

ويكون القضاء مباحًا إذا كان فقيرًا وله عيال فيجوز له أن يسعى في تحصيل القضاء لكي يسد حاجته، وكما لو كان يقصد بطلابه أن يدفع ضرًا عن نفسه به".

هذا، ويجوز للحاكم أن يتخير من أهل الأمانة والعلم من يرى فيه الكفاية والصلاحية، ويكون موضع ثقة الناس، ويجبره على القضاء لو أبى، فقد حدث ذلك في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما أخرج البوصيري في "تحاف الخيرة المهرة"، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"، "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دعي سعيد بن عامر الجمحي فقال: إني مستعملك على أرض كذا وكذا، فقال: أوثقُلني يا أمير المؤمنين؟ وفي رواية: لا تفتني يا أمير المؤمنين؟، فقال عمر: والله لا أدعك، قلدموها - أي الخلافة - في عنقي وتتركوني؟".

رابعًا: حكم تولي القضاء لغير الصالحين له

يحرم على الحاكم اختيار غير الصالحين لتولي القضاء مع وجود الصالحين له، كما يحرم على غير الصالح للقضاء قبول هذا المنصب.

أما الحاكم فلأنه يتعين عليه البحث عن أصلح الناس وأفضلهم وأرضاهم لله تعالى ليؤليه، فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة مَنْ

هو أَرْضَى اللهُ تعالى منه فقد خان الله، وخان رسوله، وخان جميع المؤمنين".

وأما الشخص الذي لا يُحسن القضاء، ولم تجتمع فيه شروطه فيدل على تحريم قبوله هذا المنصب: ما أخرجه أصحاب السنن، وصححه الحاكم عن بريدة بن الحصيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار".

ولأن مَنْ لا يُحسن القضاء لا يقدر على العدل فيه، فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره، ويقع بذلك الظلم المحرّم.

المسألة الثالثة

أحكام القضاء العامة

نتكلم عن أحكام القضاء العامة في العناصر الثلاثة الآتية:

أولاً: أركان القضاء

الركن في اللغة هو الجانب القوي أو الناحية القوية، وما تقوى به من ملك وجند وغيره، وبذلك فسر قوله تعالى: "فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ" (الذاريات: ٣٩).
ويجمع الركن على أركان وأركان.

والركن في الاصطلاح عند جمهور الفقهاء: هو ما لا بد منه لتصور الشيء ووجوده، سواء كان جزءً منه أو مختصاً به، وهو بذلك رديف الشرط.

ويرى الحنفية: التفريق بين الركن وبين الشرط، فالركن عندهم هو ما لا بد منه وكان داخلاً في الماهية، فهو جزء من حقيقة الشيء لا يوجد إلا به. أما الشرط فهو ما لا بد منه وكان خارجاً عن الماهية.

وأركان القضاء خمسة، وهي القاضي، وحكم القضاء، والحق المقضي به، والمقضي عليه، والمقضي له، ونوجز بيان ذلك فيما يلي:

(١) القاضي: وهو الشخص الذي عينه الحاكم للفصل في الدعاوي والخصومات.

(٢) القضاء: وهو ما ينطق به القاضي من حكم لحسم النزاع وقطع المخاصمة.

(٣) المقضي به: وهو الحق الذي هو محل كلام القاضي.

وهذا الحق إما أن يكون حقاً لله محضاً كالعبادات، وقد وصفه فقهاء الحنفية بأنه الحق العام المجتمع المسلم، وإنما أضيف لله سبحانه إشعاراً بأهميته وتشريعاً له.

وإما أن يكون حقًا للعبد خالصًا كالأموال بين الناس حيث جعل الله أمر تصريفها لمن وضعها الله تحت يده، كما قال تعالى: "وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ" (الحديد: ٧)، وقال جل شأنه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" (النساء: ٢٩)، فكان الرضا هو السبيل إلى الاستطابة.

وإما أن يكون حقًا مشتركًا بين الله تعالى وبين العبد، وحق الله فيه غالب كالأعراض التي جعل الله لانتهاكها حدودًا، فرغم أنها حق للعبد إلا أن الضرر على المجتمع آكد، ولذلك لا تسقط بالعفو عند الجمهور.

وإما أن يكون حقًا مشتركًا بين الله تعالى وبين العبد وحق العبد فيه غالب كالدماء التي جعل الله للاعتداء عليها قصاصًا، فقال تعالى: "وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ" (الإسراء: ٣٣)، وجعل - أيضًا - لولي الدَّم حقَّ العفو عنها، فقال سبحانه: "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم" (البقرة: ١٧٨)..
(٤)المقضي عليه: وهو مَنْ يحكم القاضي ضده، أو مَنْ يستوفى منه الحق، سواء كان المدعي أو المدعي عليه، بحسب ما يظهر للقاضي.

(٥)المقضي له: وهو مَنْ يحكم القاضي لصالحه، أو مَنْ يستوفى الحق له. وقد يكون المحكوم له هو المدعي عليه إذا ثبت الحق له، وفي الغالب يكون المحكوم له هو المدعي وذلك في أحوال رفعه الدعوى بحق.

وفي حقوق العباد المحضة أو الغالبة يشترط للمحكوم له أن يدعى الحق المحكوم به، فلا يحكم القاضي لأحدٍ بحقٍّ لم يطلبه؛ إذ ربما تسامح فيه. أما حقوق الله المحضة أو الغالبة فإن المحكوم له هو الشرع، أو ما يعرف بالحق العام، أو حق المجتمع، ويحق للقاضي أن يحكم به، نيابة عن المجتمع بناء على طلب النائب العام.

ثانيًا: رزق القاضي وأجرته

الرزق غير الأجرة. أما الرزق في اللغة فهو العطايا والمنح المنقطعة أو الجارية، والمقصود بالرزق عند الفقهاء كما عرفه ابن عابدين في "حاشيته": "ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة".

وأما الأجر في اللغة فهو عوض العمل أو المنفعة، وضابطه عند الفقهاء، كما ذكره ابن قدامة في "المغني": "كلُّ ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون عوضًا في الإجارة"، وكما يكون الثمن باتفاق المتبايعين يكون الأجر باتفاق المتعاقدين غالبًا.

وبهذا يتضح أن الفرق الأساس بين الرزق وبين الأجر عند الفقهاء يرجع إلى تكييف العلاقة بين طرفي المعاملة المرتب عليها الأجر أو الرزق، فإن كانت تعاقدية فإن ما يأخذه العامل يكون أجرًا وتجري فيه المشاركة. وإن كانت تكليفية بحكم الولاية فإن ما يأخذه العامل يكون رزقًا ويكون إذعانًا من الولي لا يخضع إلا لحد الكفاية الإنساني من مأكّل وملبس ومسكن ومركب، ولوازم ذلك بما لا يُدخّر منه.

وقد اختلف الفقهاء في حكم منح القاضي رزقاً أو اشتراطه أجراً مقابل توليه عمل القضاء.

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم رزق القاضي الذي يكون من عطايا بيت المال، إلى أن تلك العطايا في حكم الأصل مقيدة بحال الاحتياج والفقر، فلا يجوز للإمام أو الحاكم منحها لغير محتاج ولو كان من أفضل الناس.

كما يرجع سبب الخلاف في حكم أجر القاضي إلى أن الأجر يكون في شئون الدنيا وليس في القربات والطاعات كالصلاة والصيام، والقضاء شبيه بتلك الطاعات. كما أن الأجر يكون في عمل معلوم لمنع النزاع، وهذا غير متحقق في عمل القاضي. ونذكر فيما يلي مذاهب الفقهاء في مسألتى رزق القاضي وأجره.

(١) رزق القاضي:

اتفق الفقهاء على جواز منح القاضي رزقاً يحقق له وأسرته الملزمة منه حد الكفاية إذا كان من أهل الحاجة. أما إذا كان من الأغنياء فقد اختلفوا في حكم إعطائه هذا الرزق على مذهبين.

المذهب الأول: يرى جواز أن يُطلق الحاكم للقاضي من الرزق ما يكفيه من بيت المال، والأفضل للقاضي أن يأخذه ولو كان غنياً حتى لا يُخرج من بعده. وهو قول جمهور الفقهاء، الحنفية في أحد القولين، والإمام مالك وبعض أصحابه، والشافعية في قول أبي بكر الشاشي شيخ الشافعية

في عصره ت ٣٦٥هـ، والحنابلة في المذهب، وبه قال القاضي شريح ومحمد بن سيرين.

وحجتهم:

(١) ما ذكره السمناني الحنفي في "روضة القضاة": أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وولاة أمرها رزقه أربعمائة درهم في كل عام. وذكره القرافي المالكي في "الذخيرة" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرزق عتاب بن أسيد أربعين أوقية في السنة. قال القرافي: رواه الزهري ولم يبين ذهبًا ولا فضة.

(٢) ما ذكره السمناني في "روضة القضاة"، وابن قدامة في "المغني" أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل في الشام أن انظروا رجالًا من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله؛ ليكون لهم قوة وعليهم حجة.

(٣) ما ذكره ابن قدامة في "المغني" أن عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا، ورزق شريحًا في كل شهر مائة درهم، وبعث إلى الكوفة عمارًا وعثمان بن حنيف وابن مسعود ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان، وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم.

(٤) ما ذكره القرافي في "الذخيرة" أن عمر بن عبد العزيز أجرى للقاضي دفع مائة دينار في السنة، وكان يوسع على عماله، ويقول: ذلك لهم قليل إذا أقاموا كتاب الله وعدلوا.

(٥) أن إعطاء القاضي رزقاً يرفع عنه الضرر الذي يصبه بدونه، فحسب القاضي أن يبذل علمه واجتهاده في فصل النزاع بدون مقابل، فلا يجمع عليه بين هذا البذل وبين مؤونة وكلفة معيشته في زمن توليه القضاء حتى لو كان غنياً؛ خاصة وأن القاضي كثيراً ما ينفق على مستلزمات عمله من ورق المحاضر والسجلات والأقلام والملبس والمواصلات.

(٦) أن إكفاء القاضي وأسرته الملزمة منه بالرزق من بيت المال يحفظ نزاهة القضاء، فلا يطمع القاضي في أموال المتخاصمين، وإذا فعل ذلك مع اكفائه في الرزق لم يكن له عذر عند مؤاخذته.

(٧) أن القاضي عامل في خدمة الناس، فكانت كفايته عليهم بالرزق لا من طريق الأجر، ولو لم يجز فرض الرزق له من بيت المال لتعطلت وضاعت الحقوق.

المذهب الثاني: يرى عدم جواز منح القاضي رزقاً إذا لم يكن محتاجاً. وهو قول الحنفية في القول الثاني، والمالكية في قول المازري وغيره من بعض المالكيين، والشافعية في المذهب، والحنابلة في رواية حكاها أبو الخطاب.

وحجتهم:

(١) أن الرزق لا يكون إلا للمحتاجين، كما أن الإنفاق من بيت المال لا يجوز إلا في المصالح، ولا مصلحة في دفع الرزق للقاضي الغني المتبرع.

(٢) أن عدم إعطاء الرزق على القضاء أبلغ في المهابة له، وأدعى للنفوس على اعتقاد التعظيم والجلال لمقامه.

الرأي المختار: هو ما لا يسع المسلم خلافه، الذي عليه اختيار الدولة ونظامها؛ عملاً بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، وهو عدم التعامل بمصطلح رزق القاضي الذي تجاوزه التطور الحضاري، وصار للقضاة رواتب أو أجورًا نظامية.

(٢) أجر القاضي:

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على القضاء بحيث يكون للقاضي أجرًا مشروطًا ومعلومًا، وليس رزقًا ممنوحًا بحد الكفاية، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يرى عدم جواز الاستئجار على القضاء بحال. وهو مذهب الجمهور، قال به الحنفية، والمالكية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المشهور، وبه قال مسروق بن الأجدع وعبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن، وقالوا: "لا نأخذ أجرًا على أن نعدل بين اثنين". وحكى فيه القرافي الإجماع فقال في "الذخيرة": "اتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة"، أي على القضاء.

وحجتهم:

(١) ما ذكره ابن قدامة في "المغني" أن عمر بن الخطاب قال: "لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا".

(٢) أن القضاء من القربات والطاعات، ويوصف فاعله بأنه من أهل القربى، فأشبه الصلاة التي يُتَقَرَّبُ بها تحنُّنًا دون أجر.

(٣) أن القضاء ليس عملاً يعملُه القاضي نيابة عن غيره حتى يأخذ عليه أجرًا كغيره من المُستَخدمين، وإنما يقضي القاضي باجتهاد نفسه لإظهار الحق لنفسه قبل إعلانه للخصوم، فهو يعمل عند نفسه ولا يأخذ الإنسان من نفسه أجرًا، فأشبه الصلاة. ولا يقال إن القاضي يعمل عند الخصوم أو حتى الإمام الذي عيّنه؛ إذ لو كان يعمل عند أحد منهم لوجب عليه طاعته فيما يريد من صيغة الحكم القضائي.

(٤) أن القضاء عمل غير معلوم القدر، فلا يجوز أن يكون محلًّا للإجارة؛ إذ يشترط لصحة الإجارة العلم بالمعقود عليه.

(٥) أنه إذا جاز للقاضي أن يأخذ رزقًا من بيت المال عند جمهور الفقهاء فهو لا يعني جواز إعطائه أجرًا. يقول ابن قدامة في "المغني": "ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز الأجرة بدليل القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها".

المذهب الثاني: يرى جواز الاستئجار على القضاء دون أي حرج. وهو وجه عند الشافعية قال به القاضي حسين المروزي شيخ الشافعية في عصره ت ٤٦٢هـ.

وحجتهم:

(١) أن القضاء من الأعمال الفنية المادية كالتعليم والتطبيب فجاز الاستئجار عليه، وليس من القربات المحضة كالصلاة والصيام. وتكون القرية أو الطاعة في القضاء أو غيره من الأعمال المادية في النية القلبية التي لا تأثير لها بين المتعاملين بحسب الظاهر.

(٢) القياس على الرزق، فإذا كان جمهور الفقهاء قد أجاز منح القاضي رزقاً يكفيه وأسرته الملزمة منه من بيت المال فلا مانع من إعطائه أجرًا.

(٣) أن أجر القاضي ليس على عمله الاجتهادي الذي يتقرب به إلى الله تعالى، ولكن الأجر نظير احتباس وقته، فهو مقابل منعه عن السعي للمكاسب؛ ليتفرغ للقضاء ويحتبس عليه.

المذهب الثالث: يرى كراهة أخذ الأجر المشروط على القضاء. وهو قول ابن مسعود والحسن البصري، واختاره الإمام أحمد فقال: "ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرًا، وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم".

وحجتهم: الخروج من الخلاف في حكم الأجر على القضاء؛ خاصة وأنه يمكن اكفاء القاضي بالرزق من بيت المال، فلا حاجة للأجر.

الرأي المختار: هو ما لا يسع المسلم خلافه، الذي عليه اختيار الدولة ونظامها؛ عملاً بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، وهو ما ذهب إليه القاضي حسين المروزي شيخ الشافعية في عصره، والذي قال بجواز إعطاء القاضي أجرًا مشروطًا في عقد إجارة كامل الأركان يحفظ

للمتعاقدين حقوقهما باعتبار القضاء عملاً فنياً مادياً، وليس قرينة أو منسكاً محضاً كالصلاة والصيام في ذاته، وأطلقوا على هذا الأجر راتباً.

ثالثاً: إلزام القاضي أن يحكم بمذهب معين أو بالقانون

اختلف الفقهاء في حكم الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين عند تقليده، كأن يشترط عليه أن لا يحكم إلا بأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة. ومن ذلك إلزام القاضي بالحكم وفق التقنيات الحديثة التي أصدرتها المجالس النيابية في منتصف القرن العشرين فيما يعرف بالقوانين الوضعية، وهي عبارة عن انتقادات فقهية من جملة المذاهب الإسلامية المختلفة، وإن كان أكثرها من المذهب الحنفي.

ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في حكم هذا الاشتراط على القاضي إلى أنه من أهل الاجتهاد، ولا يجوز إلزام المجتهد بغير اجتهاد نفسه، ونجمل آراء الفقهاء في هذه المسألة في مذهبين، كما يلي:

المذهب الأول: يرى عدم جواز الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين لا يتعداه، أو بقانون معين لا يخرج عنه ولو كان هذا القانون من اجتهادات الفقهاء المسلمين، وإذا حدث كان الشرط باطلاً. وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به متقدمو الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

وهل يبطل عقد التولية ببطلان هذا الشرط؟ قولان: ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان عقد التولية لبطلان الشرط فيه. وذهب الحنفية والظاهرية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة عقد

التولية وبطلان الشرط؛ لما أخرجه الشيخان عن عائشة من حديث بريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق".

وحجة أصحاب هذا المذهب في عدم جواز الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين:

(١) عموم قوله تعالى: "فاحكم بين الناس بالحق" (ص: ٢٦). قالوا: والحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب المعين، فكيف يترك القاضي الحق الذي رآه حقاً إلى غيره من الأقوال، فلا بد لصحة القضاء أن يكون موافقاً لرأي القاضي.

(٢) أنه لو جاز للحاكم أن يبتديء الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف، كما نص على ذلك ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" ثم قال: "ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل".

(٣) أن القاضي من أهل الاجتهاد، ويحرم قهر المجتهد على غير اعتقاده، فإن قبل القاضي الاشتراط عليه بأن يحكم بغير مذهبه واجتهاده فقد ارتضى أن يكون مقلداً، ولا يجوز للمجتهد التقليد.

المذهب الثاني: يرى صحة الاشتراط على القاضي أن يحكم بمذهب معين لا يتעדاه، وفي حكمه أن يلتزم القاضي بقانون معين. وهو ما ذهب إليه متأخروا الحنفية، وقد نص عليه ابن عابدين في "حاشيته" عن علمائه فقال في "كتاب الهبة": "ثم من المقرر أن القضاء يتخصص، فإذا أولى

السلطان قاضيًا ليقضي بمذهب أبي حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه، فالتحق فيه بالرعية. نص على ذلك علماؤنا، رحمهم الله تعالى".

وحجتهم: عموم قوله تعالى: "أوفوا بالعقود" (المائدة: ١)، وقوله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا" (الإسراء: ٣٤)، وما أخرجه البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون عند شروطهم"، وأخرجه الدارقطني عن عوف المزني مرفوعا، وبزيادة: "إلا شرطا حرم حلالا أو أحلا حراما". ولأن القضاء عمل فني وليس اجتهدا محضا، وإلزام القضاة بالحكم بالقانون المختار عن دراسة فيه من العدل ما ليس في تفويض القضاة إلى اجتهداتهم المتباينة والمباغته للمتخاصمين.

الرأي المختار: هو ما لا يسع المسلم خلافة، الذي عليه اختيار الدولة؛ عملاً بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، وهو ما ذهب إليه المتأخرون من الحنفية الذين قالوا بجواز تقييد القاضي عند تقليده أن يحكم بمذهب معين، وفي حكمه القانون المعين؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وحتى يتحقق العدل بين الناس بتوحيد القضاء.

المسألة الرابعة

شروط الصلاحية لتولي القضاء

نظراً لأهمية أمر القضاء وعظم خطره فقد وضع الفقهاء عدة ضوابط فيمن يصلح لتوليّه؛ لضمان نزاهته في أداء رسالته، فضلاً عن الحفاظ على هيئته لدى الناس، واختلفوا في عدد تلك الشروط تبعاً لما يراه الفقيه ضابطاً لرسالة القضاء من إقامة العدل، وقبول المتنازعين بالحكم.

والأصل أن يتم اختيار القضاة ممن توفرت فيهم تلك الشروط والضوابط، والتجاوز عنها أو عن بعضها دون تأويل بحاجة انحراف وإساءة يَأْثُمُ فاعلها، فضلاً عما يقوله الماوردي في "الحاوي الكبير" من عدم جواز ولاية القاضي مختل الشروط وعدم نفاذ أحكامه.

وقد اتفق الفقهاء على بعض تلك الشروط، وأهمها: البلوغ، والعقل واعتماد الحاكم تعيينه لأهليته عنده.

واختلفوا في بعضها، ومنها: الإسلام، والذكورة، وسلامة حاستي السمع والبصر، والقدرة على النطق والكلام، والعدالة، ونبين ذلك في العناصر الثلاثة الآتية:

أولاً: تولية المرأة أو غير المسلم القضاء على المسلمين

اختلف الفقهاء على اشتراط الذكورة في القاضي، واشتراط صفة الإسلام فيه.

ويرجع سبب الخلاف في شرط الذكورة في القاضي إلى الاختلاف في إلحاق القضاء بالولاية العامة أو إلحاقه بالعمل الفني كالإفتاء أو الشهادة التي هي إخبار.

ويرجع سبب الخلاف في شرط الإسلام في القاضي إلى الاختلاف في إلحاق القضاء بالولاية أو بالعمل الفني، والاختلاف في وصف غير المسلم بصفة العدل حتى يحكم به، وإلى الاختلاف في إنفاذ حكم غير المسلم إذا عينه سلطان ذو شوكة.

ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في حكم تولية المرأة أو غير المسلم القضاء في المذاهب الأربعة التالية:

المذهب الأول: يرى عدم جواز تولية المرأة أو غير المسلم القضاء مطلقاً، ولا ينفذ حكمهما إن وقع. وهو مذهب الجمهور قال به المالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم:

(١) عموم قوله تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء: ١٤١)، والقضاء من أعظم السبل، فكان ممنوعاً على غير المسلمين للمسلمين. وأيضاً عموم قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" (النساء: ٣٤)، والتعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم، أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكماً على جنس النساء، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة قاضية أو في وظيفة تكون فيها قيمة على الرجل.

يقول ابن كثير في "تفسيره" المُعَبَّر عن رؤيته الفقهية: "أي الرَّجُل قِيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم".

(٢) عموم ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وهذا في حق بنت كسرى، وغيرها من باب القياس.

(٣) أن غير المسلم لا يعرف أحكام الحلال والحرام في الإسلام فكيف يكون قاضيًا على المسلمين الذين يتحاكمون إلى كتاب الله. كما أن المرأة ناقصة عقل عن الرجل، مع احتياج القاضي لحضور محافل الخصوم والرجال للبحث عن كمال الرأي ومشاورة أهل العلم، فلم تصلح للقضاء.

ويدل على نقص عقل المرأة عموم قوله تعالى: "أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى" (البقرة: ٢٨٢)، وما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن - زاد مسلم: وأكثرن الاستغفار - فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟" قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها".

(٤) أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، ولا عن حاكم بعدهم أنه قلّد المرأة القضاء فيما بلغنا - كما يقول ابن قدامة في "المغني"، وهذا دليل على عدم صلاحيتها للقضاء.

المذهب الثاني: يرى عدم جواز تولية غير المسلم القضاء على المسلمين، ويجوز أن تلي المرأة القضاء فيما يجوز أن تقبل شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال كما في أقضية الأموال والعقود. أما أقضية الحدود والقصاص فلا يجوز تولية المرأة فيها؛ لأن شهادتها لا تقبل في ذلك. وهو مذهب الحنفية.

وحجتهم: أن الشهادة فرع عن القضاء، وفيها معنى الولاية، فوجب إلحاقها به، فكل من جازت شهادته جاز قضاؤه، والعكس فكل من بطلت شهادته لم يصلح توليته القضاء. وغير المسلم لا تجوز شهادته على مسلم عند جمهور الفقهاء، والمرأة لا تجوز شهادتها في الحدود والقصاص وتجاوز في غيرها، فكذا القضاء.

المذهب الثالث: يرى عدم جواز تولية غير المسلم القضاء على المسلم مطلقاً، ويجوز أن تتولى المرأة القضاء في كل شيء، حتى الحدود والقصاص. وهو قول ابن جرير الطبري (٢٢٤-٣١٠هـ)، وإليه ذهب الظاهرية ونصره ابن حزم في "المحلى" (٣٨٤-٤٥٦هـ).

وحجتهم:

(١) عموم قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" (النساء: ١٤١)، فهذا يمنع بظاهرة تعيين غير المسلم قاضياً.

(٢) عموم ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، وهذا أصل في صحّة ولاية المرأة كصحّة ولاية الرّجل.

(٣) ما حكاه ابن حزم في "المحلى" أن عمر بن الخطاب وليّ الشّفاء - امرأة من قومه - السوق، وولاية السوق من الولايات العامة.

(٤) أن قوامة الرجال تعني مسئوليتهم وخدمتهم وحمايتهم على مصالح النساء، كما ذكر ذلك الزجاج في "إعراب القرآن"، ولا تعني سيادتهم أو رئاستهم أو تسلّطهم على النساء، كما يرى ابن كثير؛ فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النساء شقائق الرجال".

(٥) أن حديث أبي بكرة "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" محمول على الخلافة العظمى التي تجمع كلّ السلطات التّشريعية والتنفيذية والقضائية، أو محمول على التّواكل بتفويض الغير - امرأة أو رجلاً - في إدارة الشؤون المشتركة دون مشاركة، أو أن الحديث خاص ببنت كسرى؛ لأنّ أباهما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه، يدعوه فيه إلى الإسلام، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق مملكه.

المذهب الرابع: يرى جواز تولية غير المسلم أو المرأة القضاء، إن ولأهما سلطان ذو شوكة، وينفذ قضاؤهما. وهو قول بعض الشافعية كما حكاه الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"، والشربيني الخطيب في "مغني المحتاج".

وحجتهم:

(١) أن السلطان من أهل الاجتهاد، فله أن يُنشئ رأياً فقهياً غير مسبوق، مع عموم الأدلة الآمرة بالسمع والطاعة له، ومنها قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" (النساء: ٥٩)، وما أخرجه الشيخان عن عبادة بن الصامت، قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".

(٢) أن منع تعيين القضاة من المؤهلين علمياً لكونهم من النساء أو من غير المسلمين ظلم، ونوع من العنصرية المقيتة والعصبية المنهي عنها، وفيه تعطيل للمصالح وضياح للحقوق؛ على خلاف ما قام عليه الدين من إقامة العدل، وجلب المصالح ودرء المفاسد؛ خاصة أن جميع القضاة في الدولة الحديثة يحكمون بالقانون سابق الدراسة، بتوافق مجتمعي، ويدرس هذا القانون المسلم وغيره، والرجل والمرأة، ويتم الاختيار للعمل القضائي من بين المتفوقين في دراسة القانون، فلا وجه لاشتراط صفة الإسلام أو الذكورة بعد في العمل القضائي.

الرأي المختار: الالتزام بما لا يسع المسلم خلافه، من طاعة ولي الأمر فيما له من حق الاجتهاد؛ للقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، فضلاً عن مراعاة المصلحة المرسلّة التي تدور في الزمان والمكان والحال، وفي ظل الدولة الحديثة التي تقوم على المواطنة بدستور يسوّي بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة.

وعلى هذا، فإن القول بصحة تولية الدولة مواطنيها من غير المسلمين، أو من النساء القضاء، الذي قال به بعض الشافعية، هو القول الذي لا يجوز الافتتات عليه؛ لمنع الفوضى على النظام العام، فقد أخرج الشيخان من حديث عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على أصحابه "بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وفي أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".

ونذكر فيما يلي أسباب ترجيح القول بصحة تولية المؤهلين علمياً القضاء من غير المسلمين ومن النساء:

(١) أن الاستدلال على منع غير المسلمين المؤهلين علمياً القضاء بعموم قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً" (النساء: ١٤١) خارج عن محل النزاع، بحسب سياق الآية الكريمة الواردة في شأن الآخرة وليس في شؤون الحياة الدنيا، كما يقول سبحانه: "قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء: ١٤١).

كما أن مقصد القضاء هو إقامة العدل بإنفاذ الحكم المتفق عليه سلفاً فيما يُعرف بالقانون، ولا يشترط لتحقيقه صفة الإسلام أو الذكورة، فالعدل صفة

إنسانية فطرية وليست صفة تُمنح للرجال دون النساء، أو لمن أعلن إسلامه دون أن تكون داخلته الإنسانية عادلة؛ لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"، ولذلك فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة العدل لبعض غير المسلمين، فيما أخرجه ابن هشام في "سيرته" عن ابن إسحاق أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية بمكانه من الله تعالى ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه". كما أذن القرآن الكريم في قبول شهادة غير المسلمين في وصايا المسلمين، ووصفهم بأنهم أهل عدل، كما قال سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ" (المائدة: ١٠٦).

وإذا كان فقهاء الحنفية يرتبون القضاء على الشهادة فإن شهادة النساء مقبولة بالإجماع في الجملة، كما أن غير المسلمين لهم الحق في الشهادة على الوصية في السفر عند الحنابلة في المشهور والقديم عند الشافعية ومذهب الظاهرية، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى تعميم ذلك في الوصية وفي غيرها من العقود والتصرفات، وفي السفر وفي الحضر على السواء بحسب الحاجة.

كل هذا يظهر رجحان اختيار القول الفقهي بجواز اتخاذ القضاة من النساء ومن غير المسلمين؛ خاصة وأن القضاء قد صار وظيفة محددة بقوانين ملزمة تخضع للتفتيش والاستئناف والنقض، فلم يعد للقاضي سلطة تقديرية كالتى كانت قبل سلطان القانون، الذي يدرسه المسلمون وغيرهم والرجال والنساء على السواء، فإذا قلنا إن للقضاة ولاية فإن تلك الولاية ترجع إلى القانون ولا ترجع إلى شخص القاضي.

(٢) أن صحة تعيين القضاة من النساء هو قول بعض كبار الفقهاء الذين يجوز اتّباعهم، منهم ابن جرير الطبري وبعض الشافعية ومذهب الظاهرية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأي أم سلمة، ولم يصفه بالنقصان، فيما أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صلح الحديبية: "قوموا فأنحروا، ثم احلقوا، فما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلم يقم منهم أحد، ثم دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُذْنك، وتدعو حالقك فيحلقك، ففعل، وفعل أصحابه من بعده. كما أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النساء شقائق الرجال".

ثانياً: تولية فاقد بعض الحواس القضاء

نتكلم عن تولية فاقد بعض الحواس القضاء، في العناصر الأربعة الآتية:

(١) التعريف بسلامة الحواس:

الحواس في اللغة هي: مشاعر الإنسان كالعين والأنف واللسان واليد، وحواس الإنسان: المشاعر الخمس وهي: الطعم والشم والبصر والسمع واللمس، وحواس الأرض خمس وهي: البرد والبرد والريح والجراد والمواشي.

والحس والحسيس: الصوت الخفي، قال تعالى: "لَا يَسْمَعُونَ حَسِيئَهَا" (الأنبياء: ١٠٢)، وأيضًا الحركة وفي الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "جزء أحاديث أبي الزبير" أنه كان في مسجد الخيف فسمع حس حية - أي حركتها وصوت مشيها - فقال: "اقتلوا اقتلوا". ومنه الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم"، أي شديد الحس والإدراك.

والحس - بكسر الحاء - من أحسست بالشيء، حس بالشيء يحس حسًا وحسًا وحسيًا، وأحس به وأحسّه: شعر به.

والمقصود بسلامة الحواس عند الفقهاء: سلامة الجسم في السمع والبصر والنطق.

هذا، وقد اكتفى الكاساني الحنفي بذكر سلامة الجسم في البصر والنطق؛ لأن النطق يتضمن سلامة السمع، فالذي يتكلم يسمع، إلا أن يكون قد طرأ عليه الصمم بعد أن تكلم، وهذه أحوال مرضية نادرة، ولا حكم للنادر.

وقد اقتصر الفقهاء في سلامة الحواس للقاضي على سلامة السمع والبصر والنطق؛ لمسيس الحاجة إليها في إقامة العدل بين الناس.

أما سلامة سائر أعضاء الجسم في غير تلك الحواس الثلاث، كسلامة الأذنين واليدين والرجلين، فإنما تعتبر استحباباً لا لزوماً؛ لأن السلامة من الآفات الشكليّة أهيب لذوي الولايات.

والهيئة في ولاية القضاء مستحبة لا مستحقة؛ لأن المقصود أن يكون القاضي قادراً على مهام وظيفته، وهو يقدر على ذلك بالسمع والبصر والكلام، لا بسلامة أذنيه ويديه ورجليه، وإن كانت السلامة في تلك الأعضاء تضيف عليه كمالاً وجمالاً وهيبة.

(٢) اشتراط سلامة الحواس في القاضي

إن اجتماع فقْد البصر والسمع والكلام يحول دون القيام بمهام القضاء، مما يوجب عدم صلاحية من اجتمع فيه هذا الفقْد من تولي القضاء إلا أن ينجح الطب في اكتشاف بدائل لتلك الحواس تُحقق مقصودها.

أما إذا فقِدَت حاسة واحدة من البصر أو السمع أو الكلام فقد اختلف الفقهاء في حكم تولية القضاء مع هذا الفقْد لإحدى تلك الحواس، ونبين ذلك فيما يلي.

(٣) فقْد حاسة البصر في القاضي

اختلف الفقهاء في اشتراط سلامة حاسة البصر لصلاحية تولي القضاء، وما يترتب عليه من تولية الكفيف القضاء، على مذهبين:

المذهب الأول: يرى اشتراط سلامة حاسة البصر في القاضي حتى يصلح لتولية القضاء، وإن طرأ عليه العمى بطلت ولايته. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في قول، والشافعية في الأصح والحنابلة.

وحجتهم: أن كفيف البصر لا يفرّق بين الطالب وبين المطلوب، ولا يعرف المقر من المقر له، ولا الشاهد من المشهود له؛ خاصة مع أهل المكر من الخصوم، والأصل في القاضي أن يفرق بين هؤلاء، ويعرفهم حتى يقع حكمه مطابقاً للواقع ما أمكن.

وأجيب عن ذلك: بأن كفيف البصر يستطيع أن يفرق بين الطالب وبين المطلوب، كما يستطيع التعرف على كلّ من المقر والمقر له، والشاهد والمشهود عليه بالأصوات، أو بالاستعانة بمستشار مؤتمن.

المذهب الثاني: يرى عدم اشتراط سلامة البصر لصلاحية تولي القضاء، فتصح تولية كفيف البصر، كما ينفذ حكمه. وهو مذهب المالكية في المشهور، والظاهرية والإمامية وبعض الشافعية.

وقال بعض المالكية: إن البصر ليس شرطاً في جواز ولاية القاضي، إنما هو شرط في استمرار ولايته، بمعنى أنه يجب عزل مَنْ طرأ عليه العمى، وإلى حين يتم عزله فإن حكمه ينفذ.

وحجتهم: أن شعبياً - عليه السلام - كان أعمى، كما أن كفيف البصر تصح إمامته حيث استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم إماماً في الصلاة على المدينة المنورة وكان أعمى، وإذا صحت إمامته

صحت توليته للقضاء، ثم إن شهادة الأعمى مقبولة عند كثير من الفقهاء، فذلك ولايته للقضاء قياساً.

أجاب ابن قدامة في "المغني" عن الادعاء بأن شعيباً - عليه السلام - كان أعمى بأنه غير صحيح؛ إذ لم يثبت أنه - عليه السلام - كان أعمى، ولو ثبت فيه ذلك فلا يلزم هنا، فإن شعيباً - عليه السلام - كان من آمن معه من الناس قليلاً، وربما لا يحتاجون إلى حكم بينهم لقلتهم وتناصفهم، فلا يكون حجة في مسائلتنا.

ثم إن شرع من قبلنا مختلف في كونه شرعاً لنا أم لا، ولا يجوز الاستدلال بمحل خلاف.

والجواب عن إمامة ابن أم مكتوم: أن تلك الإمامة في الصلاة، فتجوز لعدم احتياج الإمام إلى رؤية المأمومين، بخلاف القاضي الذي يحتاج إلى ذلك للتفريق بين المدعي وبين المدعى عليه.

وقيل إن خبر استخلاف ابن أم مكتوم في الإمامة في المدينة المنورة خبر ضعيف لا يحتج به.

الرأي المختار: هو ما لا يسع المسلم خلافه من عدم الافتئات على ولي الأمر؛ لأنه من أهل الاجتهاد، وعملاً بالقاعدة الفقهية: "حكم الحاكم يقطع الخلاف"، وقد وضع ولاية الأمور ضوابط العمل القضائي، وشروط صلاحية توليه، بما يضمن إقامة العدالة، ويراعي المصالح المرسلة، والتطور الحضاري في حقوق الإنسان.

(٤) فقد حاسة السمع في القاضي

اختلف الفقهاء في اشتراط سلامة السمع في القاضي، وما يترتب على ذلك من تولية الأصم الأخرس للقضاء، على مذهبين:

المذهب الأول: يرى اشتراط سلامة السمع في القاضي حتى تصح توليته، وإن طرأ عليه الصمم بطلت ولايته. وهو مذهب جمهور الفقهاء، ذهب إليه الحنفية والشافعية في المعتمد والحنابلة.

وحجتهم: أن الأصم لا يستطيع التفريق بين الإقرار وبين الإنكار، ليميز الحق من الباطل، ويعرف المحق من المبطل، فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي"، قال علي: فما زلت قاضياً بعد.

المذهب الثاني: يرى عدم اشتراط سلامة السمع في القاضي، فتصح ولاية الأبكم، وإن كان الأولى اختيار صحيح السمع، وإن طرأ الصمم على القاضي لم تبطل ولايته، وتنفذ أحكامه حتى يعزل.

وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية في وجه، والظاهرية، والإمامية.

وحجتهم: صحة إمامة الأصم في الصلاة، فتصح ولايته للقضاء؛ قياساً. **الرأي المختار:** ليس له محل؛ لمنع الافتئات على ولي الأمر، بعد أن وضعت الدولة ضوابط العمل القضائي بما يضمن صلاحية الاختيار ونزاهته، ويراعي المصالح المرسلة في حقوق الإنسان.

ثالثاً: تولية فاقد العدالة القضاء

اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة لصحة ولاية القضاء، وما يترتب على ذلك من ولاية الفاسق، وذلك على مذهبين:

المذهب الأول: يرى أن العدالة شرط في صحة تولي القضاء واستمراره، فلا تصح ولاية الفاسق، وينفذ حكمه إلى حين عزله، حتى لا تتعطل مصالح الناس. وهو قول جمهور الفقهاء، الحنفية في قول، والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.

وحجتهم: أن القضاء حارس للعدالة، وفاقد الشيء لا يعطيه، مع عموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (الحجرات: ٦).

ويرى بعض المالكية في وجه صححه القاضي عياض: بطلان حكم القاضي الفاسق، فلا ينفذ حكمه، فيقول عياض في "كتاب الأقضية"، من كتابه "التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة": "وأما الفاسق ففيه خلاف بين أصحابنا، هل يُردُّ ما حكم فيه، وإن وافق الحق؟ وهو الصحيح، أم يمضي إذا وافق الحق، ووجه الحكم؟".

المذهب الثاني: يرى أن العدالة ليست شرطاً في صحة تولية القاضي، فتصح ولاية الفاسق في القضاء، وينفذ حكمه. وهو رأي الحنفية في الأصح عندهم.

وحجتهم: طاعة ولي الأمر الذي عيّنه، فولّي الأمر من أهل الاجتهاد، وطاعته واجبة. وقياساً للقضاء على الشهادة، فهي عند الحنفية تصحُّ من الفاسق، وإن كان تقليد الفاسق للقضاء خلاف الأولى، وقيل إنه محظور

يأثم فاعله، وقيل: إن تقليد الفاسق ابتداءً يصح، فلو قُلد وهو عدل ينعزل بالفسق.

الرأي المختار: ليس له محل؛ لمنع الافتئات على ولي الأمر، بعد أن وضعت الدولة ضوابط العمل القضائي بما يضمن صلاحية الاختيار ونزاهته، وتتبع السيرة الذاتية للمرشحين للقضاء، ومتابعة مسيرتهم المهنية والمجتمعية اللائقة التي ترفعهم فوق مستوى الشبهات، وليس على آحاد الناس إلا الإبلاغ الرسمي عن أي تجاوز يراه مخلًا بمكانة القضاء الجليل المهيب.

المسألة الخامسة

تأثير الأحكام القضائية الحقوقية على الأحكام الديانية

هذه مسألة خطيرة في الفقه، تبحث عن تكييف أو وضع الحكم القضائي الحقوقي في ميزان الدين، فكما وقع الخلاف في تكييف الحكم الإفتائي هل هو من إنشاء المفتي باجتهاده وفهمه لخطاب الشرع، أو هو من اكتشاف المفتي لمراد الله تعالى من خطابه.

وقع - أيضًا - الخلاف في الحكم القضائي الحقوقي، وهو الصادر بحق آدمي يتعلق بمال، أو شفعة، أو استحقاق وظيفة، أو العزل منها، أو

زواج، أو طلاق، أو نحو ذلك، هل هو منشيء للحق بسلطة القاضي في إصدار الأحكام فلا يوصف حكمه بخطأ أو صواب، أو هو كاشف عن الحق الذي هو في علم الله بشهادة الشهود أو باجتهاد القاضي، فيوصف حكمه بخطأ أو صواب؟

إن القاضي عندما يحكم أو يفصل في النزاع يعتمد على أحد أمرين. الأول: الأدلة مثل الأوراق الثبوتية وشهادة الشهود، وغير ذلك. والثاني: قناعته بتلك الأدلة، واجتهاده في المسائل التي يجوز له الاجتهاد فيها.

ومن المحتمل أن يكون الشهود كاذبين أو مُزوّرين، كما يحتمل أن يكون اجتهاد القاضي غير مصيب، أو أن اختياره الفقهي أو المذهبي مخالف لاختيار الخصوم الفقهي أو المذهبي.

إنه من الواجب في جميع الأحوال إنفاذ حكم القاضي؛ حسماً لمادة النزاع، ولكن بالنسبة للخصوم المحكوم لهم أو عليهم هل يستحلون حكم القاضي ديانة، وهم يعلمون زور الشهادة، أو اعتماد القاضي في حكمه على رأي فقهي يرونه فاسداً، ومخالفاً لمذهبهم الفقهي؟ أم يكون حكم القاضي المبني على شهادة الزور التي يعلمها المحكوم له، أو المبني على رأي فقهي مخالف لمذهب المحكوم له باطلاً، ويحرم عليه استحلال ما حكم له به؟

هذه هي مسألة تأثير الحكم القضائي الذي يعتمد الظاهر التعاقدى على الحكم الدياني الذي يعتمد الباطن الاعتقادي، وهي مسألة مترتبة على مسألة تكييف الحكم القضائي فقهيًا، وهذا التكييف متردد بين فقهاء:

الفقه الأول: أن الحكم القضائي كاشفٌ عن الحق الذي هو في علم الله، فيخطئ ويصيب، وليس للمحكوم له استحلال المحكوم به المبني على شهادة زور يعلمها، أو خطأ القاضي بسبب اعتماده على مذهب فقهيٍّ مخالف لمذهب الخصوم أو أحدهم.

الفقه الثاني: أن الحكم القضائي مُنشئٌ للحق الذي حَكَمَ به، كما أن المُتعاملين ينشئون الحقوق بعقودهم، وهذه العقود تُرتَّب أثرها، وإن قامت على شهادة زور، أو بفقه أحد الطرفين المخالف لفقه الآخر الذي يعتقد فساد فتوى صاحبه، فالعقد يجبُ ذلك، كذلك حكم القاضي يُنشئ الحقَّ بمنطوقه، فيجبُ زور الشهادة، ويجبُ اختلاف مذهب القاضي الفقهي عن مذهب الخصوم الفقهي، وإن اعتقدوا فساد فقهِه، وبهذا ينفذ حكم القاضي ديانة في إطار ضوابط دين كلِّ أحد على نفسه.

وقد تناول الفقهاء مسألة تكييف الحكم القضائي، وما يترتب عليه من أثر ديانِي، بتفريقهم بين الحكم القضائي الصَّادر عن أدلة كاذبة، وبين الحكم القضائي الصَّادر عن اجتهاد يراه المحكوم له باطلاً، ونوضح هذين النوعين فيما يلي:

النوع الأول: الأحكام القضائية الحقوقية المبنية على الأدلة الكاذبة

الأحكام المثبتة للحقوق، والمَبْنِيَّة على أدلة تتعلق بالعقود أو بالفسوخ مثل أن يصدر حكم قضائي بطلاق أو بزواج أو بيع أو بفسخ عقد إجارة مستندًا إلى شهادة الزور، والقاضي حسن النية لا يعرف أنها شهادة زور، فإذا صدر الحكم النهائي - بإجراءات سليمة - حتى لم يعد قابلاً للنقض، فهل يكون هذا الحكم نافذًا ديانة وقضاءً، أم يكون نافذًا في الظاهر - أي

بسلطان القضاء - لا باطنًا - أي في حكم الدين والإعتقاد والأخلاق -
عند أصحاب الشأن العالمين بالحقيقة المخالفة للحكم؟ مذهبان للفقهاء:

المذهب الأول: يرى أن حكم القاضي كاشف عن الحقيقة التي هي في علم الله، فهو لا يُنشئ حقوقًا، ولا يُحلُّ حرامًا ولا يحرم حلالًا، فلو صدر الحكم بشهادة زور كاذبة كان باطلًا عند ذوي الشأن العالمين بها، وعليهم الانتصاف من أنفسهم بما يرضي الله، ويحرم على من يعلم كذب الشهادة التي اعتمد عليها القاضي في حكمه استحلال المحكوم به. وهو قول جمهور الفقهاء، ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأصحاب أبي حنيفة الثلاثة أبو يوسف ومحمد وزفر.

وحجتهم: أن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر التي يعلمها شاهد الزور، فقد أخرج الشيخان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

المذهب الثاني: يرى أن حكم القاضي مُنشئ للحقوق الآدمية، وليس كاشفًا للحق الذي هو عند الله، فمنطوق الحكم القضائي كمنطوق الصيغة في إبرام العقود، فينفذ هذا الحكم الصادر، ولو بشهادة الزور ظاهرًا وباطنًا، أي قضاءً وديانةً. فإذا كان الحكم بالطلاق فعلى الزوجين الانفصال ديانة، وإذا كان الحكم بالزواج فللزوجة اللقاء إلا أن يوجد مانع ديني كمحرمة بينهما. وهو قول الشعبي ت ١٠٣هـ، وأبي حنيفة ت ١٥٠هـ.

وحجتهم: أن حكم الحاكم حجة شرعية منشئة للعقود والفسوخ؛ لأن القضاء شرع لقطع المنازعة بين المتخاصمين من كل وجه، فلو لم ينفذ باطنًا كان تمهيد للمنازعة بينهما، وقد عهدنا نفوذ مثل ذلك في الشرع. ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنًا وأحدهما كاذب بيقين.

ويؤيد هذا ما ذكره الزيلعي في "تبيين الحقائق" وغيره من فقهاء الحنفية في كتبهم، كما أورده ابن قدامة الحنبلي في "المغني"، أنه روي عن علي بن أبي طالب أن رجلاً ادعى عنده أن هذه زوجته، وشهد الشاهدان عليها، فقضى بصحة الزواج، فقالت المرأة: إني أعلم أن هذا الرجل كاذب فقضيت به، فأنكحني به يا أمير المؤمنين كي لا يآثم في وقاعه، فقال علي: "شاهداك زوّجاك".

وفي رواية: أن الرجل تقدم لهذه المرأة فأبّت فادعى عليها عند علي ابن أبي طالب أنه تزوجها، وأتى بالشاهدين زوراً، فقضى علي بشهادتهما، فقالت المرأة: إن كان ولا بد فزوجني منه، فقال لها علي: "شاهداك زوّجاك".

كما استشهد أبو حنيفة بقصة هلال بن أمية في صحيح مسلم، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هلال وبين امرأته باللعان وقال: "أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً قضى العيين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء"، قال أنس: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين - أي على الوصف المكروه - وتبين الأمر على ما قال هلال، وأن الفرقة لم تكن موجودة، ومع ذلك لم يفسخ تلك الفرقة وأمضاها.

قال أبو حنيفة: ويستثنى من ذلك إذا قضى بنكاح أخت المقضي له، أو ذات محرم فلا تحل لفوات قبول المحل للنكاح بالمحرمية.

اعترض على أبي حنيفة بما يلي:

(١) أن حكم القاضي ليس سبباً لإنشاء الحقوق، وإنما هو كاشف عن علم الله فيها، وقد يخطئ القاضي وقد يصيب في هذا الكشف، وكثيراً ما يعلمه الخصم الجاحد.

(٢) أن أثر الإمام علي: "شاهداك زَوْجَاكِ" أورده فقهاء الحنفية في كتبهم. وقال ابن قدامة في "المغني": "أما الخبر عن علي إن صحَّ فلا حجة لهم فيه؛ لأنه أضاف التَّزْوِيجَ إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يجْهأ إلى التزويج لأن فيه طعنًا على الشهود". وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير": "إنه ليس له سند يعرف. وعلى التسليم بصحته فهو لا يزيد عن كونه مذهب صحابي".

(٣) أن الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج بدليل أنه لو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه، وإنما كانت بسبب أنهما وصلا إلى أسوأ الأحوال من المقابحة من التلاعن، فلم يرَ الشارع اجتماعهما بعد ذلك.

الرأي المختار: يمكن الوصول إليه بحسب قوة الأدلة، ومآلات الاختيار على شيوع شهادة الزور في حال استحلال الحقوق، أو شيوع الاستهانة بالأحكام القضائية في حال ادّعاء كذب الأدلة وزورها. كما يمكن الجمع بين المذهبين باعتماد حجّة الأحكام القضائية الحقوقية، ولكن يجب على المحكوم له التنازل عن المحكوم به في حال مساسه بحق الغير، كالحكم

بصحة عقد زواج بشهادة زور بدون رضا الطرفين، فإن لم يرض أحدهما بالحكم فلا يحلُّ للطرف الآخر الذي يرى الحكم في صالحه أن يحتجَّ به ديانةً.

النوع الثاني: الأحكام القضائية الحقوقية المبنية على اجتهاد القاضي الذي يراه المحكوم له فاسدًا

ذكر الفقهاء من أمثلة ذلك قبل عصر تدوين القوانين: القضاء بالشفعة للجار، وهذه الشفعة أجازها الحنفية؛ لما أخرجه النسائي وصححه ابن حبان، وله علة، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جار الدار أحق بالدار". وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت الشفعة للجار؛ لعدم الضرر بسبب قسمة الحدود، وأن الشفعة إنما تكون في الملك المشاع وليس في المقسم؛ لما أخرجه الشيخان - واللفظ للبخاري - عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة في كلِّ شرك في أرض أو رُبْع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".

فإذا اجتهد القاضي وحكم بالشفعة للجار وكان هذا الجار لا يعترف بهذه الشفعة على مذهب الجمهور، فهل يجوز له ديانةً استحلال الشفعة بالجوار؛ لأن القاضي حكم له بها؟ أم يحرم عليه العمل بحكم قضائي مبنيٍّ بفتوى تخالف معتقده الفقهي؟.

ومثال آخر: القاضي الحنفي الذي قضى بصحة الزواج إذا زوجت المرأة الرشيدة نفسها من زوج كفاء، وكان هذا الزوج مالكي المذهب أو شافعي المذهب أو حنبلي المذهب أو ظاهري المذهب يرى بطلان هذا الزواج لعدم وجود ولي من الرجال للمرأة، فهل يجوز له استحلال هذا الزواج بقضاء القاضي؟ مذهبان:

المذهب الأول: يرى أن تلك الأحكام القضائية الحقوقية الصادرة بمذهب القاضي واجتهاده، على خلاف مذهب الخصوم، منشئة للحق المحكوم به، فتتخذ في الظاهر والباطن، أي قضاءً وديانةً، ولا توصف بخطأ أو صواب، فهي أسباب شرعية لموضوعها، وليس من حق الخصوم أو بعضهم أن يحكم ببطلانها بزعم مخالفتها مذهب الفقهي. وهو قول جمهور الفقهاء، الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة.

وحجتهم: أن هذه الأحكام الحقوقية مبنية على حق القاضي في الاجتهاد فيها، ولا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله.

المذهب الثاني: يرى أن هذا الحكم القضائي الحقوقي المخالف لمذهب الخصوم الفقهي لا يلزمهم، فلا ينفذ باطنًا أي ديانةً، ولا يستحل المحكوم له المحكوم به على خلاف مذهب المعتدي. وهو قول بعض الشافعية منهم أبو إسحاق الإسفراييني ت ٤١٨هـ، وأبو حامد الغزالي ت ٥٠٥هـ. وذهب بعض آخر من الشافعية إلى أنه لا ينفذ باطنًا في حق العلماء وينفذ باطنًا في حق العامة.

وحجتهم: أن المحكوم له من أهل الاجتهاد، أو من أهل الالتزام بفتوى معينة، ويرأها الحق، وما عداها باطل، فلا يستحل شيئاً يعتقد بطلان فقهه.

الرأي المختار: تم الاستغناء عنه في ظل قضاء الدولة الحديثة التي يتحاكم أهلها إلى قانون سابق الدراسة والتوافق عليه، ومع ذلك فإن الدستور الذي تنبثق منه القوانين يكفل حرية الاعتقاد، وعدم إلزام أحد بقبول حقٍ يراه حراماً عنده، فمن قُضي له بحقٍ يخالف مذهب الفقهي فله أن يتركه، ولكن إن كان الحكم عليه لصالح غيره فلا يسعه إلا الامتناع، وليس من حقّه أن يدّعي مخالفة الحكم لمذهبه؛ حتى لا تضيع حقوق الآخرين.

المبحث الثالث

التعريف بالتحكيم وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة

نتكلم في هذا المبحث عن تعريف التحكيم، وبيان أحكامه الفقهية العامة في المسائل الأربع الآتية:

المسألة الأولى

تعريف التحكيم وبيان أنواعه وأهميته وحكمه الفقهي

نتكلم عن تعريف التحكيم وبيان أنواعه وأهميته وحكمه الفقهي في العناصر الأربع الآتية:

أولاً: تعريف التحكيم في اللغة وفي الإصلاح

التَّحْكِيمُ في اللغة: هو تفويض الحكم إلى الغير، فيكون حَكَمًا. والتَّحْكِيمُ مصدر حَكَمَ تحكيمًا فهو مُحَكَّمٌ وحَكَمٌ. ومن معاني التَّحْكِيمِ في اللغة - أيضًا - القضاء في الأمر والشَّيْء. تقول: حَكَّمُوهُ بينهم، أي أَمَرُوهُ أَنْ يحكم. ويقال: حَكَّمْتُهُ في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه، واحتكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه. والمحاكمة: المخاصة إلى الحاكم، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى واحد.

والتحكيم في اصطلاح الفقهاء: هو تولية الخصمين حَكَمًا - أو أكثر - ليس قاضيًا؛ ليحكم بينهما.

وفي مجلة الأحكام العدلية: "التَّحْكِيمُ هو اتِّخَاذُ الخصمين حاكمًا برضاهما لفصل خصومتها ودعواهما".

ثانيًا: أنواع التَّحْكِيمِ

للتحكيم نوعان، كما يلي:

(١) تحكيم قضائي: الذي يكون بطلب القاضي إذا رآه، ويكون قرار المُحَكِّمِينَ استشاريًا بالنسبة للقاضي؛ لأن الحكم له.

(٢) تحكيم عرفي أو أهلي: الذي يكون باختبار أطراف الخصومة بعيدًا عن ساحة القضاء.

وعند اطلاق مصطلح التحكيم فيكون المراد غالبًا هو التحكيم العرفي؛ لأن التحكيم القضائي يدخل في حيثيات الحكم القضائي.

ثالثًا: أهمية التحكيم

تختلف أهمية التحكيم باختلاف نوعه، كما نوضحه فيما يلي:

(١) التحكيم القضائي: يفيد دراسة القضية بدقة، وعرضها على القاضي، فهو خدمة للقاضي في فهم أعمق للقضية.

(٢) التحكيم العرفي: ينهي الفصل في الخصومات سريعاً بدون تعطيل إجراءات التقاضي الرسمي، ويتحقق به تراضي الأطراف غالباً، فهو قضاء ضامن لإنهاء الخصومة إن تم على وجهه الصحيح؛ لأنه وقع باختيار الخصمين، كما أنه قضاء ضامن لخروج الخصمين متصالحين أو على الأقل بدون عداوة غالباً؛ لأن المحكم يجمع بين أطراف الخصومة على مائدة واحدة؛ فقد أخرج البيهقي في "سننه الكبرى"، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"، أن عمر بن الخطاب قال: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن". وفي لفظ: "يورث الضغائن بين الناس".

ومع تلك الأهمية للتحكيم العرفي إلا أن خطورته تكمن في العزوف عن القضاء الرسمي، وربما يكون ذلك فقدًا للثقة، أو احتجاجاً على طول أمده بما يوقع الفتنة بين الشعب وبين السلطة القضائية. ومع ذلك فإن التحكيم يُخفف التزاحم على القضاء الرسمي، ويبقى قضاءً عرفياً وليس رسمياً، فقد يحتمل المحاباة لأحد طرفي الخصومة، كما يحتمل مخاطرة اعتراض أحد الخصمين على نتيجته؛ ليطمسك بحقه في الرجوع إلى القضاء الرسمي.

رابعاً: حكم التَّحْكِيمِ الفقهِي

اختلف الفقهاء في مشروعية التحكيم العرفي على مذهبين:

المذهب الأول: يرى عد مشروعية التحكيم العرفي. وهو قول بعض الحنفية وعليه الفتوى عندهم، وإليه ذهب بعض الشافعية، وذهب بعضهم إلى جوازه إذا لم يكن في البلد قاض. وحجتهم: أنه يخشى من التحكيم ترك القضاء بعلمه واجتهاده، إلى تحكيم العوام والجهلة بغير الحق والعدل.

المذهب الثاني: يرى مشروعية التحكيم العرفي في الجملة، وأنه لا يزاحم القضاء الرسمي؛ لأن القضاء الرسمي مقصود لفض الخصومات وليس مقصودًا لذاته. وهو قول جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم.

وحجتهم: الكتاب والسنة والمعقول:

(١) دليل الكتاب: عموم قوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير" (النساء: ١٢٨)، وعموم قوله تعالى: "وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما" (النساء: ٣٥). قال القرطبي ت ٦٧١ هـ في "تفسيره": "هذه الآية دليل إثبات التحكيم".

(٢) دليل السنة: أحاديث كثيرة، منها عموم ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ في أمر اليهود من بني

قريظة بعد خيانتهم في الأحزاب، وهم كانوا قد رضوا بالنزول على تحكيمه، ولما قضى فيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حكمت فيهم بحكم الله يا سعد".

وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد حسن، أن أبا شريح هانيء بن يزيد - رضي الله عنه - لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، سمعهم يكتفون بأبي الحكم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكني أبا الحكم؟". فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضى كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟" قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: "فما أكبرهم؟" قلت: شريح، قال: "أنت أبو شريح. ودعا له ولولده".

ومن المعروف أن أبا جهل كان يكنى بأبي الحكم، فقد أخرج الحاكم وصححه عن عباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه، قال: كنت يوماً في المسجد، فأقبل أبوجهل فقال: إن لله عليّ إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته، فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل، فخرج غضباً حتى جاء المسجد، فعجل قبل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط، فقلت: هذا يوم الشر، فاتزرت ثم اتبعته، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: "اقرأ باسم ربك الذي خلق"، فلما بلغ شأن أبي جهل: "كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى" (العلق: ٦-٧)، قال إنسان لأبي جهل: يا أبا الحكم هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو جهل: ألا ترون ما أرى، والله

لقد سد أفق السماء علي، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد.

(٣) دليل المعقول: أن التحكيم يحقق مقاصد في فض الخصومات بالتراضي، فهو نحو من الصلح، وكما قال تعالى: "والصلح خير" (النساء: ١٢٨).

ولا يخشى من التحكيم الحكم بغير ما أنزل الله أو تحكيم الجهلة؛ لأن التحكيم يكون بالتراضي غالبًا، والتراضي هو حكم الله في المعاملات في الجملة؛ لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" (النساء: ٢٩).

وقد وقع التحكيم بين بعض كبار الصحابة دون نكير، ومن ذلك ما حكاه ابن نجيم في "البحر الرائق"، والكمال بن الهمام في "شرح فتح القدير"، أنه كان بين عمر وأبي بن كعب منازعة في نخل، فحكما بينهما زيد بن ثابت. كما تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم.

المسألة الثانية

الفرق بين التَّحْكِيم وبين القضاة

نذكر فيما يلي أهم الفروق بين التحكيم وبين القضاة، وذلك في سبعة عناصر، وهي الولاية، والمشروعية، والأهلية، والتهمة، والمحل، والرجوع فيه، ونقضه.

أولاً: الولاية

(١) القضاة: ولايته عامة من الإمام أو الرئيس، فهو قضاء رسمي.

(٢) التحكيم: ولايته خاصة من أطراف الخصومة، فهو قضاء عرفي.

ثانيًا: المشروعية

(١) القضاء: مجمع على مشروعيته في الجملة، ولا تقوم مصالح الناس إلا به.

(٢) التحكيم: فيه خلاف فقهي، حيث أجازهُ الجمهور؛ للتخفيف على القضاء، ومنع جوازهُ بعض الحنفية وعليه الفتوى عندهم وبعض الشافعية؛ خشية من تحكيم الجاهل وترك العلم في القضاء.

ثالثًا: الأهلية

(١) القضاء: يشترط في القاضي شروط تؤهله لولاية القضاء العامة، ومن أهمها العلم بمتطلبات القضاء.

(٢) التحكيم: اختلف الفقهاء في شروط المُحَكَّم على مذهبين:

المذهب الأول: يرى أنه يجب أن يتصف المُحَكَّم بأهلية القاضي وشروطه؛ لأنه في حكم القاضي. وهو قول جمهور الفقهاء.

المذهب الثاني: يرى أنه لا يشترط في المُحَكَّم كل صفات القاضي، بل تكفيه الشروط التي تمكنه من فصل الخصومة بتراضي أطرافها، ولو مع صفة الجهل بالأحكام الفقية؛ لمحدودية تحكيمه، بخلاف القاضي العام. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة.

رابعًا: التهمة

(١)القضاء: لا يجوز للقاضي أن يحكم في خصومة يُتَّهم فيها، كما لو كان القاضي قريبًا أو صديقًا لأحد الخصمين بما تبلغ هذه التهمة حق طلب رده.

(٢)التحكيم: اختلف الفقهاء في اشتراط عدم تهمة المحكم على مذهبين: المذهب الأول: يرى أنه لا يجوز تحكيم الخصم وغيره ممن يتهم؛ لأنه نوع قضاء. وهو قول جمهور الفقهاء، ذهب إليه بعض الحنفية القائلين بالتحكيم، وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة.

المذهب الثاني: يرى جواز تحكيم الخصم وغيره ممن يتهم؛ لأنه قضاء عرفي قائم على التراضي، فيتسامح فيه. وهو القول الثاني عند المالكية والشافعية والحنابلة.

خامسًا: محل التحكيم

(١)القضاء: يفصل في كل نزاع يعرض عليه.

(٢)التحكيم: محل خلاف، ونجمله في أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أنه يجوز التحكيم في كل ما يجوز فيه القضاء حتى الحدود والقصاص. وهو قول الشافعية في وجه، والحنابلة في ظاهر الرواية عن الإمام أحمد.

وحجة هذا المذهب: أن التحكيم قضاء، ويتحقق به إنهاء الخصومة، فيكون له مثل ما يكون للقضاء من اختصاصات.

المذهب الثاني: أنه يجوز التحكيم فيما يصح لأحدهما ترك حقه فيه، وهو لابن عرفة المالكي، ونسبه لظاهر الروايات في المذهب المالكي.

وحجة هذا المذهب: أن التحكيم قضاء عرفي فاختص فيما يصح للمتخاصمين التصالح فيه؛ لمنع العدوان على القضاء العام.

المذهب الثالث: أنه يجوز التحكيم في كلِّ الأقضيات عدا الحدود والقصاص، وما فيه حق الله كالطلاق واللعان والنسب. وهو قول جمهور الفقهاء، الحنفية القائلون بمشروعية التحكيم، والمالكية في القول الثاني، والشافعية، والحنابلة في المشهور. وأجاز أبو حنيفة في رواية التحكيم في القصاص، وأجاز السرخسي الحنفي التحكيم في القذف.

وحجة هذا المذهب: أن الأقضيات التي تقوم على حق الله، أو يغلب فيها حق الله، كالحدود والقصاص واللعان والنسب مبنية على الاحتياط ومراعاة الحق العام، فاختص الإمام بالنظر فيها، ولم يجز تركها للتحكيم

سادساً: الرجوع عن الحكم

(١) القضاء: لا يجوز الرجوع في حكمه؛ لحسم مادة النزاع، ولحماية هيبة القضاء.

(٢) التحكيم: محل خلاف، ونجمله في ثلاثة مذاهب للفقهاء:

المذهب الأول: أنه يجوز الرجوع في التحكيم قبل صدور الحكم من المحكم، أما بعد صدوره فقد لزم؛ لاستقرار الأحكام. وهو قول جمهور الفقهاء.

المذهب الثاني: أنه يجوز الرجوع في التحكيم قبل صدور الحكم وبعده؛ لأن رضا الخصمين معتبر في أصل التحكيم، فاعتبر بعده. وهو قول بعض الشافعية والحنابلة.

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الرجوع في التحكيم بحال، لا قبل صدور الحكم ولا بعده؛ لحسم النزاع كالقضاء. وهو قول ابن الماجشون المالكي.

سابعًا: نقض الحكم

(١) القضاء: محل إجماع في عدم نقض حكمه في الجملة إلا إذا خالف نصًا قاطعًا، وزاد المالكية: ما يشذ مدركه، أي دليله.

أما حكم القاضي في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد فلا يجوز نقضها عند جمهور الفقهاء؛ استقرارًا للأوضاع.

وزهد الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز نقضها؛ لأن الحكم الأول لم يجز بقول الكل بل بقول البعض دون البعض، فكان محتملاً للنقض بمثله.

(٢) التحكيم: محل خلاف في نقض حكمه، ونجمل الخلاف في مذهبين: المذهب الأول: يرى أنه إذا رفع أحد المتنازعين في التحكيم أمره للقضاء لزم على القاضي عدم نقض التحكيم إلا بما ينقص به قضاء غيره من القضاة. وهو قول جمهور الفقهاء.

المذهب الثاني: يرى أن التحكيم لا يلزم القاضي، فله أن يعده كأن لم يكن. وهو قول الحنفية.

المسألة الثالثة

صور التحكيم

يقع التحكيم بثلاث صور بحسب موضوع نزاعه: فإن كان النزاع ماليًا فإن نتيجته تكون صلحًا ماليًا أو تعويضيًا، وإن كان النزاع عائليًا فإن نتيجته تكون صلحًا عائليًا أو أسريًا، وإن كان النزاع دينيًا فإن نتيجته تكون صلحًا دينيًا أو تعبديًا، كما في كفارة صيد المُحرم. ونبين ذلك فيما يلي:

أولاً: التحكيم للصلح المالي (التعويضي)

يصحُّ الصلحُ المالي من كل أحد يقدر عليه، وتكون له المكانة الأدبية عند المتخاصمين، بحيث يكون حكمه بينهما مرضيًا، وقاطعًا للنزاع؛ لأن هذا التحكيم من النصيحة التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لكل قادر عليها، فيما أخرجهُ مسلم عن تميم الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة". ويجوز أن يطلق على هذا الصلح المالي أنه صلح تعويضي؛ لما يحكم فيه من العوض للطرف المظلوم.

ويشترط في الصلح المالي (التعويضي) عند جمهور الفقهاء ألا يكون المُحكَّم قريبًا لأحد الخصمين قرابة تمنع الشهادة لمنع المحاباة؛ خلافًا لبعض المالكية والشافعية والحنابلة الذين أجازوا تحكيم من يتَّهم؛ لأنه باختيارهم.

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح المالي في الجملة؛ لأنه بالتراضي. قال تعالى: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" (النساء: ١١٤).

وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين"، وفي رواية: "إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً". وأخرج الطبراني عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاقدوا".

وأخرج البخاري ومسلم عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: "يا كعب:" قال لبيك يا رسول الله، قال: "ضع من دينك هذا"، وأوماً إليه أي الشطر، قال: فعلت يا رسول الله، قال: "قم فاقضه". قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم": السجف، بكسر السين وفتحها مع إسكان الجيم، هو الستر.

وأخرج الشيخان عن عائشة، قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟" فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب.

ثانياً: التحكيم للصلح العائلي (الأسري)

اشتراط الفقهاء في الصلح العائلي أن يكون من الأقارب في الأسرة، ومن في حكمهم؛ لأنه قائم على الستر، ومراعاة قيمة الكبار في العائلة كضمانة للصلح.

ويدل على ذلك عموم قوله تعالى: "وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما" (النساء: ٣٥)، فإن لم نجد من أهل القرابة الأدنى أخذنا الأبعد، لكن الأقرب فالأقرب.

واختلف الفقهاء في سلطة الحكمين في النزاع الزوجي، كما اختلفوا في جهة تنصيب الحكمين، ونبين ذلك فيما يلي:

(١) سلطة الحكمين في النزاع الزوجي:

اختلف الفقهاء في سلطة الحكمين في النزاع الزوجي، على مذهبين في الجملة:

المذهب الأول: يرى أن الحكمين لهما الجمع بين الزوجين، ولهما التفرقة بينهما. وهو قول جمهور الفقهاء، حتى حكى بعضهم الإجماع فيه.

وحجتهم: ما أخرجه عبد الرزاق عن عثمان بن عفان أنه بعث حكمين، وقال لهما: "إن رأيتما أن تجمعاً جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا". وروى ابن أبي حاتم الرازي نحو هذا عن علي بن أبي طالب.

قال ابن كثير في "تفسيره": "قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما، ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتها بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة، وثقة من قوم الرجل ليجمعاً فينظر في أمرهما، ويفعلاً ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق.

وعن ابن عباس قال: أمر الله - عز وجل - أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل، ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضى يرث الذي لم يرض، ولا يرث الكاره الراضي".

المذهب الثاني: يرى أن الحكمين لهما الجمع بين الزوجين، وليس لهما التفرقة بينهما. وهو قول الحسن البصري وقتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وداود الظاهري.

وحجتهم: عموم قوله تعالى: "إن يريدوا إصلاً يوفق الله بينهما" (النساء: ٣٥). فلم يذكر التفريق.

(٢) جهة تنصيب الحكمين في النزاع الزوجي:

اختلف الفقهاء في الحكمين لحل النزاع العائلي، هل هما منصوبان من جهة الحاكم، أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على مذهبين في الجملة: **المذهب الأول:** يرى أن الحكمين في النزاع الزوجي منصوبان من جهة الحاكم. ويترتب على ذلك أن ينفذ حكمهما وإن لم يرض الزوجان بتنصيبهما. وهو قول جمهور الفقهاء.

وحجتهم: عموم قوله تعالى: "فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها" (النساء: ٣٥)، ومن شأن الحكم أن يفصل بدون رضا الخصمين.

المذهب الثاني: يرى أن الحكمين وكيلان من جهة الزوجين. ويترتب على ذلك أن حكمهما يحتاج إلى إقرار الزوجين بتنصيبهما. وهو قول أبي حنيفة والجديد للشافعي.

وحجتهم: حاجة الحكمين إلى معرفة ما يحمله كل زوج من صاحبه؛ لئتمكنا من تقريب وجهات النظر، فلزم أن يكون حكم كل زوج باختياره ورضاه؛ حتى يفشي له أوجه غضبه من الآخر.

واستدل ابن كثير في "تفسيره" على أن الحكمين وكيلان عن الزوجين، وليساً منصوبين من جهة الحاكم بما أخرجه ابن أبي حاتم الرازي وابن جرير الطبري، عن محمد بن سيرين عن عبيدة، قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها، مع كل واحد منهما فتاًم من الناس، فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً، فقال عليٌّ للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعاً جمعتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعليّ.

وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله - عز وجل - لك وعليك".

ثالثاً: التحكيم للصلح الديني (كفارة صيد المُحرم)

يصحُّ الصلح الديني من كل مَنْ يوصف بالعدالة من المسلمين، ويدل على مشروعيته عموم قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليزوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو

انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون" (المائدة: ٩٥-٩٦).

وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن العمد والخطأ في قتل صيد الحرم سواء؛ لكن العمد معه الإثم والخطأ لا إثم فيه.

وذهب الظاهرية ونسبه ابن حزم في "المحلى" لعمر بن الخطاب ورواية عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن جبیر. ونسبه ابن كثير في "تفسيره" إلى طاوس بن كيسان، قالوا: إنه ليس على المخطيء في صيد المُحرم شيء؛ عملاً بظاهر الآية الكريمة: "ومن قتله منكم متعمداً".

قال ابن رشد في "بداية المجتهد": "أجمعوا على أن المُحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء بالنص، واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم؟ فقال الجمهور: عليه الجزاء. وقال داود وأصحابه: لا جزاء عليه".

وإذا ثبت تحريم قتل المُحرم للصيد عمداً للنهي الصريح في الآية الكريمة، وإلحاق جمهور الفقهاء المخطيء بالعامد فيه. فإن الفقهاء قد اختلفوا في تفسير هذه الآية كيف يكون الحكم بالمثل من النعم، وكيف يكون التخيير، على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يرى التفصيل في نوع الصيد، فهو لا يخلو من أن يكون له مثل، أي نظير في الشبه من النعم (إبل أو بقر أو غنم) مثل الحمار الوحشي أو البقر الوحشي، أو لا يكون كذلك مثل الطيور. وهو مذهب جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا لكل نوع من هذين حكمه الخاص.

(١) أما الصيد المثلي فجزأؤه على التخيير، أي أن الجاني يُخَيَّر بين ثلاثة أشياء:

أ- أن يذبح المثل من النعم والشبيه بالصيد في الحرم، ويتصدق به على مساكين الحرم.

ب- أن يَقْوَمَ المثل من النعم دراهم ثم يشتري بها طعامًا، ويتصدق به على مساكين الحرم.

ج- أن يقسم الطعام إلى أمداد ثم يصوم عن كل مد (ربع صاع أو ستمائة جرام تقريبًا) يومًا. وفي أقل من مَدٍّ يجب صيام يوم، ويجوز الصيام في الحرم وفي كل البلاد.

(٢) أما الصيد غير المثلي فيجب فيه قيمته، ويتخير فيها بين أمرين:

أ- أن يشتري بهذه القيمة طعامًا يتصدق به على مساكين الحرم، وعند مالك: على المساكين في موضع الصيد.

ب- أن يصوم عن كل مَدٍّ يومًا.

المذهب الثاني: يرى أن تقدر قيمة الصيد نقدًا بتقويم رجلين عدلين سواء أكان للصيد المقتول نظير من النعم أم لم يكن. وهو مذهب الحنفية، وقالوا تعتبر القيمة في موضع قتله، ثم يخير الجاني بين ثلاثة أمور هي:

أ- أن يشتري هديًا أو أكثر ويذبحه في الحرم إن بلغت القيمة هديًا، ويكون الهدي المذبح للفقراء ولو بغير الحرم، ويتعدد الهدي بحسب القيمة المتوفرة.

ب-أن يشتري بالقيمة طعامًا ويتصدق به على المساكين مثل صدقة الفطر، نصف صاع لكل فقير (والصاع ٢,١٨٥ جرامًا تقريبًا عند جمهور الفقهاء، ويساوي ٣,٠٥٠ جرامًا تقريبًا عند أبي حنيفة). ولا يختص التصدق بمساكين الحرم.

ج-أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

المذهب الثالث: يرى أن المتعمد لقتل الصيد وهو محرم مخير بين ثلاثة أشياء، أيها شاء فعله وقد أدى ما عليه:

أ-أن يهدي مثل الصيد الذي قتل من النعم.

ب-أن يطعم مساكين، وأقل ذلك ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع عند أكثر أهل اللغة.

ج-أن ينظر إلى ما يشبع ذلك الصيد من الناس فيصوم بدل كل شبة إنسان يومًا، فإذا كان الصيد قد وقع على حمار وحشي نظرنا إلى عدد الذين يأكلون مثل هذا الحمار من البشر ويشبعون، فإذا قلنا إنه ينتهي بأكل ثلاثين إنسانًا فإنه يجب على المحرم صائده أن يصوم ثلاثين يومًا. وهذا مذهب الظاهرية الذي نص عليه ابن حزم في "المحلى".

صفة الحكمين في تقدير صيد المُحرم:

قال تعالى: "يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة" (المائدة: ٩٥)، والعبرة بالعدالة الظاهرة. وهل يشترط في هذين الحكمين أو أحدهما ألا يكون قريبًا للمُحرم المحكوم عليه بالجزاء؟ مذهبان للفقهاء:

المذهب الأول: يرى أنه يشترط في هذين الحكمين عدم صلة القرابة بالمُحَرَّم المحكوم عليه بالجزاء إلى درجة مظنة المحاباة. وهو قول جمهور الفقهاء.

المذهب الثاني: يرى أنه لا يشترط في هذين الحكمين إلا صفة العدل، فيصح تحكيم الأقارب الأدنى والأزواج المحكوم بعدالتهم. وهو قول الظاهرية؛ لأن الأصل هو اعتبار الأمانة.

المسألة الرابعة

لزوم التَّحْكِيم ونقضه

نتكلم عن لزوم التحكيم ونقضه في العنصرين الآتين:

أولاً: لزوم التَّحْكِيم

اختلف الفقهاء القائلون بمشروعية التَّحْكِيم في مدى لزوم حكمه بعد صدوره، على مذهبين:

المذهب الأول: يرى أن التحكيم ملزم بنفس الحكم، وإليه ذهب الحنفية القائلين بالتَّحْكِيم، والمالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة، واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

(١) دليل الكتاب: منه عموم قوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا" (النساء: ٣٥)، وشأن الحكم الإلزام كالقضاء. وعموم قوله تعالى: "أوفوا

بالعقود" (المائدة: ١)، وعموم قوله تعالى: "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً" (الإسراء: ٣٤).

(٢) دليل السُّنَّة: أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، عن أبي شريح هانيء بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قومه يكنونه بأبي الحكم، فقال له: "إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلم تكني أبا الحكم"؟. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضى كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا، فما لك من الولد"؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: "فما أكبرهم"؟ قلت: شريح، قال: "أنت أبو شريح. ودعا له ولولده"، وفي هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لعمل أبي شريح من التحكيم، ولولا أنه ملزم لما كانت له فائدة.

وأخرج البخاري تعليقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون عند شروطهم"، وأخرجه الدارقطني عن عوف المزني مرفوعاً، وبزيادة: "إلا شرطاً حَرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وفي هذا دلالة على لزومية التحكيم؛ لأنه عقد مشروط.

وأورد ابن قدامة في "المغني" دون إسناد، غير موجود في كتب الأحاديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون"، قال ابن قدامة: "لولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم".

(٣) دليل المعقول: أوجه كثيرة، نذكر منها وجهين:

الوجه الأول: أن المحكّم بمثابة الوكيل المفوض من المتنازعين، وتصرف الوكيل نافذ في حق موكله، فكذاك حكم المحكّم نافذ في حق مَنْ حَكَمُوهُ؛ قياسًا على نفاذ تصرف الوكيل على موكله.

الوجه الثاني: إن كل مَنْ جاز حكمه لزم حكمه كالقاضي الذي ولّاه الإمام، إذ من شأن الحَكَم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه.

المذهب الثاني: يرى أن التحكيم ليس ملزمًا بنفس الحكم، وإنما يلزم بتراضيهما بعد الحكم. وهو القول الثاني عند الشافعية اختار المزني، ووجه عند الحنابلة. وحجتهم من وجهين:

الوجه الأول: أنه لو ألزما الخصمين بحكم التّحكيم لكان عزلاً للقضاء، وافتئاتاً على الإمام، فلزم أن يكون حكم التّحكيم اختياريًا.

الوجه الثاني: أنه لما اعتبر تراضي الخصمين في اختيار الحكم اعتبر رضاها في لزوم حكمه.

الرأي المختار: يمكن التّوصل إليه عن طريق النظر في أدلة المذهبين، واختيار ما قوي دليله، وظهرت حجته، مع مراعاة تداعيات الاختيار على المصالح الخاصة والعامة، وكلّ مكلف على نفسه بصيره، وعليه أن يستفتي قلبه بحثًا لأحظ لنفسه؛ لأن التّحكيم مشروع ديانة وقضاء لكل أحد، فكان الاختيار في وضع ضوابطه لكلٍ أحد بالتراضي مع صاحبه.

ثانيًا: نقض التحكيم بالقضاء

اختلف الفقهاء فيما يجب على القاضي في حال التجاء أحد الخصمين إليه بعد صدور حكم المحكّم المختار منهما، على مذهبين:

المذهب الأول: يرى أنه يلزم على القاضي إنفاذ حكم المحكم المختار، وعدم نقضه لمجرد أنه حكم تحكيم، إلا أن يكون مستحقاً للنقض موضوعياً، كمخالفته للنظام العام. وهو مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة.

وحجتهم: عموم الأمر بالوفاء بالعقود، والتحكيم من تلك العقود.

المذهب الثاني: يرى أنه من حق القاضي نقض حكم التحكيم في حال مخالفته مذهبه في إصدار الأحكام، ومن حقه عدم نقضه. وهو مذهب الحنفية.

وحجتهم: سيادة القضاء على التحكيم، والعمل على توحيد أحكام الأقضية، وعدم التمكن للأحكام العرفية أو الأهلية أن تخرج عن سلطان القضاء.

ثانياً:

كتاب الصيد والذبائح

تأليف/

الأستاذ الدكتور/ مراد محمود حيدر

أستاذ الفقه المقارن بالكلية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله أحل الحلال برحمته، وحرّم الحرام بحكمته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بلغ عن ربه المراد من شرعه، وبينه لأمته، فتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من هلك.

وبعد:

فإن الذبائح تحتل أهمية كبيرة في حياة الفرد المسلم، ذلك أن المسلم مأمور باتباع أحكام دينه التي تتعلق بحياته، وما يشملها من مأكّل ومشرب، والذبح الشرعي له كيفية أمرنا به الشارع الحكيم، وشرحتها بها النصوص الشرعية، واستنبط الفقهاء من مجموع النصوص الشرعية من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، ما يوضح للمسلم في حياته، كيف يذكي ذبيحته تذكية شرعية في حالي الاختيار والاضطرار، فحال الاختيار تتحقق عندما يكون الحيوان المراد تذكيته أو ذبحه ذبْحاً شرعياً، مقدوراً عليه بحيث يستطيع اضطجاعه، وقطع حلقومه ومريئه ووجديه، على تفصيل يذكره الفقهاء في ذلك، وحال الاضطرار تتحقق عندما يكون الحيوان المراد تذكيته غير مقدور عليه، كما هو الحال في الحيوانات المتوحشة، وكذا الحيوان المستأنس غير المقدور على إمساكه بسبب هروبه أو شروده أو توحشه، فلا مفر حينئذ من اللجوء إلى عقر الحيوان غير المقدور عليه في أي مكان من جسده، بحيث يكون إنهار الدم على النحو الشرعي المطلوب.

ومع التطور الصناعي، الذي أدى إلى استخدام الآلات الحديثة في الذبح، عن طريق الذبح الآلي، واستخدام وسائل الصعق الكهربائي، مما قد يؤدي إلى خنق الذبيحة، أو قتلها على غير الطريق الشرعي، وكذا تطور وسائل الصيد الحديثة، مثل البنادق، والمسدسات، والحق المسمومة أو المخدرة التي تؤدي إلى تخدير الحيوان، كلياً أو جزئياً، وربما اختناقه في بعض الأحوال، لكل هذا؛ فقد بات من الضروري للمسلم التعرف على كيفية التذكية الحديثة، وموافقتها للتذكية المطلوبة في شريعته من عدمه، حتى يمتثل أمر ربه، في مأكله ومشربه.

وقد ترك لنا الفقهاء عليهم رضوان الله، ثروة فقهية هائلة، شرحوا من خلالها في باب الصيد، كيف يتم صيد الحيوان بالآلة المحددة، وكيف يتم اصطياده بحيوان جارح معلم أو غير معلم، كالكلاب والصقور، وغيرها من سائر الحيوانات والطيور المستخدمة في الصيد، المأكول منها وغير المأكول، ما اقره الشارع منها وما لم يقره رحمة بعباده، ورأفة بهم.

خطة الدراسة:

نحن في هذا الباب، نحاول إيضاح ما كتبه الفقهاء، وقرروه في شروحهم، في كيفية تذكية الحيوان البري المقذور عليه فيما يسمى عند الفقهاء "بالتذكية في حال الاختيار"، وكذا الاصطياد للحيوان الوحشي، أو المستأنس الشارد، أو غير المقذور على تذكيته، فيما يسمى عند الفقهاء "بالتذكية في حال الاضطرار"، كل هذا مع ضمنية كيفية الذبح والنحر،

وكيف تكون التذكية وآلتها، وشروطها وشروط الذابح " المذكي " ولا ننسى في ذلك الخلاف الفقهي في الحيوان البحري، المستثنى من التذكية، مثل السمك، وكذا الحيوان البري، الذي استثنته النصوص من الذبح كالجراد.

ورغم أن الباحث يجد في جُلِّ كتب الفقهاء المتقدمين هذه التسمية "كتاب الصيد والذبائح" إلا إنهم يفتتحون الكتابة "بكتاب الذبائح" رغم تقديمهم " كتاب الصيد" عليه في التسمية، ولعل مرّد ذلك إلى أن التذكية أي الذبح الشرعي في حال الاختيار هو الأكثر وقوعاً بين الناس، أما التذكية في حال الاضطرار، وهي العقر في الصيد وغير المقدور عليه من الحيوان، هي الأقل وقوعاً، ولذا؛ فقد قدم الفقهاء ما يحتاج إليه المسلم لكثرة وقوعه، وأخروا ما يقل حدوثه، من باب تقديم الأهم على المهم.

وحتى يكون طالب العلم الشرعي على دراية تامة بأمور الذبح والقنص الشرعي، فقد رأينا تقسيم هذا الكتاب من الدراسة إلى بابين:

الباب الأول: أحكام الذبائح.

الباب الثاني: أحكام الصيد.

باب الذبائح

تقسيم:

نتعرض لدراسة الأحكام المتعلقة بباب الذبائح في تمهيد وخمسة فصول:

التمهيد: ويشمل: تعريف الذبائح، والألفاظ ذات الصلة، وحكم الذبح، وحكمة مشروعيته.

الفصل الأول: في بيان محل الذبح.

الفصل الثاني: في أنواع التذكية وكيفيةها.

الفصل الثالث: في بيان آلة التذكية.

الفصل الرابع: في شروط التذكية.

الفصل الخامس في شروط المذكي.

وذلك كما يلي:

تمهيد

في تعريف الذبائح، والألفاظ ذات الصلة، وحكم الذبح، وحكمة مشروعيته

تعريف الذبائح:

لغة: الذبائح جمع ذبيحة، بمعنى مذبوحة. والذَّبْحُ: مصدر ذَبَحْتُ الشاة. والذَّبْحُ، بالكسر ما يُذْبَحُ: قال الله تعالى: (وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ) ^(١). والذَّبِيح: المذبوح، والأنثى ذَبِيحَةٌ، وإنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها. والذَّبِيح: الذي يَصْلُحُ أَنْ يُذْبَحَ للنسك ^(٢)، والذبح هو الذكاة أيضا ^(٣)، قال - تعالى - : (إِنْ مَا ذَكَيْتُمْ) أي ذبحتم ^(٤).

وشرعاً: الحيوان الذي تمت تذكيته ^(٥) على وجه شرعي ^(١).

(١) الصافات/ ١٠٧.

(٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، الجوهري، ٣٢/١، أساس البلاغة للزمخشري، ٣٠٩/١، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ١٥٣/٢.

(٣) المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيدة، ٢٩٢/٣. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان الحميري، ٢٤٥/٤، المغرب في ترتيب المعرب ، ناصر المطرزي، ، ص: ١٧٣، مختار الصحاح للرازي، ص: ١١١.

(٤) المائدة/ ٣

(٥) الزكاة لغة: الذَّبْحُ، وَذَكَى الْخَيْوَانُ: ذَبَحَهُ ، ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، ٧/ وشرعاً ١٣٣، وَمَعْنَى التَّذْكِيَةِ: أَنْ تُذَرِكَهَا وَفِيهَا بَقِيَّةٌ تَشْتَبُ مَعَهَا الْأَوْدَاجُ وَتَضْطَرِبُ اضْطِرَابَ الْمَذْبُوحِ الَّذِي أُذْرِكَتْ ذَكَائِهِ، لسان العرب، لابن منظور، ١٠٤/٣، والذكاة شرعاً: السَّبَبُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى إِبَاحَةِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ الْخَيْوَانِ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب ، ٢٠٨/٣، وعرفها

الألفاظ ذات الصلة:

التذكية:

وهي في اللغة: مصدر ذكيتُ الحيوان أي ذبحته أو نحرتَه، والذكاة: اسم المصدر. ومعناها إتمام الشيء والذبح^(٢)

وفي الاصطلاح: هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري اختياراً^(٣). وقيل: هي السبيل الشرعية لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولاً وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير مأكول^(٤)

حكم الذبح:

بعض الفقهاء بأنها: ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ حَيَوَانٍ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ لَا جَرَادٍ وَنَحْوَهُ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني ٣٢٨/٦.

(١) الاختيار لتعليل المختار، الموصلي البلدحي، ٩/٥. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، ١٩٠/٨. المقدمات الممهدات لابن رشد الجد، ٤٢٣/١. لمختصر الفقهي لابن عرفة، ٣٠٥/٢. البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمرائي، المحقق: ٥٢٦/٤، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لابن الملقن، ١٧٢٣/٤. تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب، البَجِيرَمِي، ٢٩٣/٤. كشف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، ٢٠٣/٦، الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، عثمان الحنبلي، عبد الله بن محمد بن ناصر البشر (ج ٣، ٤) الناشر: مؤسسة ٩٦٨/٤.

(٢) لسان العرب لابن منظور، ١٠١/٢.

(٣) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١ / ٣١٢.

(٤) بدائع الصنائع ١ / ٨٥، الدر المختار على حاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٦.

اشترط الفقهاء لحل أكل الحيوان التذكية الشرعية المعهودة، إلا ما استثناه الشارع الحكيم بنص خاص كالسمك والجراد^(١)

واستدلوا لذلك بما يلي:

أ. قوله تعالى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)^(٢)

وجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله عز وجل، حرم الميتة وما بعدها في الآية الكريمة، واستثنى من التحريم ما تمت تذكيته أي ذبحه، على النحو الذي أمر به الشارع الحكيم، فيكون حلالاً.^(٣)

وقد دلت الآية الكريمة على أن الحيوان البري المأكول لا يكون حلالاً إلا بالتذكية الشرعية من ذبح أو نحر أو عقر.

ب. قوله تعالى (أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ)^(٤)

وجه الاستدلال: أن المذكي من الطيبات وغير المذكي ليس منها.

ج قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفْرَ".^(١)

(١) بدائع الصنائع، ٣٦/٥، المبسوط للسرخسي، ٢٢١/١١، المدونة الكبرى، للإمام مالك، ٥٤٢/١، أسنى المطالب للأنصاري، ٥٥٢/١، تحفة المحتاج لابن حجر، ٣١٢/٩، المغني لابن قدامة، ٣١٥/٩، الفروع لابن مفلح، ١٢٢/٦.

(٢) المائدة/٣

(٣) جامع البيان، للطبري، ٥٠٥/٩.

(٤) المائدة/٤

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الحيوان الذي تمت تذكيته على نحو شرعي، فيكون غير المذكي حراماً.

د . وأما الإجماع على التذكية فقد نقله غير واحد من أهل العلم. (٢)

حكمة مشروعية الذبح:

الحكمة في اشتراط التذكية أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) (٣) وقال تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) (٤) ولا يطيب إلا بخروج الدم وذلك بالذبح أو النحر، ولهذا حرمت الميتة؛ لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم، ولذا لا يطيب مع قيامه، ولهذا يفسد في أدنى مدة لا يفسد في مثلها المذبوح، وكذا المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا لم تدرك حية، فتذبح أو تنحر (٥)

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، ١٤٢/٢، الحديث: ٢٥٠٧.

(٢) عجلة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لابن الملن، ١٧٢٣/٤.

(٣) سورة المائدة / ٤.

(٤) سورة الأعراف / ١٥٧.

(٥) بدائع الصنائع ٥ / ٤٠، مغني المحتاج ٤ / ٢٦٧.

ومن الحكمة أيضاً: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وتمييز
مأكل الآدمي عن مأكل السباع، وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإباحة
إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع به بعد موته (١)

(١) حجة الله البالغة للدهلوي ٢ / ٨١٢ وما بعدها نشر دار الكتب الحديثة
بالقاهرة.

الفصل الأول

في بيان محل الذبح

تمهيد:

محل الذبح: هو الحيوان الذي يجري ذبحه، وليس كل حيوان يتم ذبحه يكون حلالاً، وإنما يجري الذبح في الحيوان الذي أحل الشارع الحكيم أكله.

وعليه: فكل حيوان أباح الشارع أكله فإنه يشترط فيه الذبح كي يكون حلالاً، وسوا أكان ذلك الحيوان برياً أم كان بحرياً، إلا ما استثناه الشارع من الذبح بنص خاص.

ولذا ستكون دراستنا في محل الذبح للحيوان البري أو البحري الذي يشترط فيه الذبح، وما يُستثنى من الذبح ولو كان ميتة، سواء في ذلك ميتة البر والبحر على السواء، ثم نتعرض لدراسة تأثير الذكاة في الحيوان المأكول، وغير المأكول، وكذا تأثير الذكاة في المحرمات، وذلك في المباحث الآتية:

المبحث الأول: ما يُشترط فيه الذبح من الحيوان.

المبحث الثاني: في تأثير الذكاة في المحرمات متى أدركت حية.

المبحث الثالث: في تأثير الذكاة في الحيوانات التي يحرم أكلها.

المبحث الأول:

ما يُشترط فيه الذبح من الحيوان:

من المعلوم شرعاً أن الأصل في حِلِّ أكل الحيوان هو تذكّيته أي ذبحه^(١) أو نحره^(٢) على النحو الذي أراده الشارع، إلا ما استثناه بنص خاص.

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على اشتراط التذكية في الحيوان البري، الذي له دم يسيل منه عند الذبح، وليس بمحرم شرعاً.^(٣)

(١) النَّحْرُ: نَحَرُ الصدر أعلاه، وقيل: هو موضعُ القلادة منه، وهو المَنْحَر، ونَحَرَ البعيرَ يَنْحَرُه نَحْراً: طَعَنَه في مَنْحَرِه حيث يبدو الحُلُقُوم من أعلى الصَّدْر؛ لسان العرب لابن منظور، ١٩٥/٥، فالنحر يكون للإبل ومعناه: أن يضربها بسكين أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، والوهدة التي بين أصل عنق الجمل وصدرة يضربها بحربة أو سكين ونحوها، وهو إنما يكون للإبل، فتح الباري لابن حجر، ٥٥٦/٩.

(٢) الذَّبْحُ: مصدر ذَبَحْتُ الشاة؛ يقال: ذَبَحَهُ يَذْبُحُه ذَبْحاً، فهو مَذْبُوح وذَبِيح والذَّبِيحَة: الشاة المذبوحة. فالذبح؛ هو قطع الحلقوم والمريء والودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. وتكون للشاه والبقرة وما شابه. لسان العرب لابن منظور، ٤٣٦/٢. فتح الباري لابن حجر، ٥٥٦/٩.

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني الحنفي ٣٥/٥، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ٢٠٢/٢. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، ٢٦/١٥، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ٢٠٤/٦.

كما اتفقوا على عدم اشتراط التذكية في الحيوان البحري المنصوص على
حَلِّهِ، كالسمك. (١)

**واختلفت كلمة الفقهاء في اشتراط تذكية الجنين، وتذكية الجراد، وميتة
البحر كالسمك ونحوه، ونعرض لكل واحدة منه هذه المسائل بالتفصيل في
المطالب الآتية:**

المطلب الأول

هل تعمل ذكاة الأم في جنينها؟

من المسائل المتعلقة بمحل الذبح: تذكية الأم هل تقع تذكية لجنينها
بحيث تعمل الذكاة فيها وفي جنينها، فيكون الجنين ذبيحة حلالاً أم لا
تعمل الذكاة في الجنين فيكون ميتة؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الذكاة تعمل في الحيوان المذبوح متى وقعت على
النحو الشرعي المطلوب. واختلفوا هل تعمل الذكاة في جنين الحيوان
المذبوح الذي يكون داخل بطن الأم المذبوحة على قولين:

**القول الأول إن الذكاة تعمل في الحيوان المذبوح وتعمل في جنينه الذي
في بطنه، فذكاة الأم ذكاة لجنينها.**

(١) المراجع السابقة، نفس المواضع.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: المالكية^(١)، والشافعية، والحنابلة، وهو قول محمد وأبي يوسف من الحنفية^(٢)، وقول جمهور السلف ومن بعدهم من العلماء^(٣)، وحكي فيه الإجماع^(٤)

واستدلوا بما يلي:

(١) وقَّيَّده المالكية بشرطين: أن يتمَّ خلفه وينبت شعره. انظر: مواهب الجليل

لشرح مختصر الخليل، ٣٤٢/٤، التاج والإكليل، للمواق، ٢٢٧/٣

(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ٣٤٢/٤، التاج والإكليل، للمواق

٢٢٧/٣، المجموع، للنووي، ١٢٨/٩، ويُنظر: أسنى المطالب لذكري

الأنصاري، ٥٦٨/١، الإنصاف للمرداوي (٣٠٣/١٠)، كشاف القناع، للبهوتي

٢٠٩/٦، بدائع الصنائع للكاساني، ٤٢/٥.

(٣) قال ابن عبد البر: (وقال الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وأبو يوسف،

ومحمد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود: يؤكل الجنين ذكاة أمه إن كان ميتاً،

ولم يذكروا تمام خلق ولا شعر). التمهيد لابن عبد البر، ٧٧/٢٣، وقال النووي:

(وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار).

المجموع، ١٢٨/٩، وقال ابن قدامة: (وقال ابن عمر: ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر،

وروي ذلك عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والحسن، وقتادة، ومالك،

والليث، والحسن بن صالح، وأبي ثور؛ لأنَّ عبد الله بن كعب بن مالك، قال: كان

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه،

وهذا إشارة إلى جميعهم، فكان إجماعاً). المغني، ٤٠١/٩.

(٤) قال ابن قدامة: (هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم، فلا يُعَوَّل على ما

خالفه). المغني، ٤٠١/٩. وقال أبو الحسن بن القطان: (وأجمع جميع علماء

الأمصار إلا من شذَّ ممن لا يُعَدُّ خلافة: أنَّ ذكاة الجنين إذا أشعر، في ذكاة أمه).

الإقناع في مسائل الإجماع، ٣١٧/١.

أ. عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: "قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنَحِرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أُنَلِّقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتِهِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" (١)

ب. واستدلوا من المعقول: بأنَّ حَقِيقَةَ الْجَنِينِ مَا كَانَ فِي الْبَطْنِ، وَذَبْحُهُ فِي الْبَطْنِ لَا يُمَكِّنُ؛ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَرَادُ أَنَّهُ يُذَكَّى كَذَكَاةِ أُمِّهِ، بَلْ ذَكَاةُ أُمِّهِ كَافِيَةٌ فِي حِلِّهِ (٢)

ج. كما استدلوا: بأنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَيَوَانِ تَخْتَلِفُ عَلَى حَسَبِ الْإِمَّاكَانِ فِيهِ وَالْقُدْرَةِ، بِدَلِيلِ الصَّيْدِ الْمُتَمَتِّعِ، وَالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَالْمُتَرَدِّدَةِ، وَالْجَنِينُ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى ذَبْحِهِ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَبْحِ أُمِّهِ؛ فَتَكُونُ ذَكَاتُهَا ذَكَاةً لَهُ (٣)

د. وأيضاً فَإِنَّ الْجَنِينَ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَالِ خَلْقَةٍ، يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا؛ فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاتِهَا، كَأَعْضَائِهَا (٤)

وَكَمَا أَنَّ الْجَنِينَ يَتَّبِعُ أُمَّهُ فِي الْعِتْقِ، فَيَتَّبِعُهَا فِي الذَّكَاةِ، كَالْأَعْضَاءِ. (٥)

(١) أخرجه أبو داود، الحديث رقم: ٢٨٢٧ واللفظ له، والترمذي بحديث رقم ١٤٧٦، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابنُ القَيِّمِ في إعلَامِ الموقِعين، ٢/٢٥٥، وابن الملقن في شرح البخاري ٢٦/٦٦١، وقال الصنعاني في سبل السلام ٤/١٣٦: بمجموع طرقه يُعْمَلُ به، وحسنه لغيره الشوكاني في نيل الأوطار، ٩/٢٢.

(٢) المجموع للنووي، ٩/١٢٨

(٣) المغني لابن قدامة، ٩/٤٠١.

(٤) المغني لابن قدامة ٩/٤٠١

(٥) المجموع للنووي، ٩/١٢٨

القول الثاني: إن ذكاة الأم ليست ذكاة لأمه، بل يكون من الميتة المحرمة، إن خرج ميتاً بعد ذكاة الأم، وأما إن خرج حياً فلا بد من ذكاته.

وإليه ذهب أبو حنيفة وابن حزم من الظاهرية.

واستدلوا بما يلي:

أ. بقول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم) ^(١) وقال تعالى: (إلا ما ذكيتم) ^(٢)

ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين: أن الجنين إذا خرج ميتاً من بطن أمه فهو من الميتة المحرمة، ولأن قوله تعالى إلا ما ذكيتم هو استثناء من جملة ما سبق ذكره من الحرام وهي الميتة والمنخقة ونحوها، والجنين إذا خرج ميتاً تبين أنه كان مخنوقاً فلا يحل.

وُنُقِشَ هذا بأن الجنين مُسْتَثْنَى بنص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشمل التحريم.

ب . وأما المعقول فقالوا: " بالعيان ندري أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحي، لأنه غيرها وقد يكون ذكراً وهي أنثى، فأما إذا كان لحماً لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعضها ولم يكن قط حياً فيحتاج إلى ذكاة. ^(٣)

(١) المائدة/٣

(٢) المائدة/٣

(٣) المحلى بالآثار، لابن حزم، ٩٦*٦.

ونُوقش هذا: بأن نسلم لكم أن الجنين ليس هو أمه، ولكنه تابع لها ، وقد استثناه الحديث الشريف، فجعل زكاته بذكاة أمه ، فيكون خارجاً عن التحريم .

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف بين الفقهاء هو اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري السابق مع مخالفته للأصول، واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم، وأحد من صححه الترمذي وغيره كما ذكرنا.

فمن قال بأن زكاة الجنين تحصل بذكاة أمه، استدل بحديث أبي سعيد السابق.

وأما من قال بعدم تزكية الجنين بذكاة أمه فقد استند إلى مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر، وبيان ذلك: أن الجنين إذا كان حياً ثم مات بموت أمه، فإنما يموت خنقاً، فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها.

الترجيح:

والذي نميل إليه هو قول الجمهور بأن زكاة الجنين تحصل بذكاة أمه، وذلك لحديث أبي سعيد، الذي صححه غير واحد من أهل العلم، بل نقل ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، حيث قال "هذا إجماع من

الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا خَالَفَهُ"^(١) وسأنده في ذلك ابن القطان، حيث قال "وأجمع جميعُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَّا مَنْ شَذَّ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ خِلَافُهُ: أَنَّ ذِكَاةَ الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ، فِي ذِكَاةِ أُمِّهِ".^(٢)

ولأن القياس يقتضي أن تكون ذكاة الجنين في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها، وإذا كان ذلك كذلك، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك.^(٣)

والله أعلم.

المطلب الثاني

هل الجراد تشتط له الذكاة؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الجراد إذا أدرك حيًّا، وأذهقت روحه بأي فعل من الآدمي، كأن أُلقي في الماء الحار أو النار مع التسمية عليه فإن هذا يُعدُّ ذكاة له.^(٤)

(١) المغني لابن قدامة، ٤٠١/٩

(٢) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، ٣١٧/١

(٣) بداية المجتهد، ٢٠٦/٢.

(٤) حاشية ابن عابدين، ٣٠٧/٦، فتح العزيز للرافعي، ١٥٣/١٢، المجموع للنووي، ٢٣/٩. المبدع لبرهان الدين ابن مفلح، ١٨٦/٩، الإنصاف للمرداوي

واختلفوا فيما لو أدرك الجراد ميتاً، فهل يُباح أكله على قولين:

القول الأول: يُباح أكل ميتة الجراد ولو مات حتف أنفه.

وإليه ذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ومطرف وابن وهب من المالكية، وهو قول طائفة من السلف^(١)، وحكي فيه الإجماع^(٢).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١. عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدِمَانِ: الْجَرَادُ وَالْحِيتَانُ، وَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ"^(١)

٢٨٩/١٠، مواهب الجليل، للحطاب ١/١٢٢، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ٤٤/٣.

(١) قال النووي: "الجراد حلال"، سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأحمد، ومحمد بن عبد الحكم والأبهرى المالكيان، وجماهير العلماء من السلف والخلف". انظر: المجموع، ٢٣/٩، وقال ابن قدامة: "ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب، في قول عامة أهل العلم، منهم الشافعي، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وابن المنذر". ، المغني، ٣٩٥/٩. وقال الشوكاني: "وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد، ولو مات بغير سبب"، نيل الأوطار ٨/١١٦٩.

(٢) حاشية ابن عابدين، ٣٠٧/٦، فتح العزيز للرافعي، ١٥٣/١٢، المجموع للنووي، ٢٣/٩، المبدع لبرهان الدين ابن مفلح، ١٨٦/٩، الإنصاف للمرداوي، ٢٨٩/١٠، مواهب الجليل، للحطاب ١/١٢٢، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ٤٤/٣.

وجه الدلالة:

أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: أَجَلَ لَنَا كَذَا وَحُرِّمَ عَلَيْنَا كَذَا، مِثْلُ قَوْلِهِ: أُمِرْنَا وَنُهِينَا، فَيَتِمُّ بِهِ الْإِحْتِجَاجُ^(٢)

ب . أَنَّهُ صَحَّ فِي كُلِّ مَقْدُورٍ عَلَى تَذَكِّيَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالذَّكَاءِ، وَالذَّكَاءُ: الشَّقُّ، وَهِيَ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا فِي الْجَرَادِ، فَارْتَفَعَ حُكْمُهَا عَنْهُ. ^(٣)

ج . أَنَّ الْجَرَادَ لَيْسَ فِيهِ دَمٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى إِنْهَارِهِ، فَيَحِلُّ بِلَا ذَكَاةٍ^(٤)

د . أَنَّهُ تُبَاحُ مَيْتَتُهُ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ سَبَبٌ، كَالسَّمَكِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ افْتَقَرَ إِلَى سَبَبٍ لَافْتَقَرَ إِلَى ذَبْحٍ وَذَابِحٍ وَآلَةٍ، كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ^(٥)

القول الثاني: لَا يُبَاحُ أَكْلُ الْجَرَادِ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ، وَذَكَاتُهُ هُوَ أَنْ يَقْتَلَ إِمَّا بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالِيهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ.

وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ وَمَنْ وَافَقَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (حَرَمْتَ عَلَيْكَ الْمَيْتَةَ) ^(٦)

(١) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ، ٣٤٠/١، مِنْ كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ حَدِيثَ رَقْمٍ: ٦٠٧

(٢) زَادَ الْمَعَادُ لِابْنِ الْقَيْمِ، ٣٤٥/٣، سَبَلَ السَّلَامِ لِلصَّنْعَانِيِّ، ٢٥/١.

(٣) الْمَحَلَّى لِابْنِ حَزْمٍ، ١٢٠/٦.

(٤) الْمَرْجِعُ وَالْمَكَانُ السَّابِقَانِ

(٥) الْمَغْنِيُّ لِابْنِ قَدَامَةَ، ٣٩٥/٩.

(٦) الْمَائِدَةُ/٣

وجه الاستدلال أن الجراد إذا مات حتف أنفه يكون من الميتة المحرمة،
قلا يُباح أكله. (١)

سبب الخلاف:

وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو: هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله
تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (٢)

فمن قال بأن الجراد الميت يتناوله اسم الميتة، قال بحرمة لدخوله تحت
نص الآية الكريمة.

ومن قال بأن ميتة الجراد مستثناة من عموم الآية الكريمة بنص الحديث
الشريف، قال بحل أكل ميتة الجراد، والله أعلم.

الترجيح: الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور لحصول الإجماع
على حل أكل الجراد دون ذكاة ولو مات حتف أنفه، قال النووي: "أما
السَّمَكُ والجرادُ فَحَلَالٌ، وَمَيِّتُهُمَا حَلَالٌ بالإجماع، ولا حاجة إلى ذبحه ولا
قَطْعِ رَأْسِ الجرادِ". (٣)

وقال ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية". (٤) والله
أعلم.

(١) مواهب الجليل، للحطاب ١/١٢٢، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ٤/٣.

(٢) المائدة/٣

(٣) المجموع للنووي، ٧٢/٩.

(٤) فتح الباري، ٦٢١/٩.

المطلب الثالث

الميتة المستثناة من التحريم

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بطهارة ميتة البحر وجواز أكلها^(١)

واستدلوا بما يلي:

أ. بقوله تعالى: (أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَاةِ)^(٢)

وقد فسر الفقهاء صيد البحر بما صح عن أبي بكر الصديق وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: "إن صيد البحر ما صيد منه، وطعامه ما مات فيه"^(٣)

ب . بقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته^(٤)

(١) البدائع ٥ / ٣٥، والمبسوط ١١ / ٢٤٩، والفتاوى الخانية ٣ / ٣٥٧، والتفريع ١ / ٤٠٥، والقوانين الفقهية ص ١٧٦، وبداية المجتهد ١ / ٧٦، ٤٦٥، والذخيرة ١ / ١٧٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١ / ٥٢، والشرح الصغير ٢ / ١٨٢، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٧، والمجموع ٩ / ٢٣، ٣١، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٩، والمغني ١٣ / ٢٩٩، ٣٤٥، وكشاف القناع ٦ / ١٩٢.

(٢) المائدة/٩٦.

(٣) فتح الباري ٩ / ٥٢٩، وسنن البيهقي ٩ / ٢٥٤.

(٤) أخرجه أبو داود ١٠ / ٦٤ ط حمص، والترمذي ١ / ١٠١، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد علل الفقهاء استثناء ميتة البحر بأن : الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها، وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات زيلها الذكاة لم يحرم بالموت، ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما، والسمك من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة^(١)

المبحث الثاني

تأثير الذكاة في المحرمات متى أدركت حياة

المقصود بالمحرمات: تلك الأصناف التي نصت عليها آية المائدة، التي وردت بتحريم أكلها في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَُمْ فِسْقٌ) ^(٢).

(١) زاد المعاد ٣ / ٣٩٣.

(٢) المائدة/٣

فالميتة: هي "الميتة": كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيّره، مما أباح الله أكلها، أهليّها ووحشيّها، فارقتها روحها بغير تذكية. وهذه لا يحل أكلها بإجماع الفقهاء ^(١)

وأما الدم المحرم : فهو الدم المسفوح، دون ما كان منه غير مسفوح، ^(٢) لأن الله جل ثناؤه قال: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) ^(٣)، فأما ما كان قد صار في معنى اللحم، كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفع، فإن ذلك غير حرام، لإجماع الجميع على ذلك. ^(٤)

وأما لحم الخنزير: فإن ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جميعه، لم يخص منه شيء وهذا محل اتفاق عند الفقهاء. ^(٥)

(١) جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر الطبري ٤٩٢/٩.
(٢) الدم المسفوح: السائل عن مقره في حال الحياة وبعد الموت من سائر الحيوانات وبعد التذكية من محل التذكية. والدم غير المسفوح: هو الذي لم يجر بعد موجب خروجه شرعاً أي لم يجر عند موجب الجريان من ذبح ونحر وجرح، ويشمل الباقي في العروق، والموجود في القلب حين شق الراشح من اللحم حال تقطيعه، وخرج منه الدم القائم بالحلي وما كان من الميتة. منح الجليل، ٢٨/١، وشرح الخرشي على مختصر خليل، ٨٧/١.

(٣) الأنعام/٤٥

(٤) جامع البيان، للطبري، ٤٩٣/٩.

(٥) بداية المجتهد، ٢٠٢/٢، تفسير الطبري، ٤٩٣/٩.

وأما قوله تعالى: "وما أهلّ لغير الله به"، فإنه يعني: وما ذكر عليه غير اسم الله. وكذا ما ذبح للآلهة وللأوثان، يسمى عليه غير اسم الله. (١)

وأما المنخقة: فهي التي توثق فيقتلها بالخنق وثاقها. (٢)

وأما الموقوذة: فهي التي تضرب بالخشب حتى توفد بها فتموت، وكان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي، حتى إذا ماتت أكلوها. (٣)

وأما المتردية: فهي التي تردى من الجبل، أو في البئر، فتموت. (٤)

وأما النطيحة: فهي: التي تتطحها الغنم والبقر فتموت. (٥)

وأما قوله تعالى: "وما أكل السبع"، أي وحرّم عليكم ما أكل السبع غير المَعْلَم من الصوائد. أي: ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان كالأسد والنمر والذئب. وفي الكلام إضمار - أي ما أكل منه السبع - لأن ما أكله السبع فقد فني (٦).

(١) المراجع السابقة ، نفس المواضع.

(٢) تفسير الطبري، ٩/٤٩٥

(٣) تفسير الطبري، ٩/٤٩٩.

(٤) تفسير الطبري، ٩/٤٩٩

(٥) تفسير الطبري، ٩/٥٠٠

(٦) تفسير الطبري، ٩/٥٠١

المقصود بتأثير الذكاة في المحرمات:

المحرمات المقصودة في بحثنا هي الخمسة الواردة في الآية الكريمة "الْمُنْخَنِقَةُ، وَالْمَوْقُوذَةُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ، وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ".

ومعنى تأثير الذكاة فيها، يعني أن هذه الأصناف الخمسة إذا أدركها المذكي وفيها نوع حياة، فذكاها أي ذبحها، فهل تؤثر التذكية فيها فتجعلها حلالاً، أم لا تؤثر التذكية فيها فتكون ميتة ويحرم أكلها؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن هذه الأصناف الخمسة أعنى: "الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ" إذا فارقتها الحياة دون تذكية، فهي حرام لا يحل أكلها.

كما اتفقوا على أن هذه الأصناف الخمسة إذا تم إدراكها في حالة يغلب على الظن أنها تعيش بعدها، كأن لم تُصَبَّ في مقتل من مقاتلتها، أي فيها حياة مستقرة بأن يحرك الحيوان يده أو رجله أو يمصع بذنبه، أو يطرف بعينه، أو يسيل منه الدم. وتمت تذكيته على الوجه الشرعي، فإنها تحل بذلك ويجوز الأكل منها.

واختلف الفقهاء فيما لو تم إدراكها قبل أن تفارقها الحياة في حالة يغلب على الظن أنها لا تعيش بعدها، بل تهلك بسبب الخنق أو الوقذ أو التردي، كما لو أُصِيت في مقتل من مقاتلتها، فإذا لم يتحرك الحيوان قبل

الذبح، ولم يحرك يدا ولا رجلا، لكن عُلِمَت حياته، أو ظُنَّت حياته، ثم
سال الدم عند ذبحه، أو تحرك بعد ذبحه فهل التذكية الشرعية تؤثر فيها
فتجعلها حلالا للأكل أم لا على قولين:

القول الأول: أن الزكاة لا تؤثر فيها وتكون حراماً لا يحل أكلها.

والى هذا: ذهب مالك في الرواية المشهورة عنه، والشافعي في أحد قوليهِ،
وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (١)

واستدلوا بما يلي:

أولاً: من الكتاب العزيز بقوله تعالى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) (٢)

وجه الاستدلال: إن (إِلَّا) الواردة في الآية الكرية تفيد الاستثناء المنقطع،
فيكون المعنى أن المنخقة وما ذُكر معها وما مات بالإصابة أو بلغ حالة
يغلب على الظن أنه لا يعيش معها، لا يعمل فيها الاستثناء، فتكون ميتة
ولا تؤثر فيها الزكاة، بل تبقى على أصل التحريم. (٣)

وبيان ذلك: "أن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف وهي حية وإنما
تعلق بها بعد الموت وإذا كان كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أن معنى

(١) بداية المجتهد لابن رشد، ٢٠٢/٢، المجموع للنووي ٨٨/٩، تحفة المحتاج لابن
حجر، ٣٢٠/٩، الإنصاف للمرداوي، ٢٩٨/١٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي،
١٢٠/٣، حاشية المقنع، ٥٣٩/٣

(٢) المائدة/٣.

(٣) تفسير الطبري ٥٠٧/٩.

قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ^(١) إنما هو لحم الميتة، وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرهما. أي لحم الميتة بهذه الأسباب، فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية وإنما علق بها بعد الموت؛ لأن لحم الحيوان محرم في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها، وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» ^(٢) وجب أن يكون قوله: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) ^(٣) استثناء منقطعاً ويكون المراد بالمنخقة وما ذكر معها على هذا ما مات بالإصابة أو بلغ حالة يغلب على الظن أنه لا يعيش معها. فلا يعمل فيها الاستثناء. ^(٤)

ثانياً: من المعقول: قالوا: إن الحيوان إذا لم تكن فيه حياة مستقرة وغلب الظن أنها تهلك بسبب الخنق أو الوقذ أو التردى أو النطح، فإن الذكاة لا تؤثر فيه قياساً على تذكية الحيوانات الميتة، بجامع انعدام الحياة في كل منهما. ^(٥)

القول الثاني: أن الذكاة تؤثر فيها، وتُصبح بعد الذبح حلالاً يجوز أكلها.

(١) المائدة/٣

(٢) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له / بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ٤.

(٣) المائدة/٣.

(٤) تفسير الطبري ٥٠٧/٩.

(٥) تفسير الطبري ٥٠٧/٩.

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين، وهو المشهور من قول الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن تيمية وابن عباس والزهري.^(١)

وقد استدلو بما يلي:

أولاً: من الكتاب العزيز بقوله تعالى (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) ^(٢)

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى استثنى الحيوان الذي تمت تذكيتة من المحرم، فدل ذلك على حله لأن الاستثناء من التحريم إباحة. فهو من الاستثناء المتصل. فتكون (إلا) الواردة في الآية الكريمة بمعنى (لكن) "أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم" ^(٣)

ثانياً من السنة: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُرْسِلْتَ كَلْبُكَ، فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ

(١) بدائع الصنائع للكاساني، ٥/٥٠، الفتاوى الهندية، ٥/٢٨٦، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ٣/٣٩، شرح مختصر خليل للخرشي، ٣/٢٣، بديهة المجتهد، لابن رشد، ٢/٢٠٢، الاستذكار لابن عبد البر، ٥/٢٦١، المجموع للنووي ٩/٨٨، تحفة المحتاج لابن حجر، ٩/٣٢٠، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣/١٢٠، حاشية المقنع، ٣/٥٣٩. ٥٤٩.

(٢) المائدة/٣.

(٣) بدائع الصنائع للكاساني، ٥/٤٠، العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، ص ٤٨٩. فتح القدير للشوكاني ٢/٩.

عليك فأدرَكْتَه حَيًّا، فاذْبَحْه، وإن أدركته قد قَتَلَ ولم يأْكُلْ منه، فأكْله، وإن وجَدْتَ مع كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَه وقد قَتَلَ، فلا تأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لا تدري أَيُّهُمَا قَتَلَه، وإن رَمَيْت سَهْمَكَ فاذْكُرِ اسمَ الله، فإن غاب عنك يومًا فلم تجِدْ فيه إلَّا أثرَ سَهْمِكَ، فكلْ إن شِئْتَ، وإن وجَدْتَه غَرِيقًا في الماء، فلا تأْكُلْ" (١)

وجه الاستدلال: قوله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "فأدرَكْتَه حَيًّا، فاذْبَحْه" يدلُّ على أَنَّ الذَّكَاءَ تُجْزَى في الحيوانِ الذي فيه بَقِيَّةُ حَيَاةٍ، وإلَّا صار مَيِّتَةً. (٢)

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ) (٣). هل هو استثناء متصل (٤) فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة الاستثناء المتصل، أم هو استثناء منقطع (٥) لا تأثير له في الجملة المتقدمة، إذ كان هذا أيضًا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب.

(١) أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩) واللفظ له.

(٢) المجموع للنووي ٨٤/٩

(٣) المائدة/٣.

(٤) الاستثناء المتصل: هو الذي له علاقة بالمتصل منه، فيخرج عن الجملة بعض ما يتناوله اللفظ، البيان والتحصيل لابن رشد، ٤٢٤/١.

(٥) الاستثناء المنقطع: هو الذي انقطع عن الكلام السابق، ولا يخرج شيئاً مما يتناوله اللفظ. البيان والتحصيل لابن رشد، ٤٢٤/١.

فمن قال: إنه متصل قال: الزكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة.

وأما من قال: الاستثناء منقطع فإنه قال: لا تعمل الزكاة فيها. ^(١)

الترجيح:

والراجح الذي تسانده النصوص هو القول الثاني، القائل بتأثير الزكاة في الأصناف الخمسة وذلك لما يلي:

أولاً: إن الاستثناء متصل كما قال الجمهور، "لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل منقطعاً إلا بدليل يجب التسليم به" ^(٢) ولا دليل فيبقى على الأصل.

ثانياً: إن هذا القول هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) ^(٣) فإذا أدرك وفيه حياة فذكي فقد تناوله عموم الآية ^(٤).

ثالثاً: ومما يدل على رجحان هذا القول أيضاً واقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي «أَنَّ جَارِيَةً لِّكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَزْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ» ^(٥) فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأُدْرِكْتُهَا فَذَبَحْتُهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ

(١) بداية المجتهد، ٢/٢٠٣.

(٢) تفسير القرطبي، ٦/٥٠.

(٣) المائدة/٣.

(٤) فتح الباري لابن حجر، ٩/٦٣٢.

(٥) سَلْع: بفتح أوله - والكسر أيضاً لغة - وإسكان ثانيه، بعده عين مهملة: جبل متصل بالمدينة، بل يعدُّ اليوم في وسط عمران المدينة، وفي الجنوب الغربي منه

- صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «كُلُوهَا»^(١) فقولته: (فأدركها فذبحتها) يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها في ساعتها، واشتراط الحياة المستقرة أو اشتراط أن لا تكون الإصابة قاتلة يخالف ظاهر النصوص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، ولم يستفصل. وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة، فعقرها، فوقع قصبها بالأرض، فأدركها، فذبجها بحجر، قال: يلقي ما أصاب الأرض، ويأكل سائرها. وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة، حتى تبين فيها آثار الموت، إلا أن فيها الروح. يعني فذبجت. فقال: إذا مصعت بذئبها، وطرفت بعينها، وسال الدم، فأرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون بأكلها بأس.^(٢) والله أعلم.

تقع المساجد السبعة .انظر: معجم ما استعجم، ٣/ ٧٤٧، والمعالم الأثرية في السنة والسير، ص: ١٤٢.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الذبائح والصيد، باب: ذبيحة المرأة والأمة

(٣/ ٤٥٨) (رقم: ٥٥٠٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

(٢) المغني لابن قدامة، ٩/ ٤٠٤

المبحث الثالث

تأثير الزكاة في الحيوانات التي يحرم أكلها.

المقصود بتأثير الزكاة في الحيوانات التي يحرم أكلها هو: حل الانتفاع بأجزاء هذه الحيوانات، كالجلد والعظم، والشعر، والعصب، والدهن، ونحو هذا.

وقد شاعَتْ في الآونة الأخيرة، ظاهرة استعمال دهون الخنزير في بعض الأطعمة، والأغذية والأدوية، وكذا استخدام جلود الحيوانات البرية والبحرية في تصنيع الملابس، والأحذية، وكثير من المنتجات الصناعية، ناهيك عن الاستعمالات الحديثة المتعددة للدم الحيواني ودخوله في كثير من الصناعات وكذا الدواء والغذاء للإنسان والحيوان، فما حكم الانتفاع بهذه الأجزاء من الحيوانات المحرمة؟ وهل الزكاة لها أثر في ذلك؟

ولتفصيل هذه المسألة نقول وبالله التوفيق:

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم أكل المحرمات من الحيوانات، كالميتة، والمنخنقة؟، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وكذا لحوم السباع، ونحوها مما حرم الشارع أكله.

واختلفت كلمة الفقهاء في الانتفاع بأجزاء الحيوانات المحرمة.

وسبب الخلاف بين الفقهاء في الانتفاع بأجزاء الحيوان هو اختلافهم في مسألة تبعية أجزاء الحيوان للحمة في الحلية والحرمة أم ليست بتابعة للحم؟

فمن ذهب إلى أن أجزاء الحيوان تابعة للحمة قال إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه من أجزاء الحيوان.

ومن ذهب إلى أن أجزاء الحيوان ليست بتابعة للحمة قال إن الذكاة وإن لم تعمل في اللحم، فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان، لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. ^(١)

ومن تلك المسائل التي اختلف الفقهاء فيها حول القول بحل الانتفاع بأجزاء الحيوان، أو عدم حل الانتفاع ما يلي:

أولاً: حكم الانتفاع بجلد الميتة.

اتفقت كلمة الفقهاء على نجاسة جلد الميتة قبل دبغه.

ولكنهم اختلفوا في طهارته بالدباغ على خمسة أقوال:

القول الأول: إن جلود الميتة تطهر كلها بالدباغ إلا الخنزير.

وإليه ذهب الحنفية وأحمد في رواية عنه، وهو مذهب الشافعية غير أنهم قالوا "بنجاسة جلد الكلب والخنزير، والمتولد من أحدهما، وقالوا لا يطهر

(١) بداية المجتهد، ٢/٢٠٤

ولو تم دبغه، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله
عنهما. (١)

واستلوا بما يلي:

أ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: " إِذَا دَبَغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ ". (٢)

ب. وفي رواية أخرى ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا
إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ» (٣)

وجه الاستدلال من الحديث الشريف: أن النبي صلى الله عليه وسلم
أباح الانتفاع بالإهاب " الجلد " بعد الدبغ بقوله " فقد طهر " والنص على
الطهارة دليل واضح على حل الانتفاع.

ج. عن مرثد بن عبد الله اليزني أنه قال: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعَلَةَ السَّبْيِيِّ
فَرَوًّا، فَمَسَسْتُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ
لَهُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نَوْتِي بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ

(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٢، ومغني المحتاج ١ / ٧٨، والمجموع ١ /
٢٣١، والمغني ١ / ٨٩، ٩٤

(٢) أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في سننه ، انظر: الجمع بين الصحيحين
البخاري ومسلم، لابن حميد الأزدي، ١٣١/٢ الحديث رقم: ١٢٨٨.

(٣) أخرجه الترمذي والنسائي، انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن
الأثير، ١٦/٧، الحديث رقم: ٥٠٨٠

وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ دَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَ بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " دَبَاغُهُ طَهُورُهُ".^(١)

وجه الاستدلال من هذا النص الشريف أن النبي صلى عليه وسلم أفتى بأن دبغ الجلد يجعله صالحاً للانتفاع به في الملبس والسقاء ونحوهما.

د. عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما قال: «تُصَدِّقُ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَتَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا»^(٢)

وجه الاستدلال من النص الشريف ظاهر، حيث أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الانتفاع بجلد الميتة، وحصر التحريم في اللحم فقط بقوله " إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا"

وأما استدلالهم على عدم جِلِّ الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما، فقد قالوا: إن الكلب والخنزير قد صار الإجماع عند الشافعية على تخصيصهما من عموم الأحاديث المبيحة لاستعمال جلود الحيوانات

(١) أخرجه مسلم، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، لابن حميد الأزدي ١٣٢/٢. الحديث: ١٢٣٠

(٢) أخرجه البخاري ومسلم، جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير الجزري، ١٠٧/٧، حديث رقم: ٥٠٨١

والانتفاع بها بعد دبغها، والعلة في ذلك أن الزكاة لا تؤثر في الكلب
والخنزير، فلا يطهران ولا يُباح استعمالهما أو الانتفاع بهما. (١)

المناقشة:

يُناقش ما استدل به أصحاب هذا القول بأن النصوص الدالة على حل
الانتفاع بجلد الميتة عامة، وتخصيصها بما سوى الكلب والخنزير بلا
مُخصص هو زيادة على النص، وهو غير جائز.

ويُجاب عن هذا: بأن تخصيص الكلب والخنزير له مخصص، بدليل
الاتفاق على إخراج الخنزير من العموم بنص الكتاب العزيز، والكلب في
معناه:

القول الثاني: عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ.

وإليه ذهب المالكية، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة
رضي الله عنهم وهو أشهر الروایتين عن أحمد قال المالكية: لكن يجوز
الانتفاع بذلك الجلد المدبوغ واستعماله مع نجاسته في اليابسات وفي الماء
وحده دون سائر المائعات. (٢)

واستدلوا بما يلي:

(١) المجموع للنووي، ١/ ٢٢٠.

(٢) الشرح الصغير للدريير ١ / ٥٢، والذخيرة ١ / ١٦٦، والتفريع ١ / ٤٠٨،
وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمغني ١ / ٨٩، ٩٤،
والإنصاف ١ / ٨٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢١ / ٩٥.

أ. قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة)^(١)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن التحريم عام في كل ميتة وهو يشمل كل جلد، فيحرم على هذا: الانتفاع بكل جلد من جلود الميتة، لورود التحريم بالنص.^(٢)

ب . عن عبد الله بن عكيم قال: "أتانا كتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"^(٣)

ووجه الاستدلال من الحديث الشريف ظاهر، حيث حرم الانتفاع بأي شيء من الميتة سواء أكان جلدًا أم لحماً أم غير ذلك من أجزاء الميتة.

ج . واستدلوا من المعقول بأن جلد الميتة جزء منها، فلم يظهر بشيء، كاللحم، ولأن المعنى الذي نجس به هو الموت، وهو ملازم له، لا يزول بالدبغ، فلا يتغير الحكم.^(٤)

(١) المائدة/٣

(٢) المجموع للنووي، ٢١٧/١.

(٣) أخرجه النسائي في الذبائح، والباقون في اللباس، قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له، قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ٢ قبل وفاته بشهرين، ويقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، انتهى. انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، ١٢٠/١.

(٤) المجموع للنووي، ٢١٧/١.

المناقشة:

وَيُنَاقِشُ هَذَا: بَأَن النّص القرآني الوارد في تحريم الميتة هو عام، مخصوص بالأحاديث الشريفة التي تجيز الانتقاع بجلد الميتة.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الاسْتِعْمَالِ قَبْلَ الدَّبْحِ، وَأَمَّا بَعْدُهُ فَلَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ بِأَن جِلْدَ الْمَيْتَةِ جُزْءٌ مِنْهَا، فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مَقَابِلَةِ نَصُوصٍ، فَلَا يُلْتَمَعُ إِلَيْهِ وَالثَّانِي إِنْ الدَّبَاغُ فِي اللَّحْمِ لَا يَتَأْتِي، وَلَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ، بَلْ يَمَحَقُهُ، بِخِلَافِ الْجِلْدِ، فَإِنَّهُ يَنْظَفُهُ وَيَطْيِبُهُ وَيَصْلِبُهُ. ^(١)

القول الثالث: أن جميع الجلود تطهر بالدباغ حتى الخنزير.

وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية وسحنون وابن عبد الحكم من المالكية وهو مذهب داود وأهل الظاهر. ^(٢)

واستدلوا بما يلي:

١. عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ" ^(١)

(١) المجموع، ٢١٩/١.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٨. والبدائع ١ / ٨٥، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩ والشرح الصغير للدردير ١ / ٥٢، والذخيرة ١ / ١٦٦، المجموع للنووي ١ / ٢١٧.

وجه الاستدلال: أن النص الشريف عام في إباحة الاستمتاع بجلود الميتة جميعها متى دُبغت، فدل هذا على جواز الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وسائر الحيوانات. (٢)

ب . بحديث عن ابن عباس قال: "أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إِنَّهُ مَيْتَةٌ. قال: "دَبَاغُهُ يُذْهَبُ حَبَثَهُ - أَوْ نَجَسَهُ، أَوْ رَجَسَهُ" (٣)

وجه الاستدلال من الحديث الشريف: إباحة النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من سقاء تم اتخاذ من جلد الميتة، فدل هذا على جواز الانتفاع به في سائر الوجوه.

(١) أخرجه: مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٨، كتاب الصيد ٢٥، باب ما جاء في جلود الميتة ٦، الحديث ١٨. وأبو داود في السنن ٤/ ٣٦٨، كتاب اللباس ٢٦، باب في أهُب الميتة ٤١، الحديث ٤١٢٤. والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٧٦، كتاب الفرع والعتيرة ٤١، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ٦. وابن ماجه في السنن ٢/ ١١٩٤، كتاب اللباس ٣٢، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ٢٥، الحديث ٣٦١٢. وانظر: مصابيح السنة للبغوي، ٢/ ٢٣٥، حديث رقم ٣٥٥.

(٢) المجموع للنووي، ١٠/ ٢١٨.

(٣) المسند ٥/ ٦٤ حديث رقم: ٢٨٧٨، وصححه ابن خزيمة ١/ ٦٠ (١١٤)، والحاكم ١/ ١٦١ وقال: هذا حديث صحيح، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. وأقره على ذلك الذهبي.. وقال محققوا المسند: حسن، وهذا سند رجاله ثقات غير أخي سالم. وانظر: جامع المسانيد لابن الجوزي، ٤/ ١٣٦.

المناقشة:

ويُنَاقَشُ ما استدل به أصحاب هذا القول بأن العموم الوارد في إباحة الاستمتاع بجلد الميتة مخصوص بما ورد في شأن الكلب والخنزير، فالثاني مُستثنى بنص الكتاب العزيز، والأول في معناه من حيث نجاسة العين.

القول الرابع: إنما يظهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً حال الحياة.

وإليه ذهب أحمد في رواية عنه. ^(١)

واستدل الحنابلة لهذه الرواية بما روى عن أبي المَلِيح عن أبيه رضي

الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ" ^(٢)

وجه الاستدلال: أن النهي عن استعمال جلود السباع، لأجل أن الزكاة

لا تؤثر فيها لعدم حلِّ أكلها، وما دام الشارع الحكيم قد نهى عنها، فالنهي

عام يشمل الاستعمال والبيع ونحوه.

المناقشة:

(١) المغني ١ / ٨٩، ٩٤، والإنصاف ١ / ٨٦،

(٢) مصابيح السنة لأبي الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،

١/٢٣٤، حديث رقم: ٣٥١.

وَيُنَاقِشُ هَذَا: بَأَن الْقَوْلَ بِطَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيِّتَةِ الَّتِي كَانَتْ طَاهِرَةً حَالِ الْحَيَاةِ
بِالدَّبْعِ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّهُ جِلْدٌ مَا لَيْسَ مَأْكُولًا حَالِ الْحَيَاةِ إِنَّمَا هُوَ جِلْدُ
حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، فَأَشْبَهَ الْمَأْكُولَ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ جُلُودِ السَّبَاعِ، فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّهْيَ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السَّبَاعِ إِنَّمَا كَانَ لِكُونِهَا لَا يُزَالُ عَنْهَا
الشَّعْرُ فِي الْعَادَةِ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُقْصَدُ لِلشَّعْرِ كَجُلُودِ الْفَهْدِ وَالنَّمْرِ، فَإِذَا دُبِغَتْ
بَقِيَ الشَّعْرُ نَجَسًا فَإِنَّهُ لَا يَطْهَرُ بِالدَّبْعِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ فَلِهَذَا نَهَى
عَنْهَا. وَالثَّانِي: أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ الدَّبْعِ. (١)

الْقَوْلُ الْخَامِسُ: وَهُوَ طَهَارَةُ جِلْدِ مَيِّتَةِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ اللَّحْمَ فَقَطْ.

وَالِيهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبِي دَاوُدَ وَاسْحَقُ ابْنُ رَاهَوِيَّةٍ وَأَبُو ثَوْرٍ
وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ (٢)

وَاسْتَدْلُوا بِمَا يَلِي:

١. بِمَا رَوَى عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُقْتَرَشَ" (١)

(١) المجموع للنووي، ٢٢٠/١.

(٢) مدارج السالكين ٣ / ٢٦٠، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، وأحكام القرآن
لابن العربي ٣ / ١١٦٩، وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والإنصاف ١ / ٩٢، المجموع
للنووي، ٢١٧/١.

وجه الاستدلال من الحديث الشريف: أن جلود الحيوان غير المأكول اللحم لو كانت تطهر بالدباغ لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراشها مطلقاً. (٢)

ب . وأما المعقول فقالوا: ولأن هذه الحيوانات لا تؤثر الزكاة فيها لتحريم الشارع أكل لحومها، فلم يحل الانتفاع بها. (٣)

المناقشة:

ويُنَاقَشُ هذا بما نوقش به الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع، إذ لا معنى للفرقة بين جلد مأكول اللحم وغيره.

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف بين الفقهاء هو: هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة، أم ليست بتابعة للحم؟

فمن قال إنها تابعة للحم قال: إذا لم تعمل الزكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه.

(١) مصابيح السنة لأبي الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي،

٢٣٤/١، حديث رقم: ٣٥١.

(٢) المجموع للنووي، ١/٢٢٠.

(٣) المرجع والمكان السابقين.

ومن رأى أنها ليست بتابعة قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان، لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه. (١)

الترجيح:

ونحن نرى . والله أعلم . رجحان ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من القول بطهارة جلود الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، وذلك لما يلي:

١. أن الاحتجاج بالأحاديث التي يدل عمومها على جواز الانتفاع بجلود الميتة جميعها فهو مخصوص بغير الكلب والخنزير لما سبق من تخصيص الخنزير بنص القرآن الكريم، والكلب في معناه
٢. وأما من قال يؤثر الدباغ في المأكول خاصة، فقد تعلقوا بخصوص السبب في شاة ميمونة وليس ذلك بصحيح، فإن اللفظ عام مستقل بالإفادة

٣. إن سبب نجاسة الجلود بالموت، إنها بانقطاع الحياة عنها تتعرض للبلى والعفن والنتن، فإذا دُبغت لم تتعرض للتغير، وقد بطل حمل اللفظ على خصوص السبب وامتنع التعميم لما ذكرنا في جلد الخنزير، وأرشد

(١) بداية المجتهد، ٢/٢٠٤

الدباغ إلى معنى يضاهي به المدبوغ الحيوان في حال الحياة، فإن الحياة دافعة للعفن والموت جالب له والدباغ يرده إلى مضاهاة الحياة في السلامة من التغير، فانتظم بذلك اعتبار المدبوغ بالحي ولذا قال الشافعي رضي الله عنه : "كل ما كان في الحياة طاهرا عاد جلده بالدبغ طاهرا وما كان نجسا لا يطهر" ثم ثبت عنده نجاسة الكلب من نجاسة لعابه.

والله أعلم.

ثانياً: صوف الميته وشعرها:

اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بصوف وشعر ووبر ميته الحيوان المأكول اللحم على قولين:

القول الأول: إن صوف الميته، وشعرها، ووبرها، طاهر، يجوز الانتفاع به.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء: من الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب، وهو قول الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر وغيرهم.^(١)

(١) تبيين الحقائق للزيلعي ١ / ٢٦، أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٩، والبدائع للكاساني، ١ / ٦٣، الذخيرة للقرافي، ١ / ١٨٣، والتفريع ١ / ٤٠٨، ومدارج السالكين ٣ / ٢٦٠، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٣ / ١١٦٩، وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والمجموع ١ / ٢٣١، والإنصاف ١ / ٩٢، وتفسير الرازي ٥ / ١٥، والمغني ١ / ١٠٦.

الأدلة:

واستدلوا على ذلك:

أ- بقوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين)^(١)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن الله سبحانه وتعالى، قد عمّ الجميع بالإباحة من غير فصل بين المُذَكَّى منها، وبين الميتة، ولأنه عز وجل ذكر هذه الأشياء في معرض المَنَّة، والمنَّة لا تقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به.

ب . كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الميتة: "إنما حرم أكلها"^(٢)

ووجه الاستدلال كما قال الجصاص: "فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن مراد الله تعالى بتحريم الميتة، فلما لم يكن الشعر والصوف والعظم ونحوها من المأكول لم يتناولها التحريم"^(٣)

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقَرْنِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ".^(١)

(١) النحل/٨٠

(٢) أخرجه البخاري، فتح الباري ٣ / ٣٥٥ ، ومسلم ١ / ٢٧٦ ط عيسى

الخلبي، من حديث ابن عباس

(٣) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٥٠

ووجه الاستدلال من هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الانتفاع بصوف الميتة وشعرها وقرنها بعد غسله بالماء.

المناقشة:

ونُوقش هذا بأن شعر الميتة وصوفها تابع للميتة، فيكون نجساً لدخوله تحت تحريم الميتة.

وأجيب عن هذا: بأن الآية عامة، وقد خصصتها الأحاديث الشريفة من هذا الباب كحديث أم سلمة رضي الله عنها.

ج . واستدلوا من المعقول فقالوا: بأن هذه الشعور والأصواف والأوبار أجسام منتقع بها، لعدم تعرضها للتعفن والفساد، فوجب أن يُقضى بطهارتها كالجلود المدبوغة، ولأن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، وهي غير موجودة في هذه الأشياء. (٢)

القول الثاني: إن صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس، لا يحل الانتفاع به.

وإليه ذهب الشافعية في المذهب، وأحمد في رواية عنه.

(١) أخرجه الدارقطني في السنن، وقال "يُؤسَفُ بِنُ السَّفَرِ مَثْرُوكٌ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ

غَيْرُهُ" سنن الدارقطني ، ١٦/٦٨ الحديث : ١١٦

(٢) أحكام القرآن لابن العربي ٣ / ١١٦٩ . الذخيرة ١ / ١٨٤ .

الأدلة:

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أ. قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) ^(١) .

وجه الاستدلال: إن صوف الميتة وشعرها ووبرها جزء من الميتة، فالآية الكريمة عامة في تحريم سائر أجزائها. ^(٢)

ب . واستدلوا من المعقول بقولهم: "ولأنَّه أي الصوف والشعر والوبر جزءٌ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَتَجَسَّ بِالْمَوْتِ كَالْأَعْضَاءِ" ^(٣)

المناقشة:

نُوقِشَ ما استدل به الشافعية ومن وافقهم بأن الآية الكريمة الواردة في تحريم الميتة من قبيل العام الذي خُص بالأحاديث الدالة على حل الانتفاع بالصوف والشعر ومنها حديث أم سلمة السابق.

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة كما ذكرنا من قبل هو اختلافهم في تبعية أجزاء الحيوان للحم أو عدم تبعية لها ، فمن قال بتبعية اللحم، قال بالحرمة ، ومن قال بأنها غير تابعة للحم قال بجواز الانتفاع. ^(١)

(١) سورة المائدة / ٣.

(٢) المجموع للنووي ٢٣١/١، وتفسير الرازي ٥ / ١٥، والمغني ١ / ١٠٦.

(٣) الإقناع للخطيب ٢ / ٢٣٣، المجموع ٢ / ٥٤٧

والله أعلم.

الترجيح:

والراجع . والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بطهارة أصواف الميته وأوبارها وأشعارها، وذلك لتخصيصها لعموم الآية الكريمة الدالة على تحريم الميته. ولعموم البلوى في عصرنا هذا حيث يدخل شعر الميته ووبرها في كثير من الصناعات الحديثة وخاصة ما يتم استيراده من البلاد غير المسلمة.

والله أعلم.

ثالثاً: عظم الميته وقرنها:

اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بعظم الميته من الحيوان المأكول اللحم وقرنها وظلفها وظفرها على قولين:

القول الأول: إن الانتفاع بعظم الميته من الحيوان المأكول اللحم وقرنها وظلفها لا يحل لكونها نجسة.

وإليه ذهب الشافعية في المذهب والمالكية والحنابلة. (٢)

(١) بداية المجتهد، ٢/ ٢٠٤.

(٢) بدائع الصنائع ١ / ٦٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٩، والإنصاف للمرداوي ١ / ٩٢، والذخيرة للقرافي ١ / ١٨٣، والتفريع لابن جلاب ١ / ٤٠٨، وتفسير الرازي ٥ / ١٥، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩،

واستدلوا بقوله تعالى (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة).^(١)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: أنها دلت على أن العظام كانت حية، فصارت عند الموت ميتة، وإذا ثبت أنها ميتة، وجب أن يحرم الانتفاع بها لعموم قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة)^(٢)

ونوقش هذا: بأن هذه الأجزاء من الميتة لم يُذكر تحريمها في القرآن بنص صريح، فيكون من المسكوت عنه، وما سكت عنه الشارع فهو عفو.

القول الثاني: إن الانتفاع بعظم الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرنها وظلفها يحل الانتفاع بها.

والإيه ذهب الحنفية وابن وهب من المالكية وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية.^(٣)

وبداية المجتهد ١ / ٧٨، وأحكام القرآن للسيا الهراس ١ / ٧٢، والمجموع شرح المذهب ١ / ٢٣١، والمغني لابن قدامة ١ / ٩٧، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٢٦.

(١) سورة يس / ٧٨ - ٧٩.

(٢) سورة المائدة / ٣.

(٣) بدائع الصنائع ١ / ٦٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٩، والإنصاف للمرداوي ١ / ٩٢، والذخيرة للقرافي ١ / ١٨٣، والتقرع لابن

واستدلوا: بقوله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ^(١)

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن الله تعالى قد أخبر أن التحريم مقصور على ما يتأتى فيه الأكل. وقال النبي عليه السلام: "إنما حرم من الميتة لحمها" ^(٢) فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن مراد الله تعالى بتحريم الميتة. فلما لم يكن العظم والقرون ونحوها مما ذكرنا من المأكول لم يتناولها التحريم، ومن حيث خصصنا جلد الميتة المدبوغ بالإباحة للآثار الواردة فيه وجب تخصيص القرون والعظم وما لا يتأتى فيه الأكل من جملة المحرم بالآثار المروية فيها مما قدمنا ذكره.

كما استدلوا: بأنها أجسام منتفع بها، غير متعرضة للتعفن والفساد، فوجب أن يقضى بطهارتها، كالجلود المدبوعة، ولأن نجاسة الميتات ليست لأعيانها، بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، وهي ليست موجودة في هذه الأشياء ^(٣)

جلاب ١ / ٤٠٨، وتفسير الرازي ٥ / ١٥، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩،
وبداية المجتهد ١ / ٧٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٩٧.

(١) الأنعام: ١٤٥

(٢) سبق تخريجه

(٣) بدائع الصنائع ١ / ٦٣، وتبيين الحقائق ١ / ٢٦، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٩، والإنصاف للمرداوي ١ / ٩٢، والذخيرة للقرافي ١ / ١٨٣، والتفريع لابن جلاب ١ / ٤٠٨، وتفسير الرازي ٥ / ١٥، والكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩،

ونوقش هذا: بأن أية تحريم الميتة قد تناولت الميتة بجميع أجزائها، والعظم والقرون منها، فتكون حراماً لا يحل الانتفاع بها.

وأجيب عنه: بأن المراد بالآية ما يتأتى فيه الأكل، والدليل عليه قوله تعالى في الآية الأخرى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ^(١) والعظم والقرون ليست منها فلا يشملها التحريم.

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف كما قلنا سابقاً: هو اختلاف الفقهاء في تبعية أجزاء الحيوان للحمه من عدمها، فمن قال بحل الانتفاع بنى ذلك على عدم تبعية أجزاء الحيوان للحم ومن قال بالحرمة، بنى ذلك على القول بتبعية أجزاء الحيوان للحمه ^(٢) والله أعلم.

الترجيح:

والراجح من وجهة نظرنا . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من القول بحل الانتفاع بقرون الميتة وعظمها، وذلك لأن عظم الميتة وقرونها شأنه شأن الجلد ، لما كان خروج الجلد عن حد الأكل

وبداية المجتهد ١ / ٧٨، وأحكام القرآن للكبيا الهراس ١ / ٧٢، والمجموع شرح المذهب ١ / ٢٣١، والمغني لابن قدامة ١ / ٩٧، ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٢٦.

(١) الأنعام: ١٤٥

(٢) بداية المجتهد، ٢/٤

بالدباغ مبيحا له وجب أن يكون ذلك حكم سائر ما لا يتأتى فيه الأكل منها من الشعر والصوف ونحوهما ويدل عليه أيضا أن الأخبار الواردة في إباحة الانتفاع بجلود الميتة لم يذكر فيها حلق الشعر والصوف عنها، بل فيها الإباحة على الإطلاق، فافتضى ذلك إباحة الانتفاع بها بما عليها من الشعر والصوف، ولو كان التحريم ثابتا في الصوف والشعر لبينه النبي عليه السلام لعلمه أن الجلود لا تخلو من أجزاء الحيوان مما ليس فيه حياة وما لا حياة فيه لا يلحقه حكم الموت. والدليل على أن الشعر ونحوه لا حياة فيه، أن الحيوان لا يألم بقطعها، ولو كانت فيه حياة لتألم بقطعها كما يؤلمه قطع سائر أعضائه، فدل ذلك على أن الشعر والصوف والعظم والقرن والظلف والريش لا حياة فيها، فلا يلحقها حكم الموت، ووجود النماء فيها لا يوجب لها حياة؛ لأن الشجر والنبات ينميان ولا حياة فيهما ولا يلحقهما حكم الموت، فكذلك الشعر والصوف. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه السلام: "ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت" ويبين منها الشعر والصوف ولا يلحقهما حكم الموت، فلو كان مما يلحقهما حكم الموت لوجب ألا يحل بذكاة الأصل كسائر أعضاء الحيوان، فدل ذلك على أنه لا يلحقه حكم الموت ولا يحتاج إلى ذكاة. ^(١) والله أعلم.

(١) أحكام القرآن للجصاص، ١/١٤٩.

رابعاً: الانتفاع بالميتة في علف الحيوانات:

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على تحريم انتفاع الآدمي بالميتة انتفاعاً مباشراً، في طعامه كطهيها، أو شيها، أو استخدامها في أي نوع من الطعام قبل استحالة مادتها. (١)

واختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالميتة عن طريق إطعامها للدواب والبهائم أو الكلب المعلم والطير والبازي المعلم أو دخولها في الأعلاف للحيوانات ونحو هذا على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز الانتفاع بالميتة على أي وجه من الوجوه.

واليه ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه. (٢)

واستدلوا بما يلي:

أ. قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (٣).

(١) الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمغني ١٣ / ٣٥٠، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٢٥، والمبدع ٩ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٦ / ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٩.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٣٢، وتفسير الفخر الرازي ٥ / ١٦.

(٣) سورة المائدة / ٣.

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة قد حرمت الميتة مطلقاً، وإذا أُطعمت الميتة للحيوان أو دخلت في علفه، فإن هذا يُعدُّ نوعاً من الانتفاع بالميتة، وقد حرم الله الميتة تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها، مؤكداً به حكم الحظر، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم به. (١)

ونُوقش هذا: بأن الآية الكريمة قد دلت على تحريم أكل الميتة على الآدمي، بدليل "كاف" الخطاب في قوله تعالى (عليكم) وأما الانتفاع بها فلم يشمل النص الكريم.

وأجيب عن هذا: بأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والانتفاع به، فيكون إطعام الميتة للحيوان محرماً.

ب . واستدلوا من المعقول، فقالوا: إن إطعام الميتة للحيوان، يُقاس على أكلها، بجامع الانتفاع في كُلِّ، وأكل الميتة محرم بالنص، فيكون الانتفاع بها محرم أيضاً. (٢)

(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٣٢، المغني ١٣ / ٣٥٠.

(٢) الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمغني ١٣ / ٣٥٠، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٢٥، والمبدع ٩ / ٢٠٤، وكشاف القناع ٦ / ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٩٩.

ويؤيد دليل القياس: ما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.^(١)

وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.^(٢)

القول الثاني: يري جواز إطعام الميتة للحيوان غير مأكول اللحم، فيجوز إطعامه للكلب المعلم والبازي المعلم جواز، وكذا علف دوابه التي لا يؤكل لحمها.

واستدلوا لذلك:

أ. بأن هذه الحيوانات ليست بمأكولة اللحم، ولأنه استعمال للميتة فيما يجري مجرى الإتلاف، وليس فيه ضرر.^(٣)

(١) أخرجه البخاري، في صحيحه، ٨٤/٣، الحديث: ٢٢٣٦، ومسلم في صحيحه، ١٢٠٧/٣، الحديث: ١٥٨١

(٢) أخرجه أحمد في المسند، ٤١٦/٤، الحديث رقم: ٢٦٧٨، قال الأرنؤوط "إسناده صحيح، بركة المجاشعي كنيته أبو الوليد، وقيل: أبو العريان، روى له أبو داود وابن ماجه، ووثقه أبو زرعة وابن خفون والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"

(٣) الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمغني ١٣ / ٣٥٠،

وُثِّقَ هذا: بأن المحرم هو الانتفاع بالميتة على أي وجه من الوجوه، سواء أكان ذلك بالأكل أم كان بالانتفاع، فيكون إطعام الميتة للحيوانات داخل في النهي الذي يشمل سائر وجوه الانتفاع بالميتة.

ب . ولأن الحيوانات التي ترعى في المراعي على اختيارها . أي المراعي المفتوحة . كبطون الأودية، والصحاري، فهذه الحيوانات تأكل الميتة والنجاسة ومعلوم أنها مباحة الأكل، فيُقاس عليها إطعام الميتة للحيوان ودخولها في علفه بجامع جواز الانتفاع في كل منهما. ^(١)

وُثِّقَ هذا: بأن قياس إطعام الميتة للحيوان على رعيه في البوادي قياس مع الفارق، فيكون فاسداً، **ووجه الفرق:** أن الحيوانات التي ترعى في البوادي على اختيارها إنما هو مما تَعُمُّ به البلوى، فيكون في حكم المعفو عنه من الشارع، وهو علة قاذحة في الحكم، وأما إطعام الميتة للحيوان، فليس فيه هذا المعنى، بل إن إطعام الميتة للحيوان مقصود فيه دون حاجة تستدعي ذلك، وهذا الفرق جوهري، يقدر في الحكم، فيكون القياس فاسداً.

القول الثالث: يري جواز إطعام الميتة للحيوان وجعلها علفاً له مطلقاً، سواء أكانت الحيوانات التي تذل الميتة في طعامها مأكولة اللحم أم كانت غير مأكولة اللحم.

(١) الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، والمغني ١٣ / ٣٥٠، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ٢٥،

وإليه ذهب بعض المالكية. (١)

واستدل هؤلاء بما استدل به أصحاب القول الثاني من أن إطعام الميتة للحيوان، إنما هو استعمال للميتة فيما يجري مجرى الإيتلاف، وليس فيه ضرر.

ويُناقش هذا بما نوقش هذا الدليل في موضعه فلا حاجة لتكراره.

الترجيح:

والرأي الذي نميل إليه . والله أعلم . هو القول بجواز إطعام الميتة للحيوانات غير مأكولة اللحم على سبيل الصدقة والتبرع لا على سبيل الانتفاع بالبيع ونحوه ، وذلك لأن الإنسان يؤجر على ما يعطيه للحيوان؛ لما روى البخاري ، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَنُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبَنُرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ . (٢)

(١) الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، الحديث رقم " ٢٤٦٦ " ومسلم في صحيحه الحديث رقم: ٢٢٤٤ .

قال النووي رحمه الله " (في كل كبد رطبة أجر) معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجف جسمه وكبدته. (١)

وأما إذا دخلت الميتة في الأعلاف على نحو ما نراه اليوم في الأسواق، فإن هذا يُعدُّ من قبيل الانتفاع المنهي عنه وهو حرام.

وأما الانتفاع بإطعام الميتة للحيوان المأكول اللحم أو دخولها في علفه، فالراجح الذي نراه هو ما ذهب إليه أصحاب القول من تحريم دخول الميتة في سائر أطعمة الحيوانات وأعلافهم لعموم النهي الوارد في الآية الكريمة عن الميتة هـ وهو يشمل الأكل والانتفاع بأي وجه، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. والله أعلم.

خامساً: طلاء الجلود والسفن والاستصباح بدهن الميتة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى عدم جواز الانتفاع بدهن الميتة باستصباح ولا غيره، ولا أن تطلّى به ظهور السفن والجلود

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (٢)

(١) شرح النووي على مسلم، ٢٤١/١٤

(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٥، وأحكام القرآن الكريم للكنيا الهراس ١ /

٧١، وتفسير الرازي ٥ / ١٦. والمغني ١٣ / ٤٤٩.

واستدلوا على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله، شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"^(١)

ووجه الاستدلال من الحديث الشريف: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين أن الله إذا حرم شيئاً حرمه على الإطلاق، ودخل تحت تحريمه سائر ضروب الانتفاع به، ومنها البيع.^(٢)

القول الثاني: جواز دهن ظهور السفن بشحوم الميتة

واليه ذهب عطاء بن رباح^(٣)

ويمكن الاستدلال لمذهب عطاء بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق " لا، هو حرام" فيقال: إن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم "هو حرام" يعود على البيع أي بيع شحوم الميتة، ومن ثم فإن دهن ظهور السفن بشحوم الميتة يكون من قبيل الانتفاع وليس البيع، فيكون خارجاً عن محل النهي.

(١) أخرجه البخاري، فتح الباري ٤ / ٤١٤ ، ومسلم ، ٣ / ١٢٠٧

(٢) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٥ ،

(٣) أحكام القرآن للجصاص ١ / ١٤٥ ، وأحكام القرآن للكنيا الهراس ١ / ٧١ .

قال ابن حجر "وسياق الحديث مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله هو حرام البيع لا الانتفاع "

ونُوقش هذا: بأن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم " لا، هو حرام " عام فيشمل البيع والانتفاع فيكون المعنى لا تبيعوا ولا تنتفعوا من الميتة بشيء " وهو قول أكثر أهل العلم.

القول الثالث: يجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره.

واليه ذهب ابن تيمية وحكى أن الإمام أحمد أوماً إلى ذلك في رواية ابن منصور^(١)

واستدل الخطابي لما ذهب اليه ابن تيمية وغيره على جواز الانتفاع، بإجماع الفقهاء على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذاك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق في ذلك بين المسألتين. " ^(٢)

ونُناقش هذا بمثل ما نُوقش به استدلال القول الثاني، حيث إن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم " لا، هو حرام " عام يشمل البيع والانتفاع، والله أعلم.

(١) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص ٢٦.

(٢) سبل السلام للصنعاني، ٦ / ٣

وسبب الخلاف: هو اختلاف الفقهاء في مفهوم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (لا، هو حرام" هل الضمير عائد إلى البيع، أي بيع اللحم أم هو عائد إلى الانتفاع بأجزاء الميتة ومنها الدهن.

فمن ذهب إلى أن الضمير عائد على الانتفاع حرم الانتفاع بأجزاء الميتة ومنها الدهن، قال بالمنع، ومن ذهب إلى الضمير عائد إلى البيع، قال بجواز الانتفاع بأجزاء الميتة ومنها الدهن والله أعلم.

الترجيح:

ونحن نرى أن الراجح . والله أعلم أن القول بتحريم الانتفاع بدهن الميتة وشحومها هو الأولى لموافقته لعموم النهي الوارد في الميتة، وإذ ما انضم إلى هذا ما قاله جمهور العلماء من أن العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير هي النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، هذا مع ضمنية أن القول بتحريم الانتفاع بدهون الميتة فيه حمل للنهي على ظاهره، والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التفتير عنها^(١). والله أعلم.

(١) فتح الباري لابن حجر، ٤/٤٢٦.

الفصل الثاني

في أنواع التذكية وكيفيةها

تمهيد:

الحيوان الذي يُراد تذكيته، إما أن يكون حيواناً مُستأنساً، وإما أن يكون متوحشاً، فالمستأنس كالإبل والبقر والغنم والطيور والدجاج يدرجها الفقهاء تحت نوع خاص من الحيوان يُسمى "المقدور عليه"، وأما إذا كان الحيوان متوحشاً غير مستأنس، فهذا يدرجه الحيوان تحت نوع خاص من الحيوان يُسمى "غير المقدور عليه"، والحيوان المقدور عليه إما أن يكون من الإبل أو يكون من غيرها، ولكل نوع من هذا الحيوانات ذكاة تخصه وبيان ذلك على النحو الآتي:

الذكاة الاختيارية والاضطرارية

قسم الفقهاء ذكاة الحيوان من حيث القدرة عليه إلى ذكاة اختيارية، وذكاة اضطرارية.

. الذكاة الاختيارية: تكون في الحيوان المستأنس المقدور عليه بالذبح، كالإبل والبقر والغنم والماعز والأوز والدجاج ونحوها.

وتحصل ذكاة هذا النوع من الحيوان بالذبح فيما يُذبح، والنحر فيما يُنحر على التفصيل الذي سيأتي بعد قليل.

الذكاة الاضطرارية: وتكون في الحيوان المتوحش غير المقدور عليه أو الحيوان المستأنس الذي شرد أو هرب ولم تمكن السيطرة عليه وهي تحصل بطريق الجرح أو العقور وهو رمي الحيوان بالسلاح أو بالطلق الناري، أو السهم في أي موضع في بدنه ، بحيث يحصل منه إنهار الدم حتى يهلك، فإذا حصل هذا يكون الحيوان حلال الأكل بالعقر، والسبب في ذلك هو عدم القدرة عليه. (١)

وسياأتي لذلك مزيد بيان عند دراستنا لأحكام الصيد إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الفصل نتحدث عن كيفية ذكاة الحيوان المقدور عليه، وهذا يقتضي الحديث عن أنواعها، وعليه: فينقسم هذا الفصل إلى مبحثين: أخصص الأول منهما لدراسة أنواع ذكاة الأنعام، والثاني منهما لدراسة كيفية ذكاة الأنعام، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: في أنواع ذكاة الأنعام.

المبحث الثاني: في كيفية ذكاة الأنعام.

(١) بدائع الصنائع، ٤٠/٥، الفتاوى الهندية، ٢٥٨/٥، المنتقى شرح الموطأ للباقي، ١٠٨/٣، الأم للإمام الشافعي، ٢٦٢/٢، نهاية المحتاج للرملي، ١١١/٨، المحلى لابن حزم ، ١٢٢/٦.

المبحث الأول

أنواع ذكاة الأنعام

المقصود بأنواع الذكاة أي الطرق الواجب اتباعها في تذكية الأنعام، وهما طريقتان: الذبح والنحر.

فالمقصود بالنحر: قطع عروق الإبل الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها، لأنه موضع منها لا لحم عليه، وما سوى ذلك من الحلق عليه لحم غليظ فالنحر أسفل من الذبح. (١)

والمقصود بالذبح: قطع الخُلُقُوم والودجين وهما العرقان اللذان يحملان الدم إلى الرأس من باطن عند النّصِيل، وَهُوَ مَوْضِعُ الذَّبْحِ من الحلق ومَوْضِعُهُ المَذْبَح. (٢)

ونظراً لأن الحيوان طويل العنق، كالإبل والنعام، والزراف، والأوز، لا يكون في رقبته لحم كثير فالأولى فيه عند الفقهاء هو النحر، يعني طعن الحيوان في أسفل رقبته من ناحية الصدر.

وأما الحيوان قصير العنق، كالبقرة والغنم والجاموس والماعز، والدجاج، فالأولى فيه عند الفقهاء هو الذبح، وهو طعن الحيوان في أعلى عنقه من

(١) التعريفات الفقهية، محمد عليم الإحسان المجددي البركتي، ص: ٢٢٦. المخصص لابن سيدة، ٢/٢٢٦.

(٢) لسان العرب لابن منظور، ٢/٣٤٦، العين لفراهيدي، ٣/٢٠٢، تهذيب اللغة للهروي، ٤/٢٧١. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، ٢١٣

ناحية الرأس، ولذا قال الفقهاء "يستحب في الإبل النحر، وفي الغنم ونحوها الذبح" (١)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح، وأن من السنة في ذكاة الغنم والطير: الذبح، وأن من السنة في ذكاة الإبل: النحر، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر.

واختلفوا في العكس: هل يجوز النحر في الغنم والطير، والذبح في الإبل على قولين:

القول الأول: إن عكس المذكي فنحر البقر والغنم، أو ذبح الإبل فهو جائز.

وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة.

واستدلوا: بأن المقصود فري الأوداج، وإنهار الدم ليطيب به اللحم، ولأن الكل موضع للتذكية.

القول الثاني: إنه لا يجوز النحر في الغنم والطير، ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة.

وإليه ذهب المالكية. وهو محمول على التحريم، إذا كان في حال السعة، أما إذا كان مضطراً لذبحها، فإنه جائز.

(١) بدائع الصنائع ٥ / ٦٠.

واستدلوا: بأن نحر الإبل وذبح البقر والغنم هو السنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون اتباعه هو الأصل، وأما تعذر ذلك في حال الضرورة فيجوز العكس.

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم:

فأما العموم: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا".^(١)

فهو عام في بهيمة الأنعام كافة، فمن ذهب إلى جواز الذبح في البقر والغنم، والنحر في الإبل والعكس، استند إلى عموم الحديث السابق.

وأما الفعل: فإنه ثبت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر الإبل والبقر وذبح الغنم».

فمن تمسك بفعله صلى الله عليه وسلم لم يجز العكس وهو ذبح الإبل ونحر الغنم.^(٢)

والله أعلم.

الترجيح:

والذي يترجح في نظرنا . والله أعلم . ما ذهب إليه الجمهور، لأن كل ما أنهر الدم فهو حلال،

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، ١٤٢/٣، الحديث رقم: ٢٥٠٧

(٢) بداية المجتهد لابن رشد

كيفية ذكاة الأنعام

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الذبح المبيح للأكل شرعاً هو الذي يتم فيه قطع الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان في صفحتي العنق يجري فيهما الدم.

واختلفوا من ذلك في مسائل: ندرس كل واحدة منها في مطلب مستقل.

المطلب الأول:

هل الواجب قطع الحلقوم والمريء والأوداج أم يكفي قطع بعضها؟

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن الذبح يحصل بقطع ثلاثة غير معينة من الأربعة: إما الحلقوم والودجان، وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين، أو المريء والودجان.

وإليه ذهب أبو حنيفة. (١)

لأن الأكثر حكم الجميع فيما بني على التوسعة في أصول الشرع، والذكاة

(١) بدائع الصنائع ٥ / ٤٢.

بنيت على التوسعة حيث يكتفى فيها ببعض بلا خلاف بين الجمهور،
وإنما اختلفوا في الكيفية فيقام الأكثر فيها مقام الجميع

القول الثاني: إن الذبح يحصل الواجب بقطع المريء والحلقوم فقط.

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة. ^(١)

لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعها عادة وقد تبقى بعد
قطع الودجين إذ هما عرقان كسائر العروق، والحياة لا تبقى بعد قطع
عرقين من سائر العروق. ^(٢)

القول الثالث: إن الذبح يحصل بقطع كل الحلقوم مع الودجين.

وإليه ذهب المالكية. ^(٣)

وذلك لأن الحلقوم مجرى النفس والودجان مجرى الدم والمقصود إنهار
الدم.

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف بين الفقهاء: أنه لم يأت في ذلك شرط منقول، وإنما جاء
في ذلك أثران: أحدهما: يقتضي إنهار الدم فقط، والآخر يقتضي قطع
الأوداج مع إنهار الدم.

(١) نهاية المحتاج ٨ / ١٠٥، ١١٠، والمقنع ٣ / ٥٣٧، ٥٣٨.

(٢) المرجع والمكان السابقين.

(٣) الشرح الصغير مع بلغة السالك ٢ / ٣١٤.

ففي حديث رافع بن خديج أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل". وهو حديث متفق على صحته. (١)

وروي عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما فرى الأوداج فكلوا، ما لم يكن رض ناب أو نخر ظفر" (٢)

فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج، فقط، لأن إنهار الدم يكون بذلك، وفي الثاني قطع جميع الأوداج، فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين: إما أحدهما، أو البعض من كليهما، أو من واحد منهما، ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله - عليه الصلاة والسلام - : «ما فرى الأوداج» البعض لا الكل، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض.

وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين، ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه، لأن الزكاة لما كانت شرطاً في التحليل ؛ ولم يكن في ذلك نص فيما يجزي وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه، إلا أن يقوم الدليل على

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، ١٤٢/٢، الحديث: ٢٥٠٧.

(٢) أخرجه الطبراني في مسنده، ٢٥٠/٨ (٧٨٥١) مطولاً واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٦٠١)

جواز الاستثناء من ذلك، وهو ضعيف، لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطاً في الصحة.

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من حصول الزكاة بقطع الحلقوم والمريء، وذلك لأن الحياة لا تبقى بعد قطع عرقين من سائر العروق. والله أعلم.

المطلب الثاني

قطع أعضاء الزكاة من ناحية العنق

تحريم محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن زكاة الحيوان تحصل بقطع الحلقوم والمريء والودجين من ناحية العنق، واللَّبة " بفتح اللام هي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق " واللَّحيان " مثني اللحي بفتح اللام وهما العظامان اللذان يلتقيان في الذقن، وتثبت عليهما الأسنان السفلى. ^(١)

واختلف الفقهاء في حصول التذكية من ناحية القفا أي من خلف رقبة الحيوان على قولين:

(١) بداية المجتهد، ٢/٢٠٣.

القول الأول: إن التذكية الشرعية لا تحصل للحيوان من جهة القفا، وأن الحيوان إذا تم ذبحه بهذه الكيفية فإن التذكية لا تحصل. ولا يجوز أكله. وإليه ذهب المالكية، وهو مذهب سعيد بن المسيب، وابن شهاب وغيرهم. (١)

واستدلوا: بأن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو مقتل من المقاتل، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله. (٢)

القول الثاني: إن التذكية تحصل للحيوان من جهة القفا، وهو حلال يجوز أكله.

وإليه ذهب الحنفية والشافعية، وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين. (٣)

واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ، وَالظُّفْرَ". (٤)

(١) بدائع الصنائع ٥ / ٦٠. بداية المجتهد، ١٠/٢، شرح منهج الطلاب بحاشية البجيرمي ٤ / ٢٨٥. المقنع ١ / ٢١.

(٢) بداية المجتهد، ١٠٣/٢.

(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٦٠، شرح منهج الطلاب بحاشية البجيرمي ٤ / ٢٨٥. بداية المجتهد، ٢٠٣/٢.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، ١٤٢/٢، الحديث: ٢٥٠٧.

ووجه الاستدلال: أن كل حيوان تمت تذكيته بإنهار الدم ، فهو حلال، سواء أكان من جهة العنق أم القفا. إذ لم يفصل الحديث الشريف في ذلك، ولو كان واجباً لبينه لنا الشارع الحكيم.

سبب الخلاف:

وسبب اختلافهم هو: هل تعمل الذكاة في المنفوعة المقاتل أم لا تعمل؟، وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع، وهو مقتل من المقاتل، فتزد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله. (١)

فمن ذهب إلى القول بعدم جواز التذكية من القفا ابتنى رأيه على القول بعدم حل منفوعة المقاتل، لأنها ميتة.

ومن ذهب إلى القول بجواز التذكية من جهة القفا، ابتنى رأيه على أن الذكاة تؤثر في منفوعة المقاتل، ولا تكون ميتة.

الترجيح: الراجح . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز التذكية من جهة القفا، لحصول المأمور به شرعاً ولما رجحه الجمهور من تأثير الذكاة في المنفوعة المقاتل. (٢)

(١) بداية المجتهد، ١٠٣/٢.

(٢) نهاية المحتاج ٨ / ١١١، البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٤٩، والمقنع ٣ / ٥٤٠.

المطلب الثالث

حكم الذبيحة المَغْلَصَمَةُ:

المَغْلَصَمَةُ: اسم مفعول من قولهم: غَلَصَمَهُ إذا قطع غُلْصُمته. والغلصمة هي جوزة العنق وهي رأس الحلقوم، وهي صفيحة غضروفية، عند أصل اللسان، سرجية الشكل، مغطاة بغشاء مخاطي، وتتحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع^(١)

والمراد بالمَغْلَصَمَةُ: عند الفقهاء الذبيحة التي انحازت الجوزة فيها لجهة البدن، بأن يُميل الذابح يده إلى جهة الذقن فلا يقطع الجوزة بل يجعلها كلها منحازة لجهة البدن مفصولة عن الرأس^(٢)

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على حِلِّ الذبيحة التي يقطع الذابح فيها منتصف الجوزة فيكون نصفها إلى ناحية العنق، ونصفها على ناحية البدن. واختلفوا فيما لو قطع الذابح الغلصمة " الجوزة " إلى ناحية البدن، فهل تصح ذكاته بذلك أم لا على قولين:

القول الأول: تصح التذكية، وَيَحِلُّ أكلُ الذَّبِيحَةِ المَغْلَصَمَةِ.

(١) الصحاح للجوهري، ١٩٩٧/٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤/٣

(٢) الشرح الصغير ١ / ٣١٣.

وإليه ذهبُ الحَنَفِيَّةِ، والْحَنَابِلَةِ، وبعضِ المَالِكِيَّةِ، واختاره ابنُ حَزْمٍ، وابنُ تيمِيَّةَ، والشُّوكَانِيُّ. (١)

واستدلوا بما يلي:

أ. عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَنَهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ" (٢)

وجهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ قَوْلَهُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا أَنَهَرَ الدَّمَ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّذْكِةَ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ إِنْهَارُ الدَّمِ، حَلَالٌ. (٣)

(١) تبين الحقائق للزيلعي (٢٩٠/٥)، البحر الرائق لابن نجيم ١٩٣/٨. شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٤١٩/٣ كشف القناع للبهوتي ٢٠٦/٦، مطالب أولي النهى للرحيبي ٣٣١/٦. شرح الزرقاني على مختصر خليل ٤/٣، ويُنظر: المقدمات الممهدة لابن رشد الجد ٤٣٠/١. قال ابن حزم: (وسواءُ ذُبِحَ من الحَلَقِ في أعلاه أو أسفله، رُمِيَتِ العُقْدَةُ إلى فوق أو إلى أسفل، أو قُطِعَ كُلُّ ذَلِكَ مِنَ القَفَا، أُبِينِ الرَّأْسُ أو لم يُبَيَّنْ - كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ أَكَلُهُ). المحلى ١٢٢/٦. قال الشوكاني: والحاصلُ أَنَّهُ قد دَلَّ الحديثُ الصَّحِيحُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إِنْهَارُ الدَّمِ؛ فإذا طَعَنَ في الحَلَقِ واللَّبَّةِ حَتَّى أَنَهَرَ الدَّمَ ولم يَفِرِ الأوداجَ كُلَّهَا؛ كان الذَّبْحُ صَاحِبًا وَالدَّبِيحَةُ حَلَالًا. السيل الجرار ٧١٢/١.

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).

(٣) السيل الجرار للشوكاني ، ٧١٢/١.

ب . عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: "الذَّكَاءُ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَّةِ"^(١)

وجهُ الدَّلالةِ:

قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الذَّكَاءُ فِي الْحَلْقِ وَاللِّبَّةِ" أَي: بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللِّبَّةِ، وَكَلِمَةُ "فِي" بِمَعْنَى: "بَيْنَ" كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي)^(٢) أَي: بَيْنَ عِبَادِي.

ج . وَلَأنَّهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى الْعُقْدَةِ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ الذَّكَاءُ بَيْنَ اللَّبَةِ وَاللِّحْيَيْنِ، وَقَدْ حَصَلَتْ، وَالْمَشْهُورُ فِي صِحَّةِ التَّنْكِيَةِ مِنَ الْاِكْتِفَاءِ بِقَطْعِ ثَلَاثٍ مِنَ الْأَرْبَعِ أَيَا كَانَتْ، وَهِيَ الْمَرْئِيُّ وَالْوُدْجَيْنِ وَالْحَلْقُومَ ، وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحَلْقُومِ أَصْلًا، فَبِالْأَوَّلَى إِذَا قُطِعَ مِنْ أَعْلَاهُ وَبَقِيَتِ الْعُقْدَةُ أَسْفَلَهُ^(٣)

القول الثاني: لا تحل زكاة المغلصمة، ويحرم أكلها.

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨٦١٥)، وابن أبي شيبة (١٩٨٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى للبخاري مُعَلَّقًا ٩٣/٧، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي ٥٥٧/٩. وَاللِّبَّةُ: مَوْضِعُ النَّخْرِ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَهِيَ الثُّغْرَةُ الَّتِي فِي أَسْفَلِ الْعُنُقِ. يُنْظَرُ: تَهْذِيبُ اللُّغَةِ لِلْأَزْهَرِيِّ ٢٤٣/١٥، الصَّاحِحُ تَاجُ اللُّغَةِ لِلْجَوْهَرِيِّ ٢١٧/١ المَجْمُوعُ لِلنَّوَوِيِّ ٨٥/٩.

(٢) الفجر: ٢٩

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٧.

وإليه ذهب الشافعية وهو المشهور من قول المالكية. (١)

واستدلوا:

أ. بأن القطع حينئذ صار فوق الحلقوم، فإن الذبح لم يكن في الحلقوم وإنما كان في الرأس (٢)

ب. بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل؛ لأن المذبح هو الحلقوم (٣)

ونؤقش هذا: بأن المطلوب لصحة التذكية هو قطع ثلاثة أشياء من الأربعة التي هي الحلقوم والمريء والودجين، فلا بأس بترك الحلقوم بما فيه من الجوزة.

وأيضاً فإن المقصود من التذكية هو إنهار الدم، وقد حصل، فتكون التذكية صحيحة. (٤)

(١) الشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٣١٣، والخرشي مع العدوي ٢ / ١٠١، وحاشية الرهوني على الزرقاني ٣ / ٢، ٣، وحاشية كنون بهامش حاشية الرهوني ٣ / ٢، ٣، والشرواني على التحفة ٩ / ٣٢٢.

(٢) الشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٣١٣، والخرشي مع العدوي ٢ / ١٠١، وحاشية الرهوني على الزرقاني ٣ / ٢، ٣، وحاشية كنون بهامش حاشية الرهوني ٣ / ٢، ٣، والشرواني على التحفة ٩ / ٣٢٢. حاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٧.

(٣) المراجع السابقة، نفس المواضع .

(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٧.

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال: لا بد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليماً، ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن قطع فوق الجوزة جاز. (١)

الترجيح:

والراجح من وجهة نظرنا . والله أعلم . هو ما ذهب غليه الجمهور من جواز التذكية في المغلصمة، لعموم حديث الصحيحين : "ما أنهرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ" (٢) ولأن المقصود في التذكية قطع ثلاثة أشياء من أربعة، فتصح ولو ترك الحلقوم كاملاً والجوزة جزء منه، فيكون الحيوان المذكى حلالاً والله أعلم.

الفصل الثالث

آلة التذكية وشروطها

المقصود بآلة التذكية: المحدد الذي يستخدمه المذكي لطعن ذبيحته في المحل المحدد شرعاً.

(١) بداية المجتهد، ٢/٢٠٨.

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨).

والأصل أن الذي يستخدم في الذبح هو السكين أو المديّة، أو ما يُتخذ عادة من الحديد أو الزجاج أو الحجر أو الخشب، ونحو هذا.

ونتيجة للتطور الهائل في استخدام الصناعات الحديثة، فقد ابتكرت المذابح وسائل مستحدثة للذبح، مثلك الصعق الكهربائي، والضرب على رأس الحيوان، أو إصابته بحقنة مخدرة، يتم إلقاء الحيوان بعدها في حوض كبير للتقطيع الحيوان أو فرمه، وهناك القطع الآلي عن طريق الماكينات، بحيث يعلق الحيوان، ويتم إمرار آلة القطع على رقبتة، وهناك ابتكارات أخرى للوسيلة التي يتم بها الذبح، وندرس في هذا الفصل آلة التذكية، لنستوضح الحلال منها والحرام، ليكون المسلم على بصيرة من دينه، فيعلم ما يحل له أكله وما لا يحل له.

وقبل أن نخوض في الحديث عن ذلك ينبغي أن نبين ما اتفق الفقهاء على جواز استعماله من آلات الذبح، وما اختلفوا فيه، وذلك كما يلي:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة.

واختلفوا في السن والظفر هل تجوز بهما الذكاة أو لا تجوز.

وعلى هذا يشترط في الذبح شرطان: شرط متفق عليه بين الفقهاء، وهو أن تكون آلة الذبح قاطعة، وشرط مختلف فيه، وهو ألا تكون آلة الذبح ظفرا أو سنّاً.

الشرط الأول: أن تكون آلة الذبح قاطعة. سواء أكانت حديدا أم لا، كالمروة والليطة^(١) وشقة العصا. والزجاج والصدف القاطع، وسواء أكانت حادة أم كليلية ما دامت قاطعة.

والأصل في جواز التذكية بغير الحديد ما ورد عن رافع بن خديج قال: قلت: "يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مِدَى"^(٢). قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.^(٣)

(١) المروة واحدة المرو وهو حجر أبيض والمقصود به هنا ما كان رقيقا يحصل به الذبح، والليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة، والجمع ليط، كريحشة وريش، والشقة - بكسر الشين - الشظية أو القطعة المشقوقة من لوح أو خشب أو غيره (ر: لسان العرب) .

(٢) المِدَى: جمع مدية وهي السكين والشفرة الكبيرة، وسميت مدية؛ لأنها تقطع حياة الحيوان أي عمره. لسان العرب ١٥ / ٢٧٣، المعجم الوجيز ص ٥٧٦، نيل الأوطار ١٦١ / ٨

(٣) أخرجه البخاري ، الفتح ٩ / ٦٣٨ ، ومسلم ، ٣ / ١٥٥٨ ، واللفظ لمسلم.

وأما جواز التذكية بالمدى الكليّة ونحوها إن كانت تقطع فلحصول معنى الذبح والنحر. (١)

وصرح بعض الفقهاء بأن المدى الكليّة يشترط فيها ألا يحتاج القطع بها إلى قوة الذابح، وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهاء الحيوان إلى حركة مذبوح. (٢)

الشرط الثاني: ألا تكون الآلة سنا أو ظفرا قائمين.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: ألا تكون الآلة سنا أو ظفرا قائمين. فإن كانت كذلك لم تحل الذبيحة؛ لأن الذابح يعتمد عليها فتخفق وتنفسخ فلا يحل أكلها.

والى هذا القول ذهب الحنفية والمالكية في قول رواه ابن حبيب عن مالك. (٣)

وقد أوضح الحنفية هذا الشرط فقالوا: لا تجوز التذكية بظفر المذكي الذي هو متصل بيده، وهو معنى قولهم سنا أو ظفرا قائمين، فلو كان الظفر القائم ظفر غيره جاز، وذلك بأن يأخذ الذابح يد غيره فيمر ظفرها كما

(١) البدائع ٥ / ٤٢، ٦٠، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٧، والخرشي علي العدوي ٢ / ٣١٤، والبجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥٠، والمقنع ٣ / ٥٣٧.

(٢) البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥٠

(٣) تبيين الحقائق ٥ / ٢٩١، المبسوط ١٢ / ٢، العناية شرح الهداية ٩ / ٤٩٦، التاج والإكليل ٤ / ٣٣٢، المنتقى شرح الموطأ.

يمر السكين فإن الذبيحة تحل؛ لأنها قطعت ولم تفسخ، وخرج بقيد " قائمين " السن والظفر المنزوعان إذا كانا قاطعين فتجوز التذكية بهما. (١)

وقد استدلوا بما ورد من رواية أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أفرى. الأوداج ما لم يكن قرص سن أو حز ظفر" (٢)

ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر، حيث أباح النبي صلى الله عليه وسلم التذكية بكل ما قطع الأوداج.

ونؤقش هذا بأن هذا الحديث ضعيف وهو معارض بما ورد في حديث رافع بن خديج وهو في الصحيحين.

وقد أجابوا عن هذا: بأنه لا يعارض الحديث السابق الذي جاء فيه " ليس السن والظفر " فإن المراد فيه بالسن والظفر القائمان لا المنزوعان، ويؤيده حديث الطبراني السابق. (٣)

وأجيب عن هذا: بأن حديث رافع في الصحيحين، وهو لم يفرق بين ما إذا كان السن والظفر منزوعين ام لا، فلامعنى لهذا.

(١) تبیین الحقائق ٥/ ٢٩١، المبسوط ٢/ ١٢، العناية شرح الهداية ٩/ ٤٩٦، التاج والإكليل ٤/ ٣٣٢، المنتقى شرح الموطأ.

(٢) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٨ / ٢٥٠ - وزارة الأوقاف العراقية)، وأورده الهيئتي في مجمع الزوائد (٤ / ٣٤ - ط القدسي)، وقال: فيه علي بن يزيد، وهو ضعيف.

(٣) البدائع ٥ / ٤٢.

القول الثاني: لا تجوز الذكاة بالسن والظفر وبقيّة العظام مطلقاً متصلين كانا أو منفصلين.

وإليه ذهب الجمهور: الشافعية والحنابلة وهو الصحيح عند المالكية، وهو مذهب الظاهرية..^(١)

واستدلوا بما ورد عن رافع بن خديج قال: قلت: "يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غداً، وليست معنا مدى. قال صلى الله عليه وسلم: أعجل أو أرني ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة." ^(٢)

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الذكاة بالسن والظفر كما هو ظاهر الحديث، فلا تحل الذبيحة على هذا النحو من التذكية.

(١) المنقّى ٣/ ١٠٦، الكافي ص ١٨٠، بداية المجتهد ١/ ٣٢٧، المجموع ٩/ ٩٤، كشف القناع ٦/ ٢٠٥، الإنصاف ١٠/ ٣٩٠، المغني ٩/ ٣١٦، المحلى بالآثار ٦/ ١٠.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، برقم ٥١٧٩ ص ٥/ ٢٠٩٥، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام برقم ١٩٦٨ ص ٣/ ١٥٥٨

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء هو اختلافهم في مفهوم النهي الوارد في قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث «رافع بن خديج، وفيه: قال: " يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر^(١)، وأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة». (٢)

فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل يدل على فساد المنهي عنه.

فمن فهم أن المعنى في ذلك أن السن والظفر لا ينهر الدم غالبا قال: إذا وجد منهما ما ينهر الدم جاز، ولذلك رأى الحنفية ومن وافقهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن.

(١) السن: قطعة من العظم تثبت في الفك، الظفر: مادة قرنية في أطراف الأصابع، المعجم الوسيط ١/ ٤٧٣، ٢/ ٥٩٦

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، برقم، ٥١٧٩ ص ٥/ ٢٠٩٥، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام برقم، ١٩٦٨ ص ٣/ ١٥٥٨

ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير مغلل وأنه يدل على فساد المنهي عنه قال: إن ذبح بهما لم تقع التذكية، وإن أنهر الدم. وهو مذهب الشافعية ومن وافقهم. (١)

وقد قرر الفقهاء أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله - عليه الصلاة والسلام - : « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، لِيُحَدِّدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ » (٢)

الترجيح:

والذي يترجح في النظر . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من عدم جواز التذكية بالسن والظفر متصلين كانا أو منفصلين، لعموم الحديث الشريف الذي في الصحيحين، فإن النهي فيه يقتضي فساد المنهي عنه، فلا تجوز الذكاة به ،وأيضاً فإن حديث أبي أمامة ضعيف لا تقوم به حجة لضعف سنده عند أهل الحديث، كما أن الذبح بالسن والظفر فيهما تعذيب للحيوان ، وهو منهي عنه لحديث الصحيحين السابق " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، لِيُحَدِّدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ " عن الله كتب وأيضاً : فإن حديث وهو المشهور عند أهل العلم.

(١) بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٢١٠.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، ٢/٢٣٨، الحديث: ١٢٤٨ ١٢٤٨

تطبيقات على الصور الحديثة في الذبح:

وبناء على ما سبق: مما اشترطه الفقهاء في آلة الذبح، نتطرق إلى بعض صور الوسائل الحديثة في الذبح، ومنها:

الطريقة الأولى: الذبح بالصعق الكهربائي:

يتم الذبح بطريقة الصعق الكهربائي، عن طريق إمرار تيار كهربائي ذي شدة معينة ولمدة ثابتة إلى صدغي الحيوان، يحدث فقدان الوعي مباشرة، ثم يحدث طور من التقلص العضلي المزمّن قبل الارتخاء التام، وعدم الدقة التامة في استخدامها يؤدي إلى نتيجة سلبية، فعندما ينخفض التيار الكهربائي يشل الحيوان شللاً تاماً مع بقاء وعيه، وتسمى هذه بالصدمة الضائقة، وعندما يزداد التيار يصاب الحيوان بالسكتة القلبية الفاتلة.^(١)

وظاهر من هذا: أنه لا يمكن من خلالها إنهاء الدم في الحيوان بكثرة، وهو السبب الذي من أجله شرع الشارع الحكيم الذكاة، كما أن الحيوان المصعوق، يكون بين حالين، إما أن توقف الصعقة قلبه، إذا كانت قوية، وإما أن تصيبه الصعقة بالشلل متى كانت ضعيفة.

(١) كتاب أحكام الذبح والذبائح، إعداد منظمة الصحة العالمية، إقليم شرق البحر

المتوسط . ١٩٩٥م الطبعة الثانية (المرفق الثاني والثالث)

ففي الحال الأولى إذا نتج عن صعق الحيوان بالكهرباء توقف قلب الحيوان، فإنه يصير ميتاً، وهو من قبيل الموقوذة^(١) التي يحرم أكلها إجماعاً بنص الآية الكريمة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ).^(٢)

وفي الحال الثانية: إذا نتج عن الصعق حالة شلل الحيوان التي تفقده وعيه دون أن تقتله، وهنا نقول إن بقيت في الحيوان حياة مستقرة، وأدرك بالتذكية الشرعية، كان حلالاً، وإن لم يبق في الحيوان بعد الصعق نوع حياة، فمات، فإنه يحرم أكله، ولا يحل، سواء تمت تذكيته أم لا، لأنه مات، والتذكية في الحيوان الميت لا تأثير لها. كما أنه يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقاً، وفي الذبح خاصة، فقد روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً»^(٣)

(١) الموقوذة: هو الحيوان الذي يضرب حتى يشرف على الموت، سواء كان الضرب بعصا أو بحجر أو بأي مثقل يؤدي الضرب به إلى هلاك الحيوان. (أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٣٠، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٢٠، الفواكه الدواني / ٢٨٥، كشف القناع ٦/ ٢٠٨، المحلى بالآثار ٦/ ١٤٩

(٢) المائدة/٣

(٣) رواه مسلم (١٩٥٧) ..

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبراً»^(١)

ولذا يمكننا القول بجواز التذكية عن طريق الصعق الكهربائي، متى توافرت الضوابط الآتية:

١. التحقق من أنها لا تصحبها آلام للحيوان.
 ٢. التحقق من أن الصعق لا يحول دون تدفق الدم عند إجراء الذبح بعدها.
 ٣. التحقق من أن الذبح يحصل فوراً بعد الصعق وبالحيوان حياة مستقرة.
 ٤. التحقق من عدم فساد اللحم أو نقصان لطيبه.
- فإذا تحققت هذه الضوابط، جاز استخدام هذه الطريقة وإلا فلا تجوز التذكية بها.
- واستخدام الصعق الكهربائي له طريقة محددة وتيار كهربائي محدد، ومدة زمنية محددة لكل نوع من الحيوانات، يحددها المختصون، ويجب أن يلتزم بذلك؛ لأنه إذا كانت الصدمة - مثلاً - خفيفة بالنسبة لضخامة الحيوان بقي مفلوجاً بدون أن يفقد الحواس ويشعر بالألم مرتين: الأولى: بالصدمة الكهربائية، والثانية: عند الذبح.

(١) رواه مسلم (١٩٥٩)

أما إذا كانت الصدمة الكهربائية شديدة لا يتحملها الحيوان أدت إلى موته بتوقف القلب، فيصير ميتة لا يجوز أكله بحال من الأحوال

ومن الجدير بالذكر: أن طرق الصعق هذه تستخدم لإراحة الحيوانات قبل ذبحها على الطريقة الإسلامية، وليست بديلة للطريقة الإسلامية.

فالأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل؛ رحمة بالحيوان وإحساناً لذبحته وتقليلاً من معاناته.

ولذلك نحن نطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم؛ بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل، مع مراعاة الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيته^(١)؛ فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت هذه الشروط.

(١) وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي :

١- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي - القذالي (القفوي) .

٢- أن يتراوح الفولت ما بين (١٠٠ - ٤٠٠ فولت) .

٣- أن تتراوح شدة التيار ما بين (٧٥ . إلى ١ أمبير) بالنسبة للغنم ، وما بين (٢ إلى ٢.٥ أمبير) بالنسبة للبقر .

٤- أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (٣ إلى ٦ ثوان)

علامات تأكيد تذكية الحيوان دون موته بالصعق:

إذا كانت طريقة الصعق الكهربائي كما رأينا على النحو السابق، يمكن أن يموت الحيوان خلال صعقه إذا كان التيار الكهربائي زائداً، فكيف يمكننا التأكد من أن موت الحيوان كان بالذبح بعد التدويخ بالصعق الكهربائي وليس بالصعق نفسه؟

هناك علامات عن طريقها يعرف حياة الحيوان بعد الصعق بالكهرباء والذبح، وذلك بعد التأكد من تطبيق الشروط الفنية التي حددها المختصون عند إجراء عملية التدويخ بالصعقة الكهربائية، ومن هذه العلامات:

أولاً: خروج الدم بعد الذبح.

فإن خرج الدم بقوة من الذبيحة بعد الصعق والذبح، فإنه يدل على أن الذبيحة لم تمت بالصعق، بل بالذبح،^(١)

ج- لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيتة باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية.

د- لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفشاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية.

هـ- لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيتة " انتهى.

(١) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل ، ٥ / ٢

فإذا كان ينزل الدم بعد قطعه، فمعنى ذلك أن الذبيحة لم تمت بالصعق، وإنما خُدرت ثم ذبحت، وعلى هذا تكون حلالاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" ^(١)، ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية، أما إذا ماتت؛ فإن الدم يتغير ويتخثر، ولا يمكن أن يخرج، اللهم إلا شيئاً يسيراً. ^(٢)

ثانياً: حركة الحيوان:

والمراد بالحركة: الحركة التي تدل على الحياة بعد الصعق وقبل الذبح، كضم الفم وضم العين وقبض الرجل أو تحريك الذنب أو أي عضو منه ^(٣)

أو الحركة بعد الذبح؛ فإن تحرك الحيوان وانتفض بعد ذبحه، فإن هذا دليل على أنه لم يمت من الصعقة الكهربائية، بل الموت كان بسبب الذبح ^(١)

-
- (١) أخرجه البخاري ، الفتح ٩ / ٦٣٨ ، ومسلم ، ٣ / ١٥٥٨ ، واللفظ لمسلم.
- (٢) بلغة السالك ٢ / ١٧٤ ، ١٧٥ حاشية الدسوقي ٢ / ١١٢ ، ١١٣ الموع ٩ / ١٠١ ، ١٠٢ ، الإنصاف ١٠ / ٣٩٦ ، ٣٩٧ شرح منتهى الإيرادات ٣ / ٤٢٠ ، كشاف القناع ٦ / ٢٠٨ مطالب أولي النهى ٦ / ٣٣٢ ، شرح النيل ٤ / ٤٤٦
- (٣) بدائع الصنائع ٥ / ٥٠ ، ٥١ ، الإنصاف ١٠ / ٣٩٦ ، ٣٩٧ البحر الزخار ٥ / ٣٠

الطريقة الثانية: الذبح بالشاكوش والبلطة والمطرقة والمسدس:

تتلخص هذه الطريقة في أن يهوي الذابح بشاكوش أو بلطة أو مطرقة ضخمة على رأس الحيوان، مما يجعله يفقد الوعي وينهار، وقد يستخدم المسدس^(٢) في تدويخ الحيوان حيث يحدث ثقباً في دماغ الحيوان يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل فوري.

(١) بلغة السالك ٢/ ١٧٤ ، ١٧٥ حاشية الدسوقي ٢/ ١١٢ ، ١١٣ الموع ٩/

١٠١ ، ١٠٢ الإنصاف ، ١٠/ ٣٩٦ ، ٣٩٧ شرح منتهى الإيرادات ٣/ ٤٢٠ ،

كشاف القناع ٦/ ٢٠٨ مطالب أولي النهى ٦/ ٣٣٢ ، شرح النيل ٤/ ٤١٠

(٢) هناك نوعان من المسدس الذي يستخدم في عملية التدويخ:

الأول: المسدس الواقذ ذو الطلقة المسترجعة: حيث توجه هذه الآلة إلى جبهة الحيوان في موضع محدد يختلف تبعاً لنوع الحيوان، وعند الضغط على الزناد تنطلق خرطوشة فارغة من المسدس لتوجه مسماراً غليظاً إلى داخل الجمجمة ونسيج المخ، وبهذا يدوخ الحيوان، ويفقد الوعي ويظل المسمار الغليظ المدبب من الأمام متصلاً بالمسدس، يعود إليه آلياً بواسطة نابض مرتبطب طرفه الأول بالمسدس، والثاني بالمسمار، بحيث يسمح هذا الوضع باستعماله دائماً.

الثاني: المسدس الصادم: ويستخدم أيضاً في صق العجول والأبقار؛ حيث يوجه إلى موضع محدد من جبهة الحيوان، وعند الضغط على الزناد تصدم قطعة حديدية مستديرة في مقدمة المسدس الجبهة، فتحدث بالحيوان ارتجاجاً شديداً في مخه، وأحياناً يتهشم مكان الإصابة من جبهته ثم يخر صريعاً على الأرض، وهذه الطريقة المؤلمة أقل تأثيراً على الحيوان من المسدس الواقذ ، والحيوان المصعوق بهذه الطريقة يبدأ بتحريك يديه ورجليه بعد حوالي ٦ - ٥ دقائق.

وهذه الطريقة ينتج عنها حالة باللحم تسمى بالتبقع الدموي، وهي نقطة نزيفية أو بقع أو خطوط في أجزاء مختلفة من أعضاء الذبيحة^(١)

الرأي الفقهي في هذه الطريقة:

إن الناظر في أصول الشريعة وقواعدها، يلحظ بجلاء عدم جواز استخدام هذه الطريقة شرعاً، لما يلي:

أولاً: لما فيها من إضرار وإيلام للحيوان، ولما تشتمل عليه من وحشية لا تقبل من مسلم يدين بشرع الإسلام.

ثانياً: إن الشارع الحكيم قد أمرنا بإحسان ذبح الحيوان والرفق به؛ لقول الرسول: صلى الله عليه وسلم "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته"^(٢)

ثالثاً: إن هذه الطريقة تشتمل على استخدام وسائل في الذبح نهى الشارع الحكيم عنها، والمتأمل في النصوص الشرعية، يجد أن الشارع الحكيم نهى عن الذبح بالأسنان والأظفار؛ لئلا يشبه عمل الأمم المتوحشة، وهذا مثله، وفي معناه، بل أولى؛ ولذا، يجب الامتناع عن استعمال

(١) بحوث مقارنة د، فتحي الدريني ٢ / ٣٥٢، الذبائح في الشريعة الإسلامية د. أبو فارس ص، ٦٤: ٦٦ الطرق الشرعية لإنجاز الذكاة د. سليمان الأشقر ص: ٤٣.

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيد، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، رقم: ١٩٥٥ ، ص ٣ / ١٥٤٨

هذه الطريقة بالكلية في المسالخ ؛ لأنها لا تراعي المناهج المقبولة شرعا في الذبح من عامة المسلمين.

رابعاً: إن الفورية في الذبح بعد الطلقة أو ضرب البلطة، قد تتساهل المسالخ في تطبيقها في بعض الحالات، فيتطور الأمر إلى ذبح الموقوذات وإطعامها للمسلمين، ولذا يجب منعها من باب سد ذرائع الفساد (١)

حكم الحيوان المذبوح بهذه الطريقة:

الحيوان المذبوح بتلك الطريقة لا يخلو أمره من حالين:

الحال الأولي: أن تتسبب هذه الطريقة في إفقاد الحيوان وعيه، وانتهياره فقط دون موته، ويظل على قيد الحياة، ثم تتم تذكيته بعد هذا التدويخ بالطريقة الشرعية في المحل المتفق عليه، فيكون حكمه حينئذ الحل، لأن هذا من باب أعمال الزكاة في الحيوان الذي تمت تذكيته وفيه حياة مستقرة .

الحالة الثانية: أن تتسبب هذه الطريقة في موت الحيوان قبل أن يُذكي الزكاة الشرعية، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الحيوان من قبيل الميتة الموقوذة؛ لأن زهوق روح الحيوان كان بسبب الضرب والوقذ المحرم لا

(١) الموسوعة الشاملة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، بحث الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الزكاة للدكتور محمد سليمان الأشقر، ٣٠٦ / ١٠، وأيضا بحث الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الزكاة، للدكتور محمد الهواري ، ٥٠٧ / ١٠

بسبب الذبح، والضرب متحقق هنا، وهو الذي أدى إلى هلاك الحيوان فيحرم لأنه من المعلوم فقهاً إنه إذا اجتمع حلال وحرام فغلب الحرام، فإنه يحرم تناول ما غلب في الحرام احتياطاً^(١)؛ استناداً للقاعدة الفقهية: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام احتياطاً^(٢)

الطريقة الثالثة: الذبح بالتخدير باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون:

تتلخص كيفية الذبح في هذه الطريقة بأن يحبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي على (٧٠ %) من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبقى الحيوان محتفظاً بوعيه خلال (٢٠) ثانية، ثم يحدث فقدان الوعي مباشرة، ويتبعه منعكسات حركية تستمر لمدة (١٠) ثوان ، ولا يعتبر الخبراء ذلك نتيجة لمحاولة الحيوان في الفرار؛ نظراً لأن هذه الظاهرة تشاهد في المخطط الكهربائي للدماغ للحيوان بعد تخدير عميق.

ثم تعقب المنعكسات الحركية حالة ارتخاء عضلي، حينما يصبح الحيوان في حالة تخدير عميق، تستمر عادة من (٢-٣) دقائق، ولا يؤدي هذا إلى توقف القلب إلا في حالات نادرة.

ويقول الخبراء في هذا العلم إن زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء تؤدي إلى تسريع عملية التدويخ، وهو ما يرغبه المهنيون.

(١) مجمع الأنهر ٢/ ٥٨٢، الفواكه الدواني ٢/ ٢٨٥، مغني المحتاج ٦/ ١٠٨،

دقائق أولي النهى ٣/ ٤٢٠، كشف القناع ٦/ ٢٠٨

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١

ويعتقد كثير من العلماء بأن الحيوان يتعرض لحالة ضيق تنفسي شديد أثناء التخدير، وقد تأيد ذلك من خلال تجارب أجريت على متطوعين من البشر؛ كانوا قد شعروا بالضيق التنفسي ، عندما تجاوزت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء (٤٠) %^(١)

الرأي الفقهي في هذه الطريقة:

هذه الطريقة لا يحل الذبح بها؛ لأنها تتنافى مع شرعنا الحنيف الذي أمر بالإحسان للحيوان عند ذبحه بإحداث الشفرة حتى لا يطول عليه الذبح، أو يعاني آلامه.

وأشهر عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي إلى سرعة فساد اللحم، كما تؤدي إلى اختناق الحيوان وموته لعدم التحكم في كمية الغاز^(٢)

وهي طريقة غير مشروعة لإزهاق روح الحيوان لما يلي:

١- أن استعماله يؤدي إلى اختناق الحيوان، والمنخنقة محرمة بنص القرآن الكريم لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر (٥٣٩-٥٣٨ .)

(٢) الذبائح في الشريعة الإسلامية، دكتور أبو فارس ص، ٦٤: ٧٠ الأطعمة المستوردة طبيعتها-حكمها -حل مشكلاتها د . محمد بن عبد الغفار الشريف ص ٦٤- ٧٦، دار الدعوة، الكويت طبعة ١٤٠٣هـ.

لَعَبْرَ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَّنِيكُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْقُتُمْ بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ (١)

٢. ما في الخنق من التعذيب للحيوان وإيلامه.

٣. - احتباس الدم وعدم خروجه، والدم حرام بالإجماع، إلى جانب فساد
اللحم وبننته لاشتماله على الدم المليء بالميكروبات الضارة. (٢)

حكم الحيوان المذبوح بهذه الطريقة:

الحيوان الذي تستخدم معه هذه الطريقة له حالان:

الحال الأولي: أن يموت الحيوان اختناقاً بهذا الغاز، قبل أن يذبح ويذكى
الزكاة الشرعية؛ وفي هذه الحالة يأخذ حكم الميتة، أو المنخقة.

الحالة الثانية: أن يؤدي هذا الغاز إلى تدويخ الحيوان دون موته، ثم
يذبح بالطريقة الشرعية أي أنه يُدرك، ويُذكى التذكية الشرعية، وفي هذه
الحالة يحل أكله.

(١) المائدة/٣

(٢) بحوث مقارنة د. الدريني ٢/ ٢٥٣ وما بعدها، الأطعمة المستوردة، د. محمد
الشريف ص، ٦٤ وما بعدها. لذباح والطرق الشرعية في إنجاز الزكاة، للدكتور محمد
الهوري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد العاشر، سنة ١٩٩٧ ص ٥

الطريقة الرابعة: الطريقة الإنجليزية:

وتتلخص هذه الطريقة في خرق جدار الصدر بآلة حادة بين الضلعين الرابع والخامس، ومن خلال هذا الخرق يتم نفخ الهواء إلى الرئتين، فيموت الحيوان نتيجة لضغط الهواء بمنفاخ في رئتيه، دون أن ينزف دمه.

الرأي الفقهي في هذه الطريقة:

لا يجوز استخدام هذه الطريقة في ذبح الحيوان لما يلي:

أولاً: لما فيها من إيلاء وتعذيب له، وقد أمرنا ديننا بالإحسان في كل شيء، ونص على إحسان الذبح؛ لما جاء في الحديث: " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ". (١)

ثانياً: ولما في هذه الطريقة من عدم إدماء الحيوان وإنهار الدم، والذي من أجله شرعت الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أنهرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكلُّ " (٢)

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح، ص ٣/ ٥٤٨، رقم ١٩٥٥ .

(٢) أخرجه الإمام البخاري، صحيح البخاري، ٧٥/٤/ الحديث رقم ٣٠٧٥:

حكم الحيوان المذبوح بهذه الطريقة:

ما ذبح بهذه الطريقة يأخذ حكم الميتة؛ لأن موت الحيوان مضاف إلى الاختناق لا إلى الذبح والتذكية أو انفصال الدم وإنهاره.

الطريقة الخامسة: طريقة المغطس المائي المكهرب:

كيفية هذه الطريقة:

وتستعمل هذه الطريقة غالباً عند ذبح الطيور والدواجن، إذ تُعلق من أرجلها بشريط آلي متحرك يجعل رؤوسها وأعناقها تمر بحوض مائي مكهرب، فتصعق، ثم يمر بها ذلك الشريط على سكين آلية تذبحها وهي على هذه الحالة، ويتم في بعض المذابح ذبحها يدوياً بعد الصعق المذكور، ثم يمر بها على حوض كبير مملوء بالماء المغلي لتسهيل نتف الريش، ثم تخرج منه لمتابعة المراحل الأخرى.

وتستعمل هذه الطريقة للتمكن من ذبح مجموعات كبيرة بأقل تكلفة، وقد جرى العمل بهذه الطريقة منذ عام ١٩٧٠م^(١)

الرأي الفقهي في هذه الطريقة:

هذه الطريقة تجمع بين فعليهما حرمة الإسلام الحنيف، وهما: الغرق والصعق، ويؤدي هذا الصعق الكهربائي -مهما كان خفيفاً- إلى موت كمية من الحيوانات قبل ذبحها، وتفاوت هذه الكمية بحسب قوة الصعق

(١) الذبح الإسلامي ومزاياه، والذبح الغربي وخفاياه، للدكتور محمد فؤاد البرازي. ص ٥

الكهربائي وضعفه من ناحية، أو بحسب ضعف الحيوان وقوته من ناحية أخرى، أو نتيجة وصوله إلى المجزرة مجهداً بعد رحلة طويلة؛ بحيث لا يحتمل أي صدمة من ناحية ثالثة، ويظهر هذا جلياً في الدواجن أكثر من غيرها.

ولذا فإننا نرى عدم جواز استخدام هذه الطريقة لما يلي:

١- أن الغالب في هذه الطريقة أن يجتمع معها الصعق بالكهرباء قبل وصول الحيوان إلى الآلة الذابحة بوقت قصير؛ لغرض أن يكون الحيوان مشلولاً ومنعدم الحركة، بالإضافة إلى أن بعض الحيوانات يموت بهذا الصعق - كما يقول المتخصصون - قبل إجراء التذكية لها. والأحكام الفقهية إنما تكون للكثير الغالب، وليس للقليل النادر، وما دام أن الأغلب هو أن الحيوان يُصعق قبل أن يصل إلى آلة الذبح ، وحتى إن وصل إليها فقد لا تُدركه آلة الذبح، فيكون من قبيل الميتة المنخقة أو الموقودة ، وهو محرم بالنص والإجماع.

٢- عدم تحقق الذبح في موضعه؛ لأن الدجاج يعلق في علاقات مثبتة في سيور محركة تمر بها على الذبيحة، والدواجن والطيور أجسامها متفاوتة غير متساوية، فربما تطول الشفرات موضع الذبح من الدجاجة، وربما لا تطوله لصغر حجم الدجاجة فتقطع الشفرة الرأس كلية أو عرف

الدجاجة مثلاً أو موضع غير موضع الذبح؛ فتكون الدجاجة في حكم الميتة المحرمة. (١)

وحينئذ لا تكون كل الحيوانات مذكاة لقتل بعضه بما ليس ذبحاً شرعياً وحينئذ لا يمكن الحكم بحل هذه الطريقة إلا إذا تأكدنا من أن الحيوان الذي صعق بالكهرباء لم يمت وقد ذبحته الآلة الحادة في موضع التذكية، وهو أمر متعسر، وقد لا يلتفت إليه من يقوم على أمر الذبح في المجازر الآلية، نظراً لكثرة الأعداد، وقلة التفقه الديني، بل ربما يكون المجزر مملوكاً لغير المسلمين، ممن لا يأبهون بمراعاة أحكام الذبح الشرعي. والله أعلم.

(١) بحوث مقارنة د. الدريني ٢ / ٣٥٢ وما بعدها، الطرق الشرعية لإنجاز الذكاة د. سليمان الأشقر ص ٤٧ .

الفصل الرابع

شروط التذكية

اشترط الفقهاء لحلّ أكل الحيوان المذبوح عند التذكية الشرعية من حيث الجملة: التسمية واستقبل القبلة والنية، وفيما يلي تفصيل أقول الفقهاء في ذلك:

الشرط الأول: التسمية:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على استحباب التسمية على الذبيحة، وأن فاعلها، يُؤجر عليها.

واختلفوا في فرضيتها على ثلاثة أقول:

القول الأول: إن التسمية على الذبيحة فرض على الإطلاق، فإن تركها المذكي بطلت التذكية، ولا يحل أكل الذبيحة.

وإليه ذهب: الظاهرية ونقله ابن حزم. وهي رواية عن مالك وأحمد، وقول جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول ابن عمر والشعبي، وابن سيرين. (١)

واستدلوا:

(١) المحلى بالآثار لابن حزم، ١٥٤/٦، بداية المجتهد، ٢/٢١١.

أ . بعموم قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ^(١)

ب . وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أنهر الدم وذُكر اسمُ الله عليه فكلُ " ^(٢)

ووجه الاستدلال من النصين السابقين: أن الشارع الحكيم قد شرط لحل الأكل التسمية، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل ، كسائر الشروط ^(٣)

ج . كما استدلوا من المعقول فقالوا: بأن المذكي إن أتى بالصفة التي أباح الله تعالى لنا بها أكل ما ذكاه ، وإذا لم يذكر الله تعالى، أو ذكر غير الله تعالى، فقد أتى بالصفة التي حرم الله تعالى علينا الأكل مع وجودها، لأنه أهل لغير الله به. ^(٤)

ونُقش ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من وجهين:

أولهما: إن المراد ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به) ^(٥) وسياق الآية دال عليه فإنه

(١) الأنعام/ ١٢١

(٢) أخرجه الإمام البخاري، صحيح البخاري، ٧٥/٤/ الحديث رقم ٣٠٧٥:

(٣) المحلى بالآثار لابن حزم، ١٥٤/٦، بداية المجتهد، ٢/٢١١.

(٤) المحلى بالآثار لابن حزم، ١٥٤/٦،

(٥) سورة النمل / ١١٥.

قال: (وإنه لفسق) والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله. قال تعالى: (أو فسقا أهل لغير الله به) ^(١)

ثانيهما: ما قاله أحمد أن المراد به الميتة بدليل قوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) ^(٢) وذلك لأنهم كانوا يقولون: أتأكلون ما قتلتم - أي ذكيتم - ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون الميتة. ^(٣)

القول الثاني: إن التسمية على الذبيحة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، فلو تركها المذكي متعمدا بطلت التذكية، ولا تحل الذبيحة، أما إن تركها المذكي ناسياً، فتصح التذكية ويحل أكل ذبيحته.

وإليه ذهب: الجمهور: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو قول الثوري. ^(٤)

واستدلوا بما يلي:

استدلوا على وجوب التسمية على من تذكرها:

أ. بقول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ^(٥)

(١) سورة الأنعام / ١٤٥

(٢) سورة الأنعام / ١٢١.

(٣) المقنع، ٥٤١/٣.

(٤) العناية للبابرتي، ٤٨٩/٩، البناية للعيني، ٥٣٥/١١، التاج والإكليل، للمواق

، ٢١٩/٣، مواهب الجليل للحطاب، ٣٢٨/٤. الإنصاف للمرداوي، ٣٠٠/١٠،

شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ٤٣٤/٣.

(٥) الأنعام: ١٢١

وجه الدلالة:

سَمَّى اللهُ تعالى ما لم يُذَكِّرِ اسمُ الله عليه فسقًا، كما في قوله تعالى: أَوْ
فَسِقًا أَهْلًا لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْفِسْقُ مُحَرَّمٌ، وما لم يُذَكِّرِ اسمُ الله عليه فهو ممًا
أَهْلًا لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ، فهو حَرَامٌ بِنَصِّ الْآيَةِ، وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا^(١)

ب . عن عَبَّائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعِظَمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ
فَمُدَى الْحَبْشَةِ"^(٢)

ج . عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " .. فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي؟ قَالَ:
إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ. قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ لَمْ
يُؤْمِسْكَ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا
آخَرَ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ"^(٣)

(١) إرشاد الساري للقسطلاني، ٢٧٣/٨

(٢) أخرجه البخاري (٥٤٩٨) واللفظ له، ومسلم (١٩٦٨).

(٣) أخرجه البخاري (٥٤٧٦) واللفظ له، ومسلم (١٩٢٩).

وجه الدلالة مما سبق: أَنَّ الشارع الحكيم قد أَوْقَفَ الإِذْنَ فِي الْأَكْلِ مِنَ الذَّبِيحَةِ عَلَى التَّسْمِيَةِ، وَالْمُعْلَقُ بِالْوَصْفِ يَنْتَقِي عِنْدَ انْتِفَائِهِ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ، وَالشَّرْطُ أَقْوَى مِنْ الْوَصْفِ^(١)

د. أَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ الْمَيْتَةِ، وَمَا أُذِنَ فِيهِ مِنْهَا تُرَاعَى صِفَتُهُ، فَالْمُسَمَّى عَلَيْهِ وَافَقَ الْوَصْفَ، وَغَيْرُ الْمُسَمَّى بَاقٍ عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ^(٢)

واستدلوا على سُقُوطِ التَّسْمِيَةِ سَهْوًا:

أ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ"^(٣)
وجه الدلالة:

أَنَّ الْحَدِيثَ نَصٌّ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَ النِّسْيَانِ^(٤)

(١) بدائع الصنائع للكاساني، ٤٦/٥، التنبيه على مشكلات الهداية، لابن أبي

العز الحنفي، ٧٢١/٥، نيل الأوطار، للشوكاني، ١٥٣/٨

(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ١٥٣/٨.

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) واللفظ له، والطبراني في المعجم الأوسط (٨٢٧٣). حسنه النووي في المجموع، ٥٢١/٦، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٦٨٥/٧، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر، ٥١٠/١، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه، ٩٠/١: رجاله على شرط الصحيحين، وله شاهد من القرآن، ومن طُرُقٍ أُخَرِ، وقال ابن الملقن في شرح البخاري، ٢٦٧/٢٥، ثابتٌ على شرط الشيخين.

(٤) سبل السلام للصنعاني، ٥١٨/٢

ب . لِكثَرَةِ وَقُوعِ الذَّبْحِ وَتَكَرُّرِهِ، فَيَكْثُرُ فِيهِ السَّهْوُ^(١)

وَنُوقِشَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا يَبْطُلُ التَّذْكِيَةُ وَلَا يَحِلُّ الذَّبِيحَةُ، بِأَنْ ذَبِيحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ تَحِلُّ رَغْمَ أَنْهُمْ لَا يَذْكُرُونَ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ مَعَ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامدًا أَوْ نَاسِيًا.

كما نُوقِشَ : بِأَنْ النِّسْيَانُ لَا يَسْقُطُ بَقَاءَ حَكْمِ التَّكْلِيفِ، كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً، لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا.

وَأُجِيبَ عَنْهُ : بِأَنْ هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَلْزِمُهُ فِي حَالِ الذِّكْرِ، إِنَّمَا هِيَ فَرَضٌ لَزِمَ فِي الْحَالِ، وَلَيْسَتْ هِيَ صَلَاةُ الْوَقْتِ الْمُنْسِيَةِ، وَهُوَ لَمْ يَكُنْ مَكْلَفًا لِلصَّلَاةِ فِي حَالِ النِّسْيَانِ، وَلَيْسَ بَعْدَ وَقُوعِ الذَّبْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَاحِ ذَبِيحَةُ أُخْرَى يَتَعَلَّقُ بِهَا حَكْمُ الْوُجُوبِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزِمَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الذِّكْرِ^(٢)

القول الثالث: إِنْ التَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَةِ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، فَلَوْ تَرَكَهَا الْمَذْكُورُ عَامدًا أَوْ نَاسِيًا صَحَّتِ التَّذْكِيَةُ، وَحُلَّتْ ذَبِيحَتُهُ.

وَالْإِلَهَ ذَهَبَ: الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ رَشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ^(٣)

(١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ٤٣٤/٣

(٢) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ٢٣٣/٧.

(٣) البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥١. بلغة السالك على الشرح الصغير ١ /

٣١٩. المقنع ٣ / ٥٤١.

واستدلوا بما يلي:

أ. بقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(١)

وجه الاستدلال: أن الله عز وجل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، رغم أنهم لا يذكرون التسمية عليها، فمن باب أولى تحل ذبيحة المسلم مع ترك التسمية عامداً أو ناسياً. ^(٢)

ب. بقوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ^(٣)

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن عدم الأكل محمول على ما ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) ^(٤)

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قَالَ : " يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحَ كَانَتْ تَذْبَحُهَا قُرَيْشٌ عَنِ الْأَوْثَانِ ، وَيَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ " ^(٥)

(١) سورة المائدة / ٥.

(٢) البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥١. تفسير ابن كثير " ٣ / ٣٢٥ ، تفسير القرطبي ، ٧ / ٧٥ .

(٣) سورة الأنعام / ١٢١.

(٤) الأنعام / ١٤٥ .

(٥) تفسير ابن كثير " ٣ / ٣٢٥ ، تفسير القرطبي ، ٧ / ٧٥ .

ج . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
وَلْيَأْكُلْهُ" (١)

د. ما أخرجه الدار قطني من حديث أبي هريرة قال: "سأل رجل النبي
صلى الله عليه وسلم الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله قال: اسم الله
على كل مسلم" (٢)

وجه الاستدلال من الحديثين الشريفين أن المسلم إذا نسي التسمية، فإنه
يكفيه أنه مسلم وتحل ذبيحته، وفي لفظ من ألفاظ الحديث "على فم كل
مسلم" وهذا عام في الناسي والمتعمد؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب. وإذا كان ذلك كذلك، فإن التسمية تكون سنة لا فرضاً
لأن شأن الفرض بطلان التذكية بتركه. (٣)

د. **واستدلوا بما رواه البخاري** " أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَزَعَى غَنَمًا لَهُ
بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ، وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا
بِهِ ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا " (٤)

(١) رواه البيهقي (١٨٨٩٠) ولكنه حديث ضعيف، والصواب وقفه على ابن
عباس، انظر: "التلخيص الحبير" ٤ / ٣٣٨.

(٢) أخرجه الدارقطني، ٤ / ٢٩٥ - ط دار المحاسن، وضعف أحد رواته.

(٣) البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥١، بلغة السالك على الشرح الصغير ١ /

٣١٩، والمقنع ٣ / ٥٤١. تفسير ابن كثير ٣ / ٣٢٥، تفسير القرطبي، ٧ / ٧٥.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، ٧ / ٩١، الحديث: ٥٥٠١

وجه الاستدلال من الحديث ظاهر، حيث أباح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكل ما ذبحته جارية كعب دون أن يسأل هل قامت الجارية بالتسمية عليها أم لا. وفي هذا دليل واضح على أن ترك التسمية لو كان واجباً لما أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بحلها، وأجاز لهم أكلها.

هـ . ما أخرجه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر" (١)

وجه الاستدلال من الحديث الشريف ظاهر، إذ لو كانت التسمية شريطة لحل الذبح لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها؛ لأن الشك في الشريطة شك فيما شرطت له. (٢)

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، هو معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر. (٣)

(١) أخرجه البخاري ، الفتح ٩ / ٦٣٤ .

(٢) البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥١ ، بلغة السالك على الشرح الصغير ١ /

٣١٩ ، والمقنع ٣ / ٥٤١ . تفسير ابن كثير " ٣ / ٣٢٥ ، تفسير القرطبي ، ٧ / ٧٥ .

(٣) الأنعام: ١٢١

فأما الكتاب: فقوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (١)

وأما السنة المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سمو الله عليها ثم كلوها». (٢)

فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، ولم ير ذلك الشافعي، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة، وآية التسمية مكية، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على النذب.

وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيروا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». (٣)

(١) بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٢١١.

(٢) أخرجه البخاري ، الفتح ٩ / ٦٣٤ .

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) واللفظ له، والطبراني في المعجم الأوسط (٨٢٧٣). حسنه النووي في المجموع ٦/٥٢١، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٧/٦٨٥، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر، ١/٥١٠، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه، ١/٩٠: رجأله على شرط الصحيحين، وله شاهد من القرآن، ومن طُرُقٍ أُخَر، وقال ابن الملقن في شرح البخاري، ٢٥/٢٦٧ ثابت على شرط الشيخين.

وخلاصة ما سبق: أن من ذهب إلى القول بوجوب التسمية، وهم الظاهرية ومن وافقهم قالوا بأن الآية ناسخة للحديث، واعتمدوا على النص القرآني وحده، ولذا قالوا ببطلان التذكية وعدم حل الذبيحة متى تُركت التسمية عمداً أو سهواً. أي مطلقاً.

وأما من ذهب إلى القول بأن التسمية فرض مع الذكر ساقطة عند النسيان، وهم الجمهور، فقد اعتمدوا على ظاهر الآية الكريمة، في النهي عن الأكل مما لم يُذكر اسم الله عليه، واستندوا إلى سقوط التسمية عند النسيان إلى عموم الحديث الشريف في رفع الخطأ والنسيان عن كاهل هذه الأمة.

وأما من قال بأن التسمية سنة مؤكدة، وهم الشافعية، ومن وافقهم من المالكية والحنابلة، فقد جمع بين الآية الكريمة والحديث الشريف، وهو أولى من العمل بأحد الدليلين، وترك الآخر، ولذا حملوا الأمر بترك الأكل الوارد في الآية الكريمة على النذب، بناء على ما قرره جمهور العلماء من أن " الأمر الذي بعد الحظر يفيد الاستحباب"^(١) ومعلوم أن الآية الكريمة مكية ، والحديث المعارض نزل بالمدينة، فيكون مفيداً للاستحباب ليس إلا.

(١) شرح مختصر الروضة، لنجم الدين الطوفي، ٣٧٠/٢، حيث جاء فيه " صيغة الأمر الواردة بعد الحظر للإباحة ، وهو ظاهر قول الشافعي ، ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين ."

الترجيح:

والذي يترجح في نظرنا . والله أعلم، هو ما اذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهم الشافعية ومن وافقهم، من القول بأن التسمية سنة مؤكدة، لجمعهم بين العمل بالآية الكريمة والحديث الشريف، ومعلوم أن الجمع بين الدليلين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، ولأن نص الآية الكريمة عام، قد أوله العلماء بأن المراد ما ذكر عليه اسم غير الله، يعني ما ذبح للأصنام بدليل وصف الآية الكريمة له "بالفسق" والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله. وقد أوله الإمام أحمد بأن المقصود به الميتة، وذكر ما كان يقولونه " أتأكلون ما قتلتم - أي ذكيتم - ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون الميتة" ومع هذا الاحتمال للنص، لا يسوغ في النظر الفقهي إلا القول بالسنية، لا بالوجوب. والله أعلم.

كيفية التسمية:

اتفق الفقهاء من حيث الجملة على أن التسمية تتحقق بذكر اسم الله تعالى أي اسم كان لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ^(١) من غير فصل بين اسم واسم، وقوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) ^(٢) وسواء أقرن بالاسم الصفة بأن قال: الله أكبر، الله أجل، الله الرحمن، الله

(١) سورة الأنعام / ١١٨، ١١٩.

(٢) سورة الأنعام / ١٢١.

الرحيم ونحو ذلك أم لم يقرن بأن قال: الله أو الرحمن أو الرحيم أو غير ذلك؛ لأن المشروط بالآية ذكر اسم الله - عز شأنه - وكذا التهليل والتحميد والتسبيح، سواء أكان جاهلا بالتسمية المعهودة أم عالما بها^(١)

وقت التسمية:

لا خلاف بين الفقهاء في أن وقت التسمية على الذبيحة يكون عند الذبح.
(٢)

ولا بأس بتقديمها على الذبح بقليل^(٣)، والأصل فيها أن تكون مع حركة يد الذابح^(٤)

وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

(١) البدائع ٥ / ٤٨. الشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٣١٩. البجيرمي على الإقناع ٤ / ٢٥١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٢ - ٢٧٣. المقنع ٣ / ٥٤٠.

(٢) الفتاوى الهندية، ٥/٢٨٦: بدائع الصنائع للكاساني، ٥/٤٨، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي، ١/٥٧٤، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ٢/١٧١، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/١٥). روضة الطالبين للنووي، ٣/٢٠٥، الغرر البهية لذكريا الأنصاري، ٥/١٥٦. الإنصاف للمرداوي ١٠/٣٠٠، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ٣/٤٢١، مطالب أولي النهى للرحبياني، ٦/٣٣٣، المغني لابن قدامة، ٩/٣٨٩.

(٣) البدائع ٥ / ٤٨، ٤٩، والشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٣١٩.

(٤) المقنع بحاشيته ٣ / ٥٤٠.

١. قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ^(١)

وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ الذَّبْحَ مُضْمَرٌ فِيهِ، مَعْنَاهُ: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ الذَّبَائِحِ. وَلَا يَتَحَقَّقُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ إِلَّا وَقْتُ الذَّبْحِ^(٢)

ب. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَبَشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ " ^(٣)

وَجْهُ الدَّلَالَةِ:

أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَقُوعُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ^(٤)

ج وَلَئِنْ هَذِهِ مَبَادِئُ الذَّكَاةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ التَّسْمِيَةِ فَقَدْ مَضَى مِنْهَا شَيْءٌ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ، فَلَمْ يُذَكَّرْ كَمَا أُمِرَ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ وَبَيْنَ الشَّرْعِ فِي التَّذْكِيَةِ مُهْلَةً، فَلَمْ تَكُنِ الذَّكَاةُ مَعَ التَّسْمِيَةِ كَمَا أُمِرَ، فَلَمْ يُذَكَّرْ كَمَا أُمِرَ^(٥)

(١) الأنعام: ١٢١

(٢) البدائع ٥ / ٤٨، ٤٩

(٣) أخرجه البخاري (٥٥٥٨) واللفظ له، ومسلم (١٩٦٦).

(٤) فتح الباري لابن حجر، ١٠٠/١٨.

(٥) المحلى لابن حزم، ١٥٤/٦.

الشرط الثاني: استقبال القبلة:

ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب استقبال القبلة وهو مذهب السلف ^(١)

قال ابن قدامة: واستحبَّ ذلك [أي: استقبال القبلة]: ابنُ عمر، وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي ^(٢)

واستدلوا:

أ. بأن استقبال القبلة بالذبيحة قربة لا بُدَّ فيها من جهة، فكانت جهة القبلة أولى كالصلاة. ^(٣)

ب. و لأنَّ القبلة أفضل الجهات ^(٤)

ج. ولأن القبلة هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه.

(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ٣٦٥/٧، تبيين الحقائق للزيلعي، ٢٩٢/٥، منح الجليل لعليش، ٤٣١/٢، ويُنظر: شرح مختصر خليل للخرشي، ١٦/٣، المجموع للنووي ٤٠٧/٨ مغني المحتاج للشربيني، ٢٧٢/٤، الإنصاف للمرداوي، ٣٠٤/١٠، كشاف القناع للبهوتي ٢١٠/٦

(٢) المغني لابن قدامة، ٣٩٨/٩.

(٣) المجموع للنووي ٤٠٧/٨، الحاوي الكبير للماوردي، ٩٥/١٥.

(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، ٥٥٠/١، مغني المحتاج، للشربيني، ٢٧٢/٤.

د . ولأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة . ولا مخالف له من الصحابة .^(١)

وأوجب بعض المالكية استقبال القبلة بالذبيحة^(٢)

وقال بعض الحنفية بكرهية عدم استقبال القبلة بالذبيحة .^(٣)

الترجيح:

والراجع أن مسألة استقبال القبلة بالذبيحة، مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلاً تقاس عليه هذه المسألة، إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل، وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه، أو قياس شبه بعيد، وذلك أن القبلة هي جهة معظمة، وهذه عبادة، فوجب أن يشترط فيها الجهة، لكن هذا ضعيف، لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة، وقياس الذبح على الصلاة بعيد، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت .^(٤)

والله أعلم.

(١) بدائع الصنائع، ٤٩/٥

(٢) بداية المجتهد، ٢/٢١١.

(٣) حاشية ابن عابدين، ٦/٢٩٠.

(٤) بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٢١١.

الفصل الخامس

شروط المذكي

لا تصح الزكاة من كل إنسان حتى تتحقق فيه بعض الشرائط التي نص عليها الفقهاء استنباطاً من النصوص الشرعية. وفيما يلي تحرير محل النزاع، حتى تتضح المسألة.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على صحة تزكية من استجمع الشرائط الآتية: الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة.

كما اتفق الفقهاء على صحة تزكية أهل الكتاب "اليهود والنصارى" لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) ^(١)

كما اتفقوا على عدم صحة التزكية من المشركين عبدة الأصنام لقوله تعالى: (وما ذبح على النصب) ^(٢)، ولقوله: (وما أهل لغير الله به) ^(٣)

واختلف الفقهاء فيما يلي:

أولاً: تزكية المجنون:

تحرير محل النزاع:

(١) المائدة/٥

(٢) المائدة/٣

(٣) المائدة/٣

اتفق الفقهاء على أن المجنون إذا ذكي الذبيحة حال إفاقة من الجنون، فإن ذبيحته يحل أكلها.

واختلفوا: فيما لو ذبح المجنون حال جنونه على قولين:

القول الأول: إن تذكية المجنون حرام، ولا يحل أكل ذبيحته.

واليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابليّة، وهو قول للشافعيّة اختاره ابن المنذر، ومذهب الظاهريّة. (١)

واستدلوا بما يلي:

أ. افتقار الذكاة إلى نيّة بإجماع، والنيّة لا تصحّ منه، فلا تصحّ ذكاته (٢)

ب. أن القصد إلى التسمية عند الذبح شرط، ولا يتحقّق القصد الصحيح ممّن لا يعقل (٣)

ج. أنه غير مخاطب في حال ذهاب عقله، بقول الله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) (٤)

(١) الفتاوى الهندية، ٢٨٥/٥، ويُنظر: بدائع الصنائع للكاساني ١٤١/٥ مواهب الجليل للحطاب ٣١٢/٤، الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ٩٩/٢ المجموع للنووي، ٧٦/٩. الإنصاف للمرداوي ٢٩٣/١٠، ويُنظر: المغني لابن قدامة ٤٠٢/٩. الإقناع، ٣٨٥/١ المحلى ١٤٧/٦.

(٢) مواهب الجليل للحطاب ٣١٢/٤.

(٣) مواهب الجليل للحطاب ٣١٢/٤.

(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٤٥/٥.

القول الثاني: إن تزكية المجنون جائزة، ويحل أكل ذبيحته.

واليه ذهب الشافعية^(١)

واستدلوا:

بأن المجنون من جملة المسلمين.^(٢)

ب . ولأن القصد أو النية في الزكاة غير معتبر، فتصح ذكاته.^(٣)

سبب الخلاف:

اشتراط النية في الزكاة، فمن اشترط النية قال بعدم صحة تزكية المجنون وأن ذبيحته حرام لا يحل أكلها.

ومن ذهب إلى عدم اشتراط النية في التزكية، قال بصحة التزكية من المجنون، وحل أكل ذبيحته.^(٤)

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الجمهور

(١) المائدة: ٣

(٢) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للإمام الماوردي، ٩٣/١٥.

(٣) المرجع والمكان السابقين.

(٤) بداية المجتهد، ٢١٤/٢.

ثانياً: زكاة السكران:

اختلفت كلمة الفقهاء في صحة تزكية السكران على قولين:

القول الأول: إن تزكية السكران حرام، ولا يحل أكل ذبيحته.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: لحنفية، والمالكية، والحنابلة على الصحيح،

وهو قول للشافعية، اختاره ابن المنذر وهو مذهب الظاهرية. ^(١)

واستدلوا:

أ. بافتقار الزكاة إلى نية بإجماع، والنية لا تصح منه، فلا تصح زكاته،

ولأنه لا يتحقق قصد الصحيح ممن لا يعقل ^(٢)

ب. أنه غير مخاطب في حال ذهاب عقله، بقول الله تعالى: (إِلَّا مَا

ذَكَيْتُمْ) ^(٣)

القول الثاني: إن تزكية المجنون جائزة.

وإليه ذهب الشافعية. ^(١)

(١) العناية للبابرتي ٤٨٧/٩، ((الفتاوى الهندية)) (٢٨٥/٥). (مواهب الجليل))

للحطاب (٣١٢/٤)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (٩٩/٢).

((المجموع)) للنووي (٧٦/٩) ((الإقناع)) لابن المنذر (٣٨٥/١) ((المحلى)) لابن

حزم (١٤٧/٦)، ((المجموع)) للنووي (٧٧/٩).

(٢) بدائع الصنائع للكاساني ، ٤٥/٥ ، مواهب الجليل للحطاب (٣١٢/٤).

(٣) المائدة: ٣

واستدلوا ب بأن السكران من جملة المسلمين، فتصح تزكيتته. (٢)

ب . ولأن القصد أو النية في الزكاة غير معتبر، فتصح زكاته. (٣)

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في ذلك هو اشتراط النية في الزكاة، فمن اشترط النية قال بعدم صحة تزكية السكران، وأن ذبيحته حرام لا يحل أكلها. (٤)

ومن ذهب إلى عدم اشتراط النية في التزكية، قال بصحة التزكية من السكران، وحل أكل ذبيحته. (٥)

الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من القول بصحة التزكية من السكران، لما فيه من السعة، وعدم التضيق، ولأنه قد تمس الحاجة إلى أكل ذبيحته، فيكون في القول بحل ذبيحته تيسيراً على الناس ورفعاً للحرج عنهم كما قرر ذلك العلماء في مقاصد التشريع، والله أعلم .

ثالثاً: زكاة المجوسي:

(١) المجموع للنووي ، ٧٧/٩ ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للإمام الماوردي، ٩٣/١٥ .

(٢) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للإمام الماوردي، ٩٣/١٥ .

(٣) المرجع والمكان السابقين .

(٤) بداية المجتهد، ٢١٤/٢ .

(٥) بداية المجتهد، ٢١٤/٢ .

اختلف الفقهاء في حكم تذكية المجوسي للذبيحة، على قولين:

القول الأول: إن تذكيته حرام، ولا تحل ذبيحته.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابليّة (١)

واستدلوا:

أ. بقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٢)

وجه الدلالة:

نصّت الآية على حلّ ذبائح أهل الكتاب، والمجوسي ليس من أهل كتاب (٣)

ب. أنه لا تحلّ منّاكحتهم، فلا تحلّ ذبيحتهم (٤)

(١) تبيين الحقائق للزيلعي، ٢٨٧/٥، حاشية ابن عابدين، ٤٧٣/٦، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ٥٨٨/١، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني، ١٣/٣، الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، ٤٢٩/١، الفواكه الدواني للنفراوي، ٣٩٠/١، روضة الطالبين للنووي، ٢٣٧/٣، مغني المحتاج للشربيني ٢٦٦/٤، ويُنظر: أسنى المطالب لذكريا الأنصاري، ٥٥٣/١. كشف القناع للبهوتي ٢١٧/٦، شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ٤١٨/٣، مطالب أولي النهى للرحباني، ٣٣٠/٦، المغني لابن قدامة، ٣٩٣/٩

(٢) المائدة: ٥

(٣) المغني لابن قدامة ٣٩٣/٩، أسنى المطالب لذكريا الأنصاري ٥٥٣/١.

(٤) المجموع، للنووي، ٧٥/٩، مغني المحتاج للشربيني، ٢٦٦/٤.

القول الثاني: إن ذبيحته جائزة، ويحل أكلها.

وإليه ذهب وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية.

واستدلوا:

أ. بقوله تعالى: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ) ^(١)

وجه الاستدلال: إن المجوس أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك. ^(٢)

ب. قول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ^(٣)

سبب الخلاف:

والسبب في اختلاف الفقهاء، هو: اختلافهم في أصل دينهم، فمنهم من رأى أن المجوس كانوا أصحاب كتاب فرفع، كما روي عن علي، كرم الله وجهه، ولذا رأى حل ذبائهم.

ومنهم من يرى أنهم مشركون، ولذا لا تحل ذبائهم. ^(٤)

(١) المائدة: ٥

(٢) المحلى لابن حزم، ١٧/٩

(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب ١/ ٤٢١ رقم ٤٢، ومن طريقه الشافعي في الرسالة ص ٤٣٠ رقم ١١٨٢، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ٩/ ١٨٩،

انظر: الشوكاني، نيل الأوطار، ٨/ ٢١٢، الاستذكار لابن عبد البر، ٩/ ٢٩١، حديث رقم: ١٣٣٦١

(٤) فقه السنة للشيخ السيد سابق، ٣/ ٣٠٠

قال ابن المنذر: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقاً عليه.

ولكن أكثر أهل العلم عليه، لأنه ليس لهم كتاب، ولا يؤمنون بنبوة،
ويعبدون النار^(١)

الترجيح:

والذي نراه راجحاً . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز
تذكية المجوسي، وحرمة أكل ذبيحته، وأما ما يروى " سنوا بهم سنة أهل
الكتاب " فلم يثبت بهذا اللفظ، على أنه لا دليل فيه ، إذ المراد : سنوا بهم
سنة أهل الكتاب فيما ذكر من أخذ الجزية منهم ، ولو سلم بصحة هذا
الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ)^(٢) وفي رواية أخرى: " غير ناكحي نسائهم ولا آكلي
ذبائحهم " . والله أعلم .

رابعاً: تذكية من أهل بالذبيحة لغير الله تعالى:

المقصود بالإلهال لغير الله تعالى: هو أن يقصد الذابح بذبيحته غير
وجه الله تعالى، ومن ذلك: الذبح للأوثان، عند المشركين أو الذبح للأعياد
عند غير المسلمين أو الذبح للكنائس والمعابد عند أهل الكتاب.

(١) فقه السنة للشيخ السيد سابق، ١٠٤/٢

(٢) المائدة: ٥

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الذبح للوثن أو الصنم ، مع ذكر اسم الصنم أو الوثن على الذبيحة ، حرام ، لاتحل التنكية به ولا يؤكل منها، وذلك لقوله تعالى (وَمَا أَهْلَ لِيُغَيِّرِ اللَّهُ بِهِ) ^(١) ولقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ^(٢) لأنَّه إذا سَمِيَ غيرَ الله أو ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، فقد أتى بالصِّفَةِ التي حَرَّمَ اللهُ تعالى علينا الأكلَ مع وجودِها؛ لأنَّه أَهْلٌ لِغَيْرِ اللهِ به ^(٣)

كما اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط أن يكون اعتقاد أهل الكتاب في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين، ولا اعتقاد شريعتهم، لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخا، واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم، وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به، فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على الإطلاق، وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة ^(٤)

واختلف الفقهاء فيما لو ذبح أهل الكتاب لأعيادهم أو كنائسهم ومعابدهم على قولين:

(١) الأنعام/١٢١

(٢) المائدة/٣

(٣) المحلى لابن حزم، ١٥٤/٦.

(٤) بداية المجتهد لابن رشد، ٢١٤/٢.

القول الأول: يرى حل ذبائهم على هذا النحو مع الكراهة.

وإليه ذهب الإمام مالك، وهو رواية غير مشهورة عن الإمام أحمد ^(١)
واستدل المالكية لذلك بقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(٢)

وجه الاستدلال: إن الله تعالى أباح طعام أهل الكتاب، ومنه ذبائهم.
ونُوقش هذا: بأنه عام، مخصوص بقوله تعالى (وما أهل لغير الله به) ^(٣) ، والذبح في هذه الحال قد أهل لغير الله به ، فيكون حراماً.
وأجيب عن هذا: بأن قوله تعالى (وما أهل لغير الله به) ^(٤) من العموم المخصص بقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(٥)

القول الثاني: يرى حرمة ذبائهم وعدم الأكل منها.

وإليه ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، ونقل النهي عن ذلك، عن عائشة وعبد الله بن عمر. ^(١)

(١) بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٢١٤. البيان والتحصيل لابن رشد الجد، ٣/٢٧٢، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ٢/٥٣. الشرح الصغير مع بلغة السالك ١ / ٣١٤.

(٢) المائدة/٥

(٣) المائدة/٣

(٤) المائدة/٣

(٥) المائدة/٥

واستدل الشافعية ومن وافقهم بعموم (وما أهل لغير الله به) ^(٢)

وجه الاستدلال: أن الله تعالى حرم من الذبائح، ما قصد به غير الله، ولم يذكر عليه اسمه تعالى، فيكون ما يذبحه أهل الكتاب من هذا الصنف.

ونُوقش هذا: بأن الآية عامة، ويخصصها قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(٣)

وأجيب عنه بأن العكس هو الصحيح. ^(٤)

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو: تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب، وذلك أن قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(٥) يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى: (وما أهل لغير الله به) ^(٦) ويحتمل أن يكون قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به) ^(٧) مخصصا لقوله

(١) الإقناع بحاشية البجيرمي ٤ / ٢٥١، ٢٥٦. المقنع ٣ / ٥٤٤. اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ٥٣/٢.

(٢) المائدة/٣

(٣) المائدة/٥

(٤) بداية المجتهد، ٢/٢١٣.

(٥) المائدة/٥

(٦) المائدة/٣

(٧) المائدة/٣

تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(١) إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخر.

فمن جعل قوله تعالى: (وما أهل لغير الله به) ^(٢) مخصصاً لقوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(٣) قال: لا يجوز ما أهل به للكنائس والأعياد.

ومن عكس الأمر قال: يجوز. ^(٤)

الترجيح:

والذي نراه راجحاً . والله أعلم . هو ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من القول بحل ذبائح أهل الكتاب في أعيادهم مع الكراهة، وذلك لأن قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ^(٥) فسر بحل الذبائح، وأنها هي الطعام، ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب، من الكفار والمشركين، واحتج بهذا أهل العلم؛ ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله حجج شرعية.

(١) المائدة/٥

(٢) المائدة/٣

(٣) المائدة/٥

(٤) بداية المجتهد، ٢/٢١٣.

(٥) المائدة/٥

وفسروا المراد من قوله: (فَكُلُّوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) ^(١) بأن المراد به: ذبيحة المسلم والكتابي، إذا ذكر اسم الله عليه، أخذاً من مفهوم آية المائدة؛ وليس المقصود اتحاد الاعتقاد بيننا وبينهم ، وهذا هو المشهور المقرر عند أهل العلم . والله أعلم

خامساً: تذكية الغاصب والسارق:

اختلف الفقهاء في حكم تذكية الغاصب والسارق للحيوان الذي غصبه أو سرقه على قولين:

القول الأول: إن تذكية الغاصب والسارق للحيوان المغصوب أو المسروق تكون جائزة، ويحل أكل ما ذبحه.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعه ^(٢)

واستدلوا:

١. عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُوصِي الْحَافِرَ ، قَالَ: «أَوْسَعُ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ أَوْسَعُ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ» ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَلَقَّاهُ دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَأَصْحَابَكَ ، قَالَ: فَأَتَاهَا فَلَمَّا

(١) الأنعام/١١٩.

(٢) البيان والتحصيل لابن رشد الجد، ٢٨٧/٣، بداية المجتهد لابن رشد

الحفيد، ٢١٤/٢، الكافي لابن عبد البر ١٨١/١، المجموع للنووي، ٨٤/٩

جَلَسَ الْقَوْمُ أَتَى بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ قَبَيْنَا هُوَ يَأْكُلُ إِذْ كَفَّ يَدَهُ ، قَالَ: وَقَدْ كُنَّا جَلَسْنَا بِمَجَالِسِ الْعُلَمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ ، قَالَ: فَتَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَوُكَ أَكَلْتُهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ يَدَ ابْنِهِ حَتَّى يَزِمِيَ الْعِرْقَ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا». قَالَ: فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيعِ أَطْلُبُ شَاةً فَلَمْ أَصِبْ، فَبَلَّغَنِي أَنَّ جَارًا لِي اشْتَرَى شَاةً فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَتَنَهَى ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَبَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى»^(١)

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بعدم الكل من الشاة، بل أمر بإطعامها الأسارى، وهو يدل على حل التنكية من غير

(١) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، غير كليب -وهو ابن شهاب الجرمي- والد عاصم، فقد روى له البخاري في "رفع اليدين" وأصحاب السنن، وهو وابنه صدوقان لا بأس بهما. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد الفزاري، وزائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه أبو داود (٣٣٣٢) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٠٠٥) و (٣٠٠٦) ، وفي "شرح المعاني" ٢٠٨/٤ ، والدارقطني ٢٨٥/٤-٢٨٦ و ٢٨٦ ، والبيهقي في "السنن" ٣٣٥/٥ ، وفي "الدلائل" ٣١٠/٦ من طرق عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد. وزاد أبو داود والدارقطني في الأول، والبيهقي في "السنن" مسند أحمد، ١٨٥/٣٧، الحديث رقم: ٢٢٥٠٩

المالك حتى ولو كان غاصباً أو سارقاً، إذ لو لم تكن زكية لما أطمعها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحداً (١)

ب . ولأن صحة الملك ليست شرطاً من شروط التذكية.

القول الثاني: إن تذكية الغاصب والسارق للحيوان المغصوب أو المسروق تحرم، ولا يحل أكل ما ذبحه، لأنه من الميتة. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وداود بن علي. (٢)

واستدلوا بأن السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية. (٣)

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، هو اختلافهم في مدلول النهي، هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟

فمن قال: يدل على فساد المنهي عنه، قال: السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناولها وتملكها، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية.

(١) البيان والتحصيل لابن رشد الجد ، ٢٨٧/٣ ، شرح معاني الآثار لأبي جعفر

الطحاوي ، ٢٠٨/٤ ، الحديث رقم: ٦٤٠٨

(٢) البيان والتحصيل لابن رشد الجد ، ٢٨٧/٣ ، بداية المجتهد لابن رشد

الحفيد، ٢١٤/٢ ، الكافي لابن عبد البر ، ١٨١/١ ، المجموع للنووي ، ٨٤/٩

(٣) البيان والتحصيل لابن رشد الجد ، ٢٨٧/٣ ، بداية المجتهد لابن رشد

الحفيد، ٢١٤/٢

ومن قال: لا يدل النهي على فساد المنهي عنه إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل قال: تنكيتهم جائزة، لأنه ليس صحة الملك شرطاً من شروط التنكية. (١)

الترجيح:

والراجح: والله أعلم، هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بصحة تنكية الغاصب، والسارق، لقوة مأخذه، وسلامة دليله، ولما تقرر عند الجمهور من أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. والله أعلم.

(١) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ٢/٢١٥

باب الصيد

تمهيد:

تقدم في باب الذبائح: أن الذكاة نوعان: اختيارية واضطرابية، وأن الاختيارية تكون في الحيوان المستأنس المقدور عليه، وتتحقق بقطع الأربعة المذكورة: الحلقوم والمريء والودجين.

وأما الذكاة الاضطرابية، فتكون في الحيوان غير المقدور عليه مستأنساً كان أم متوحشاً.

فالذكاة الاضطرابية: هي الجرح في أي موضع كان من البدن عند العجز عن الحيوان، أي كأنها صيد فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام، وتسمى هذه الحالة: العقر.

وتتقسم دراستنا في هذا الباب إلى الفصول الآتية:

الفصل الأول: في حقيقة الصيد وحكمه ومحلّه.

الفصل الثاني: في شروط آلة الصيد.

الفصل الثالث: في شروط الصائد.

الفصل الأول

حقيقة الصيد وحكمه ومحلّه

تقسيم:

ندرس في هذا الفصل . بمشيئة الله تعالى . حقيقة الصيد اللغوية والفقهية، ثم ندرس حكم الصيد، وأخيراً ننتهي بمحل الصيد، وذلك في المباحث الآتية:

المبحث الأول

حقيقة الصيد

الصيد لغة: مصدر صاد يصيد، ويطلق على المعنى المصدرى، أي فعل الاصطياد، كما يطلق على المصيد، يقال: صيد الأمير، وصيد كثير، ويراد به المصيد، كما يقال: هذا خلق الله أي مخلوقه سبحانه وتعالى^(١) والصيد هنا بمعنى المصيد: ^(٢) يقول الله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)^(٣)

هذه حقيقة الصيد اللغوية.

(١) المصباح المنير، ولسان العرب، والقاموس، وانظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٥ / ٢.

(٢) حاشية الجمل ٥ / ٢٣٣، مغني المحتاج، ٤ / ٢٦٥، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٦ / ٢١٣.

(٣) سورة المائدة ٩٥.

وأما الحقيقة الفقهية:

فقد عرفه الفقهاء بإطلاقه الأول أي بالمعنى المصدري أي فعل الصيد بأنه "اقتناص حيوان متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه"^(١)

وأما عن تعريف الصيد بإطلاقه الثاني أي بمعنى المصيد فقد عرفه الفقهاء بأنه: "اسم لما يتوحش ويمتنع، ولا يمكن أخذه إلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه"^(٢)

أو هو "حيوان مقتنص حلال متوحش طبعاً، غير مملوك ولا مقدور عليه"^(٣)

وظاهر من حقيقة الصيد الفقهية: أن الفقهاء يستعملونه مصدراً، وبمعنى ما صيد وما يصاد أيضاً، لكنهم حينما يستعملونه مصدراً يطلقونه تارة على إزالة منعة ما كان ممتنعاً من الحيوانات، وتارة على إزهاق روح الحيوان البري المتوحش بإرسال نحو سهم أو كلب أو صقر، فيرادف "العقر" المتقدم، وحينما يستعملونه بمعنى ما صيد يقصدون به تارة ما

(١) بحر المذهب للرويانى، ١٠٦/٤ كشف القناع ٦ / ٢١٣. المختصر الفقهي لابن عرفه، ٢٨٣/٢.

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٣٥. حاشية الجمل على شرح المنهج، ٢٢٣/٥

(٣) حاشية الجمل على شرح المنهج، ٢٢٣/٥ ، كشف القناع ٦ / ٢١٣.

أزيلت منعتة، وتارة ما أزهرت روحه من الحيوان البري المتوحش. وحينما يستعملونه بمعنى ما يصاد يريدون به الحيوان البري المتوحش.

المبحث الثاني

حكم الصيد

١. ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بإباحة الصيد. ^(١)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمت حراماً) ^(٢)، ثم قال: (وإذا حللتهم فاصطادوا) ^(٣)

واتفق العلماء على أن الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النهي يدل على الإباحة، كما اتفقوا على ذلك في قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) ^(٤) أعني أن المقصود به الإباحة؛ لوقوع الأمر بعد النهي، وإن كان اختلفوا هل الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة؟ أو لا يقتضيه، وإنما يقتضي على أصله الوجوب؟ ^(٥)

(١) تبين الحقائق للزيلعي ٦ / ٠٣، حاشية الجمل على شرح المنهج، ٢٢٣/٥ ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٤٠.

(٢) المائدة: ٩٦

(٣) المائدة: ٢

(٤) الجمعة: ١٠

(٥) بداية المجتهد، ٣/٥.

وأما السنة فأحاديث، منها: حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فما يحل لنا منها؟ فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل^(١)

وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالقوس، والكلب المعلم، والكلب غير المعلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صدت بقوسك فاذا ذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذا ذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل^(٢)

وأما الإجماع فبيانه أن الناس كانوا يمارسون الصيد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهود أصحابه وتابعيهم من غير نكير.

وأما المعقول: فهو أن الصيد نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك، وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف، فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب^(٣)

٢. وذهب الإمام مالك إلى القول بکراهة الصيد الذي يقصد به السرف.^(٤)

(١) أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٦١٢) .

(٢) أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٦١٢) ومسلم (٣ / ١٥٣٢)

(٣) تبیین الحقائق للزليعي ٦ / ٥٠.

(٤) بداية المجتهد، ٥/٣.

واستدل المالكية لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (١) . أي هدفا.

كما استدلوا بأن في الصيد إذا كان المقصود منه التلهي والعبث، فهو إضاعة الوقت فيما لا ينفع، والمسلم مطالب بالانتفاع بوقته فيما يقيد به. (٢)

٣. وذهب بعض الحنفية إلى القول بکراهة الاصطياد عموما واتخاذ حرفة. (٣)

وقد رده الحصكفي وابن عابدين: وقالوا: إن التحقيق إباحة اتخاذه حرفة، لأنه نوع من الاكتساب، وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح - قال ابن عابدين: وهذا إذا لم يكن الكسب بالربا والعقود الفاسدة، ولم يكن بطريق محظور، فلا يذم بعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض (٤)

(١) أخرجه مسلم (٣ / ١٥٤٩) من حديث ابن عباس.

(٢) الشامل في فقه الإمام مالك، تاج الدين السلمي، ١/ ٢٥٠.

(٣) الدر المختار على هامش ابن عابدين ٥ / ٣٠٦.

(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٧.

المبحث الثالث

محل الصيد

١. قصد الأكل في الحيوان:

محل الصيد هو الحيوان المصيد، وهو إما أن يكون مقصوداً به الأكل، وإما أن يكون مقصوداً به مطلق الصيد.

أ. فإن كان المقصود منه الأكل، فقد اتفقت كلمة الفقهاء على يشترط في المصيد أن يكون حيواناً مأكول اللحم أي جائز الأكل^(١)

ب أما إن كان المقصود من الصيد هو مطلق صيد الحيوان، وليس الأكل، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين.

القول الأول: لا يشترط أن يكون الصيد مأكول اللحم، بل يجوز عندهم صيد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه، أو لدفع شره، وكُلَّ مشروع.

وإليه ذهب الحنفية والمالكية.^(٢)

القول الثاني: لا يجوز صيد أو ذكاة غير مأكول اللحم.

(١) الدر المختار بهامش رد المحتار ٥ / ٣٠٥. جواهر الإكليل ١ / ٢١٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ٢ / ١٠٨ البجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٤٨، وحاشية الباجوري على ابن قاسم ٢ / ٢٩٢. مطالب أولي النهى ٦ / ٢٤٢.

(٢) الدر المختار بهامش رد المحتار ٥ / ٣٠٥. جواهر الإكليل ١ / ٢١٣، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ٢ / ١٠٨.

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، وقالوا إن صيد غير مأكول اللحم يكون في حكم الميتة، فلا يؤثر الصيد فيه، ولا يُنتفع منه بشيء. (١)

الترجيح:

والراجح: . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الجمهور، إذ الأصل في الصيد هو الحل، وهذا القدر متفق عليه عند الفقهاء، وأما ما ذهب إليه المالكية والحنفية، فهو بعض الصور التي يكره فيها الاصطياد، وهو مأخوذ من حكمة التشريع في المباحات، لأن الله تعالى أحل للإنسان ما فيه نفع له وعدم إسراف، ولهو، ودخول هذه الأشياء في الاصطياد، تتنافى مع مقصود الشارع من الحل، والله أعلم.

٢. صيد الحيوان المتوحش:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن محل الصيد من الحيوان البحري، وهو السمك وأصنافه، ومن الحيوان البري الحلال الأكل الغير مستأنس.

واختلف الفقهاء فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر على أخذه ولا ذبحه أو نحره، كان يكون ممتنعاً عن الآدمي بشروده أو صياله على صاحبه على قولين:

(١) البجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٤٨، وحاشية الباجوري على ابن قاسم ٢ /

٢٩٢. مطالب أولي النهى ٦ / ٢٤٢.

القول الأول: إن هذا الحيوان حكمه حكم الصيد يحل بالعقر والجرح بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه في أي موضع قدر عليه.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم - وبه قال مسروق والأسود والحسن وعطاء وطاووس وإسحاق والشعبي والحكم وحماد والثوري^(١)

واستدلوا بما روى رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلًا وغنمًا، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، ففعلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه، فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا وفي لفظ: فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا^(٢)

(١) البدائع ٥ / ٤٣، ونهاية المحتاج ٨ / ١٠٨، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٦٦،

٥٦٧، ومغني المحتاج ٨ / ١٠٨.

(٢) أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٣١) ومسلم (٣ / ١٥٥٨) والسياق للبخاري، واللفظ الآخر للبخاري كذلك (فتح الباري ٩ / ٦٢٣) .

وجه الاستدلال من النص الشريف ظاهر، حيث أباح النبي صلى الله عليه وسلم تذكية الحيوان المستأنس الذي شرد بالعقر، وهو نص محل النزاع.

ولأن الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيتة في الحلق واللثة، فكذلك الأهلي إذا توحش يعتبر بحاله^(١)

القول الثاني: إنه لا بد من التذكية في الحيوان المستأنس الذي توحش، وذكاته تكون بالذبح فيما يذبح كالبقر ونحوها، والنحر فيما ينحر كالإبل ونحوها، وأما العقر فلا يحل به الحيوان.

وإلى هذا القول ذهب المالكية في المشهور عندهم^(٢)

واستدلوا: بأن الأصل أن يكون المصيد وحشياً، ولذا تتم تذكيتة بالعقر، وأما التوحش فهو حالة طارئة علي الحيوان المستأنس، فيبقى على أصله في التذكية، وهي الذبح أو النحر، ولا يجزئ في ذكاته العقر.^(٣)

وئوقش ما ذهب إليه المالكية بأن غير المقدور عليه لا يمكن فيه الذبح أو النحر، فيجري عليه حكم الصيد الوحشي بأن يذكي بالعقر حيث قُدر عليه، صيانة للأموال.^(٤)

(١) المغني ٨ / ٥٦٧.

(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٠٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٨٢.

(٣) المرجعان السابقين، نفس المكان.

(٤) بداية المجتهد، ٦/٣.

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هو وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبر، وذلك أن الأصل في هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر، وأن الوحشي يؤكل بالعقر.

وأما الخبر المعارض لهذه الأصول فحديث رافع بن خديج، وفيه قال: «فند منها بغير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فحبسه الله تعالى به، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا»^(١).

فمن تمسك بالأصل في تذكية الحيوان المستأنس قال لا يحل تذكيته بالعقر ولو توحش، لأن الأصل في الحيوان المستأنس أن تكون تذكيته بالذبح أو النحر.

ومن أخذ بمدلول الحديث الشريف، وهم الجمهور، قال بجواز تذكية الحيوان المستأنس بالعقر متى توحش لورود النص فيه. ووجوب المصير على العمل به.^(٢)

(١) أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٣١) ومسلم (٣ / ١٥٥٨) والسياق للبخاري، واللفظ الآخر للبخاري كذلك (فتح الباري ٩ / ٦٢٣).

(٢) بداية المجتهد، ٦/٣.

الترجيح:

ونحن نرى . والله أعلم . أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز تذكية الحيوان المستأنس بالعقر متى شرد فصار متوحشاً هو الراجح، لأنه وإن كان الأصل في التذكية في المستأنس بالذبح أو النحر، إلا شروده أضفى عليه صفة التوحش، فكان غير مقدور عليه، وعدم القدرة هي العلة في جواز عقر الحيوان المتوحش، لا لأنه وحشي فقط، فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشي، فيتفق القياس والسماع، فيكون القول بهذا الحديث أولى لصحته؛ لأنه لا ينبغي أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل. (١)

٣. أثر عدم القدرة على الحيوان في تذكية الصيد.

اتفق الفقهاء على أن الحيوان غير المقدور عليه إذا كان متوحشاً بأصله، فإنه يشترط في حل تذكيته بالعقر أن يبقى على حالة عدم القدرة عليه حتى يتم اصطياده. أما إذا صار مقدوراً عليه، فإنه لا تحل تذكيته بالعقر، بل يرجع فيه إلى الأصل، وهو الذبح أو النحر. (٢)

(١) بداية المجتهد، ٦/٣.

(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ٦٠، ٦١، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ٢ /

١٠٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٨٢، ١٨٣، والبجيرمي على المنهج ٤ /

٢٩١.

وزيادة في فهم المسألة، نسوق بعض الصور التي يتضح بها تطبيق ما أوردناه.

أ. إذا تأنس حيوان وحشي الأصل، كالظبي مثلاً، أو قدر على الحيوان المتوحش بطريقة أخرى، غير العقر، كأن وقع في حباله الصائد أو شبكه مثلاً، فإن تذكّيته لا تكون بالعقر، وإنما بالذبح، لأنه صار مقدوراً عليه.^(١)

ب. إذا تأنس الحيوان البري المتوحش بحسب الأصل كالظبي، ثم شرد وتوحش مرة أخرى، فأصبح غير مقدور عليه، فيؤكل بالاصطياد أي العقر حيث قدر عليه. لأن العلة وهي عدم القدرة عليه ما دامت موجودة فيجري عليه حكمها، إذ العلل تدور مع الأحكام وجوداً وعدماً.^(٢)

ج. من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار، ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل، لأنه صار مقدوراً عليه بالرمي الأول، فوجبت تذكّيته بالذبح لكونه صار مقدوراً عليه، بالرمية التي رماها الصائد الأول.^(٣) وكل هذا محله إذا لم تكن حياة الصيد حياة مذبوح، بل كانت حياة مستقرة.^(١)

(١) الزيلعي على كنز الدقائق ٦ / ٦٠، حاشية الدسوقي ٢ / ١٠٣، والمغني لابن

قدامة ٨ / ٥٥٩، وانظر كذلك كشاف القناع ٦ / ٢١٥.

(٢) المغني لابن قدامة ٨ / ٥٥٩، ٥٦٠.

(٣) البدائع ٢ / ٢٠٧، ٢٠٩، وابن عابدين ٢ / ٢١٢

٤. أثر إدراك الحيوان غير المقدور عليه حياً بعد الصيد في التذكية:

لكي، يؤثر العقر في تذكية المصيد غير المقدور عليه، يشترط الفقهاء ألا يُدرّكه الصائد، وبه حياة مستقرة بعد الإصابة، وعلى هذا: فالشرط في حل الحيوان غير المقدور عليه عن طريق التذكية بالعقر، هو إدراك الحيوان وهو ميت بسبب آلة الصيد، فلو أدرك الصائد الحيوان المصيد، أو أتت به الجارحة، فوجده الصائد به حياة غير مستقرة، فهو في حكم الميت أيضاً، ويحل أكله بالعقر، فلو ذبحه أو أمر السكين عليه كان مستحباً.

أما إذا وجد الصائد الصيد حياً حياة مستقرة بعد الإصابة، أو كان بحيث لو ذهب إليه لوجده كذلك ولم يذبحه مع تمكنه من ذلك، فمات لم يحل أكله، لأن ذكاته تحولت من الجرح إلى الذبح، فإذا لم يذبح كان ميتة^(٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما رد عليك كلبك المكلب، وذكرت اسم الله

(١) البدائع ٢ / ٢٠٧، ٢٠٩، وابن عابدين ٢ / ٢١٢، والدسوقي ٢ / ٧٢، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٤، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤٤، ٣٤٥.

(٢) البدائع ٥ / ٥١، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٢، المجموع للنووي ٩ / ١١٤، مغني المحتاج ٤ / ٢٦٩، المغني لابن قدامة ٨ / ٥٤٧ - ٥٤٨، كشف القناع ٦ / ٢١٦، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٠٢، الزيلعي ٦ / ٢٥٣، نهاية المحتاج ٨ / ١٠٩، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ١٠٧.

عليه، وأدركت ذكاته فذكه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل، وما ردت عليك يدك، وذكر اسم الله وأدركت ذكاته فذكه، وإن لم تدرك ذكاته فكله" (١)

٥. حكم صيد الحرم:

اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يحرم في الحرم صيد الحيوان البري - أي ما يكون توالده وتتاسله في البر - سواء أكان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم.

أما الحيوان البحري فالإجماع قائم على حل اصطياده وأكله. لقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْغِيَاةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢).

قال ابن العربي - رحمه الله -: (لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٣) جَرَى عَمُومُهُ عَلَى كُلِّ صَيْدٍ بَرِيٍّ وَبَحْرِيٍّ، حَتَّى جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٤))

(١) أورده بهذا اللفظ الشيرازي في المذهب (٩ / ١١٤ - بشرح النووي) . وقال النووي: " أخرجه البخاري ومسلم مختصرا ". وهو في البخاري (فتح الباري ٩ / ٦١٢) ومسلم (٣ / ١٥٣٢) من حديث أبي ثعلبة.

(٢) المائدة: ٩٦

(٣) المائدة: ٩٥

(٤) المائدة: ٩٦

فأباح صيدَ البحرِ إبّاحةً مطلقةً، وحرّمَ صيدَ البرِ على المُحرّمين، فصار هذا التقسيم والتّوزيع دليلاً على خروج صيد البحر من النّهي^(١)

وإبّاحة صيد البحر للمُحرّم محلّ إجماع بين العلماء، نقله: ابن المنذر، وابن حزم، وابن قدامة، وغيرهم.^(٢)

ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة صيد الحرم المكي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، إنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها"^(٣)

فقد أفاد الحديث الشريف أن الحرم المكي بحدوده المعروفة إلى اليوم، يحرم الاصطياد فيه، ولا شك أن الحرمة هنا تشمل المحرم والحلال، كما تشمل إيذاء الصيد وتغييره والمساعدة على الصيد بأي وجه من الوجوه، مثل الدلالة عليه، أو الإشارة إليه أو الأمر بقتله^(٤)

(١) أحكام القرآن، لابن العربي، ١٧٥ / ٢

(٢) الإجماع لابن المنذر، ص: ٥١. مراتب الإجماع لابن حزم، ص: ٤٤،

المغني لابن قدامة، ٢٧٠ / ٣

(٣) أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) البدائع ٢ / ٢٠٧، ٢٠٩، وابن عابدين ٢ / ٢١٢، والدسوقي ٢ / ٧٢،

ومغني المحتاج ١ / ٥٢٤، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤٤، ٣٤٥.

قال العلماء: ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإلتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حُرِّمَ التنفير فالإلتلاف أولى^(١)

وهل الحرمة تشمل كل أنواع الحيوان البري المأكول منه وغير المأكول؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: إن الحرمة تشمل جميع أنواع الحيوان البري المأكول وغير المأكول.

وإليه ذهب الحنفية والمالكية.^(٢)

واستدلوا بعموم الحديث السابق، حيث لم يفرق بين المأكول وغير المأكول.

القول الثاني: إن الحرمة تقتصر على الحيوان المأكول فقط دون غيره.

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة^(٣)

والراجح . والله أعلم . ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، من القول بتحريم جميع أنواع الحيوان، المأكول وغير المأكول لدخول الجميع تحت عموم النهي.

(١) شرح النووي على صحيح مسلم، (٩ / ١٢٦).

(٢) البدائع ٢ / ٢٠٧، ٢٠٩، والزيلعي ٢ / ٦٣، ٦٩، وابن عابدين ٢ / ٢١٢، والدسوقي ٢ / ٧٢، والخطاب ٣ / ١٧٠، ١٧١،

(٣) مغني المحتاج ١ / ٥٢٤، والمغني ٣ / ٣٤٤، ٣٤٥.

٦. تأثير غياب المصيد عن صائده في التذكية:

اشترط الفقهاء لصحة تذكية الصيد، ألا يغيب الحيوان المصيد عن الصائد مدة طويلة وهو قاعد عن طلبه، فإن غاب الصيد عن الصائد، وتوانى الصائد في تتبع المصيد، ومعرفة أثر آلة الاصطياد فيه، لم يحل أكله أما إذا لم يغيب الحيوان المصيد، ولم يقصر الصائد في البحث عنه، فهنا يحل تذكيته بآلة الصيد ويكون حلال الأكل. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة.

والغرض من اشتراط هذا الشرط هو حصول التيقن أو الظن، أي الاعتقاد الراجح، بأن ما وجده قبل الغياب، أو بعده مع استمرار الطلب هو صيده، وما أرسله من السهم أو الكلب أو نحوهما من الآلة هو الذي أصابه وأماته دون غيره. (١)

وتفريعاً على هذا الأصل فقد ذكر الفقهاء بعض الصور التي يحرم فيها المصيد ولا تحل تذكيته بالاصطياد. ومن هذه الفروع:

أ - إذا غاب الصيد بعد إرسال السهم أو الكلب عليه، ثم وجده ميتاً وفيه جرح آخر غير سهمه، لم يؤكل باتفاق الفقهاء، لأنه مشكوك فيه هل قتل بسهمه أو بسهم آخر، وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن

(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ٣٠١، ٣٠٢، نقلاً عن الهداية والزيلعي، والقوانين الفقهية ص ١٨٢، ١٨٣، ونهاية المحتاج للرملي ٨ / ١١٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع ٦ / ٢٢٠، ٢٢١.

جده أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أفنتي في قوسي، قال: ما رد عليك سهمك فكل. قال: وإن تغيب علي؟ قال: وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك (١)

ب - إن أرسل سهماً أو كلباً إلى الصيد وغاب عنه، ففقد عن طلبه غير متحامل على المشي (٢)، ثم وجده ميتاً لا يحل ما لم يعلم جرحه بسهمه يقيناً، كما صرح به الحنفية (٣)

(١) أخرجه النسائي في سننه، ١٩١/٧، حديث : ٤٢٩٦، قال محققه : حسن

صحيح

(٢) التحامل على المشي هو أن يتكلفه على مشقة وإعياء (ابن عابدين ٥ / ٣٠١).

(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٠١، وانظر كشف القناع ٦ / ٢١٨ . ١٢٨

الفصل الثاني

آلة الصيد

المقصود بآلة الصيد: الوسيلة المستخدمة في اصطياد الحيوان البري.

وهذا الآلة إما أن تكون أداة جامدة كالسهم والسيف والطلق الناري، وإما أن تكون حيوانا.

وعلى هذا ندرس آلة الصيد في مبحثين:

المبحث الأول

آلة الصيد الجامدة

أداة الصيد الجامدة: منها: ما له حد يصلح للقطع، كالسيف والسكين، ومنها ما ينطلق من آلة أخرى وله رأس محدد يصلح للخزق^(١) كالسهم، ومنها ما له رأس محدد لا ينطلق من آلة أخرى كالحديدة المثبتة في رأس العصا، أو العصا التي بري رأسها حتى صار محددا يمكن القتل به طعنا.

وهذه الأدوات ونحوها يجوز الاصطياد بها إذا قتلت الصيد بحدّها أو رأسها وحصل الجرح بالمصيد بلا خلاف.

أما الآلات التي لا تصلح للقتل بحدّها ولا برأسها المحدد، وإنما تقتل بالثقل كالحجر الذي لم يرقق، أو العمود والعصا غير محددة الرأس، أو

(١) الخزق: النفوذ في الجسم، يقال: خزق السهم القرطاس: نفذ منه ، انظر:

المصباح المنير ص: ٥٥ .

المعارض^(١) أبعرضه ونحوها، فلا يجوز بها الاصطياد، وإذا استعملت فلا بد في المرمي من التذكية، وإلا لا يحل أكله.

وكذلك جميع الآلات المحددة إذا استعملت وأصابت بعرضها غير المحدد لا يحل المرمي بها إلا بالتذكية^(٢)

وعلى هذا: يمكن القول بأن آلة الصيد يشترط فيها: ما يلي:

الشرط الأول: أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق، وإلا لا يحل بغير الذبح.

وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء.^(٣)

(١) المعارض: سهم يُرمى به بلا ريش ولا نصل يَمْضِي عَرْضاً فيصيب بعرض العود لا بحدّه. انظر لسان العرب: ٧/ ١٦٥. المغني ٨ / ٥٥٨، وقال عياض المعارض: عصى فى طرفها حديدة، ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي، محمد الأمير المالكي، ١٠٣/٢. وقال الماوردي، فأما المعارض. فهو آلة تجمع خشبا وحديدا، فإن أصاب بحدّه أكل، وإن أصاب بعرضه فهو وقيد. الحاوي الكبير للماوردي، ٢٥/١٥.

(٢) تبين الحقائق للزيلعي ٦ / ٥٩، والقوانين الفقهية ص ١٨١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٤، وحاشية البجيرمي على المنهج ٤ / ٢٩٠، وكشاف القناع ٦ / ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٥٩.

(٣) تبين الحقائق للزيلعي ٦ / ٥٩، والقوانين الفقهية ص ١٨١، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٤، وحاشية البجيرمي على المنهج ٤ / ٢٩٠، وكشاف القناع ٦ / ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٥٩.

الشرط الثاني: أن تصيب الصيد بعدها فتجرحه، ويتيقن كون الموت بالجرح، وإلا لا يحل أكله؛ لأن ما يقتل بعرض الآلة أو بثقله يعتبر موقوذة. (١)

واستدل الفقهاء على حرمة المصيد الذي مات دون أن تجرحه الآلة ويموت نتيجة لجرحها له بما يلي:

أ. بقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (٢)

ب. ولما روي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله (٣)

ج. وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت فسميت فخرقت فكل، فإن لم يتخرق فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت (٤)

(١) تبين الحقائق ٦ / ٥٨، ٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٤، وكشاف القناع ٦ / ٢١٩.

(٢) المائدة/٣

(٣) أخرجه مسلم (٣ / ١٥٢٩) .

(٤) أخرجه أحمد (٤ / ٣٨٠) من حديث عدي بن حاتم.

د . ولما ورد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تتكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين^(١)

حكم ما صيد بالمِعْراض:

اختلف الفقهاء في حكم ما صيد بالمِعْراض، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أصحابه أن ما قتله المِعْراض أو الحجر بثقله أو بحدّه إذا خرق جسد الصيد هو حلال طيب، وتذكيته صحيحة، وأما إذا لم يخرق جسد الصيد بحدّه ولم ينهر الدم، وإنما قتل الصيد بثقله، فهو كالحجر، لا تحل تذكيته، ولا يجوز أكله .

واليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة، وهو قول على وعثمان، وعمار، وابن عباس. وبه قال النخعي، والحكم، وهو قول الثوري وغيره.^(٢)

واستدلوا:

أ. بقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)^(٣)

(١) أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٩٩) ومسلم (٣ / ١٥٤٨) من حديث عبد الله بن مغفل، واللفظ لمسلم.

(٢) المائدة/٣

(٣) بدائع الصنائع، ٤٩/٥، شرح مختصر الطحاوي، ٢٤٥/٧، المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، عبد الوهاب البغدادي، ٦٨٠/١، المدونة:

وجه الاستدلال: أن الآية الكريمة أباحت أكل ما تمت تذكيته بالآلة التي تنهر الدم، وحرمت الموقوذة، والمصيد إذا أصيب بحد المعارض، كان في حكم الصيد الذي تمت تذكيته بآلة حادة ما دام أنه قد أنهر الدم، وأما ما أصابه المعارض، بعرضه فقتل الطير بثقله، فهو في حكم الموقوذة، فلا يحل أكله بنص الآية الكريمة، إذ الموقوذة هي المضروبة بالحجارة أو بالعصا حتى تموت. (١)

ب . ما روي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرمي الصيد بالمعارض فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعارض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله (٢)

وجه الاستدلال من الحديث الشريف ظاهر، حيث أباح النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن يأكل مما أصابه المعارض بحد فأسال منه الدم، لأنه عقر صحيح، وتذكية طيبة، وأما الصيد الذي أصابه المعارض

١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧. بداية المجتهد، ٧/٣، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، خليل بن إسحاق، ٣/ ١٧٨، الحاوي الكبير، للماوردي، ٦/ ١٥، المهذب للشيرازي، ١/ ٤٦٢، بحر المذهب، للرويانى، ٤/ ١٠٧، التهذيب لابن الفراء، ٨/ ١٥، مختصر الخرقى، ص: ١/ ١٤٤، المغني لابن قدامة، ٩/ ٣٨٣.

، (١) بداية المجتهد، ٧/٣، البيان للعمرائى، ٤/ ٤٥٨، العزيز شرح الوجيو، للرافعى، ١٢/ ١٦.

(٢) أخرجه مسلم (٣ / ١٥٢٩) .

بعرضه فلم يسئل منه الدم، فلم يباح له أكله لأن التكية حينئذ فاسدة، لأن المعارض قتل المصيد بثقله لا بحدّه.

القول الثاني: يرى أصحابه أن الصيد الذي أصيب بالمعارض، لا يحل أكله ولا تصح تذكّيته إلا إذا تم ذبحه وسال منه الدم.

وإليه ذهب ابن عمر والحسن البصري. (١)

واستدلوا بقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) (٢)

وجه الاستدلال: أن المصيد الذي أصيب بالمعارض، فقتله، يكون في حكم الموقوذة، فإذا أدرك الصائد مصيده حيّاً ذكاه بالذبح، وإلا فلا يحل لكونه من الموقوذة التي حرّمها الشارع الحكيم. (٣)

القول الثالث: يرى أصحابه أن الصيد الذي تم اصطياؤه بالمعارض تذكّيته صحيحه، ويحل أكله، سواء أصابه المعارض بحدّه أم بثقله.

وإليه ذهب الأوزاعي، وأهل الشام. (٤)

(١) بداية المجتهد، ٧/٣، المغني لابن قدامة، ٣٨٣/٩.

(٢) المائدة/٣

(٣) المغني لابن قدامة، ٣٨٣/٩.

(٤) بداية المجتهد، ٧/٣، المغني لابن قدامة، ٣٨٣/٩. المقنع لابن قدامة،

ص: ٤٥٧.

واستدلوا: بأن الحيوان المصيد، إنما تكون تذكيتة بالعقر، لا بالذبح، لأن العقر هو حكم الصيد، وحينئذ فلا يُستلزم تذكيتة بالذبح، سواء أصابه المعارض بالخرق فسال نمنه الدم أم أصابه بثقله فقتله. ^(١)

سبب الخلاف:

وسبب اختلافهم معارضة الأصول في هذا الباب بعضها بعضاً، ومعارضة الأثر لها. وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيز محرم بالكتاب والإجماع، ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد؛ فمن رأى أن ما قتل المعارض وقيز منعه على الإطلاق، ومن رآه عقراً مختصاً بالصيد، وأن الوقز غير معتبر فيه - أجازة على الإطلاق. ومن فرق بين ما خرق من ذلك، أو لم يخرق - فمصييراً إلى حديث عدي بن حاتم المتقدم، وهو الصواب. ^(٢)

الشرط الثالث: أن يصيب الرمي الصيد مباشرة، ولا يعدل عن جهته.

اشتراط الفقهاء لكي يكون الصيد حلالاً، وتجاوز تذكيتة أن تصيب الآلة التي صوبها الصائد المصيد على نحو مباشر، بمعنى ألا تلتوي آلة الصيد، كأن تردّها الريح أو تصطدم بحجر، فيثنيها أو يغير اتجاهها نحو المصيد، فإذا حدث ذلك، فقد خالفت الآلة الشرط المذكور، ولذا وقع فيه الخلاف الفقهي.

(١) بداية المجتهد، ٧/٣، المغني لابن قدامة، ٣٨٣/٩.

(٢) بداية المجتهد، ٧/٣،

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على أنه إذا أصابت آلة الصيد المصيد مباشرة، فهو عقر حلال، وتذكية يحل بها الصيد. (١)

واختلفوا فيما لو أثنت الريح آلة الصيد أو اصطدمت بحجر أو جبل أو جدار بيت أو شجر، ثم ارتدت إلى المصيد المقصود أو على مصيد آخر، فأصابته فهل تكون إصابتها له تذكية شرعية يحل أكله بها، أم لا، وذلك على قولين:

القول الأول: إن هذا الصيد لا يحل لعدم وقوع التذكية على النحو المطلوب. وإليه ذهب الحنفية، فقالوا: إذا رد السهم ريح إلى ورائه، أو يمنة أو يسرة، فأصاب صيدا لا يحل، وكذا لو رده حائط أو شجرة (٢)

القول الثاني: إن الصيد لا يحرم وتذكيته صحيحه. وإليه ذهب الشافعية والحنابلة، حيث قالوا: لو قتل الصيد بإعانة الريح للسهم لم يحرم، (٣) وزاد الحنابلة: أنه لو رد السهم حجر أو غيره على الصيد فقتله لم يحرم، لعسر الاحتراز عنه (٤)

(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ٣٠٠، ٣٠١. حاشية البجيرمي

على شرح المنهج ٤ / ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥٢.

(٢) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ٣٠٠، ٣٠١.

(٣) حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٤ / ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥٢.

(٤) مطالب أولي النهى ٦ / ٣٥٢.

ولأنَّ ما يَتَوَلَّدُ مِنْ فِعْلِ الرَّامِي مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَا اخْتِيَارَ لِلسَّهْمِ^(١)

الشرط الرابع: أَلَّا تَكُونَ آلَةُ الصَّيْدِ مَسْمُومَةً بِمَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ الْآلَةِ.

اختلف الفقهاء في حل المصيد بآلة مسمومة على قولين:

القول الأول: يرى عدم جواز الاصطياد بالسهم المسموم إذا تيقن أو ظن

أن السم أعان على قتل الصيد أو احتمل ذلك^(٢)

وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، وقول للمالكية،^(٣) واختاره ابن حزم^(٤).

واستدلوا:

أ. بأن ما قُتِلَ بالسَّمِّ فهو مَيْتَةٌ^(٥)

ب. ولأنه إذا اجتمع في قتل المصيد مبيح ومحرم، فغلب المحرم، كما لو

اجتمع سهم مجوسي ومسلم في قتل الحيوان. فإن لم يحتمل ذلك فلا

يحرّم.^(٦)

(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، ٣٣٢/٩.

(٢) التاج والإكليل للمواق، ٢١٧/٣، المغني لابن قدامة، ٤٢٤/٩.

(٣) التاج والإكليل للمواق، ٢١٧/٣، الشرح الكبير للدردير، ١٠٥/٢، منح الجليل

لغليش، ٤٢٥/٢، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجَدِّ، ٢٧٧/٣.

(٤) المحلى لابن حزم، ١٧٢/٦.

(٥) المحلى لابن حزم، ١٧٢/٦.

(٦) المواق بهامش الخطاب ٣ / ٢١٧، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ /

٢٤١، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٤٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٠.

القول الثاني: للمالكية، وهو يرى التفصيل، فقالوا:

أ. إن المصيد الذي مات بسهم مسموم، ولم ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته، فإنه لا يحل أكله.

واستدلوا لذلك بأن المصيد، والحالة هذه هو من منفوذة المقاتل وهي حرام بالنص القرآني.

ب. وأما المصيد الذي مات بسهم مسموم وقد أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسري السم فيه، فإنه يحل تذكيته ولا يحرم أكله، إلا أنه يكره، خوفا من أذى السم.

واستدلوا: بأن علة الخوف من أن يعين على قتله السم، وبقيت علة الخوف من أكله، فإن كانت من السموم التي يؤمن على أكلها كالبقلة فقد ارتفعت العلتان، وجاز أكله.

ج. و أما إذا رمى المصيد بسهم مسموم ولم ينفذ مقاتله، وأدركت ذكاته، ففيه قولان: قال ابن رشد في سماع ابن القاسم: لا يؤكل، ونحوه حكى ابن حبيب، وقال سحنون: إنه يؤكل، واستظهره ابن رشد، لأنه قد ذكي وحياته فيه مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله^(١).

(١) التاج والإكليل بهامش الخطاب ٣ / ٢١٧.

الترجيح:

والراجح . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الجمهور ، لأن السم إذا قتل المصيد قبل تأثير السهم فيه فقد مات المصيد حينئذ بغير آلة الصيد المباحة في التذكية ، فيكون حراماً أكله لأنه ميتة ، ولما فيه من المضرة على من يأكله .

وأما إذا قتل السهم المصيد قبل وصول السم إليه ، فقد مات حينئذ بآلة الصيد المباحة وتحل تذكيته بها ، غير أنه يُشترط عدم إضرار السم بالآكل في هذه الحالة لكونه يؤدي إلى الموت حالاً أو مآلاً . والله أعلم .

الشرط الخامس: ألا تكون آلة الصيد مغصوبة.

اتفق الفقهاء على أنه يحرم الصيد بآلة مغصوبة.

واختلفوا هل يُباح أكل ما صيد بها أم لا ، على قولين:

القول الأول: إن ما تم صيده بآلة مغصوبة يحل أكله ، ولا حرمة فيه .

وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ^(١)

(١) تبيين الحقائق للزَيْلَعِي مع حاشية الشلبي ، ٢٦٦/٣ ، و ٢٢٧/٥ ، بدائع

الصنائع للكاساني ، ٦١/٥ . التاج والإكليل للمَوْاق ، ٢٨٢/٥ ، حاشية الدسوقي على

الشرح الكبير ، ٤٤٩/٣ ، المجموع للنَّوَوِي ١١٠/٩ ، الحاوي الكبير للماوردي ،

١٥١/٧ ، الإنصاف للمزداوي ، ٣١٠/١٠ ، كشاف القناع للبهوتي ، ٢١٦/٦ .

واستدلوا:

أ. بَأَنَّ الصَّيْدَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ لِمَعْنَى فِي عَيْنِهِ، بَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ مُجَاوِرٍ لَهُ، فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ صَيْرُورَتَهُ مَعْصِيَةً لِدَاثِهِ، وَانْتِفَاءَ مَشْرُوعِيَّتِهِ، كَالْوَطْءِ حَالَةَ الْحَيْضِ، وَالْبَيْعِ وَقْتُ النَّدَاءِ، وَالْأَصْطِيَادِ بِقَوْسٍ الْغَيْرِ^(١)

ب. أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمِ الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ يَزُولُ بِإِعْطَاءِ الْمَظْلُومِ حَقَّهُ^(٢)

القول الثاني: إن ما صيد بآلة مغصوبة لا يحل أكله وهو حرام.

وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وداود بن علي.^(٣)

واستدلوا بأن السارق والغاصب منهي عن ذكاة ما صيد بآلة مغصوبة وكذا وتناولها وتملكها، فإذا كان ذكاها فسدت التذكية.^(٤)

(١) بدائع الصنائع للكاساني ، ١٦١/٥، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري ، ٢٩٠/١.

(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ٢٨٦/٢٩.

(٣) البيان والتحصيل لابن رشد الجد ، ٢٨٧/٣، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ٢١٤/٢، الكافي لابن عبد البر، ١٨١/١، المجموع للنووي، ٨٤/٩

(٤) البيان والتحصيل لابن رشد الجد ، ٢٨٧/٣، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ٢١٤/٢

سبب الخلاف:

وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، هو اختلافهم في مدلول النهي، هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟

. فمن قال: يدل على فساد المنهي عنه، قال: ما صيد بآلة مغصوبة، فهو منهي عن غصب آلة الصيد والتزكية بها، وكذا تناولها وتملكها، فإذا كان ذكاهها فسدت التزكية.

. ومن قال: لا يدل النهي على فساد المنهي عنه إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل قال: التزكية بآلة صيد مغصوبة جائزة، لأنه ليس صحة ملك آلة التزكية شرطاً من شروط التزكية. (١)

الترجيح:

والراجح: والله أعلم، هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بصحة تزكية المصيد بأداة الصيد المغصوبة، لقوة مأخذه، وسلامة دليله، ولما تقرر عند الجمهور من أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه. والله أعلم.

(١) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، ٢/٢١٥

المبحث الثاني الاصطياد بالحيوان

اتفق الفقهاء من حيث الجملة على جواز الاصطياد بالحيوان المعلم وهو ما يسمى بالجوارح، من الكلاب والسباع والطيور مما له ناب أو مخلب، ويستوي في ذلك الكلب المعلم والفهد والنمر والأسد والبازي وسائر الجوارح المعلمة، كالشاهين والباشق والعقاب والصقر ونحوها.

فالقاعدة: أن كل ما يقبل التعليم وعلم يجوز الاصطياد به^(١)

ولا يشترط في الحيوان أن يكون مما يؤكل لحمه عند عامة الفقهاء.^(٢)

وقد استدلل الفقهاء على حل الاصطياد بالحيوان المعلم :

١. بعموم قوله تعالى (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه)^(٣)

(١) تبين الحقائق للزيلعي ٦ / ٥٠ - ٥١، وابن عابدين على الدر المختار ٥ /

٢٩٨، والقوانين الفقهية ص ١٨١، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير ٢ /

١٠٤، ١٠٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٢، ٢٢٥.

(٢) الزيلعي ٦ / ٥١، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٣، وانظر الشبراملسي بذيل نهاية

المحتاج ٨ / ١١٤.

(٣) سورة المائدة / ٤.

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن الله عز وجل أباح لنا ما تم اصطياؤه بالكلب، وغيره من الجوارح، وذلك أن لفظة (مكلبين) مشترك لفظي، يحتمل أن يكون المراد بها: الكلب، ويحتمل أن يكون المراد بها (التَّكْلِب) أي التعليم، فيكون المقصود بها جميع ما علمتم من الجوارح.^(١)

ب . (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تتاله أيديكم ورماحكم)^(٢)

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن الله عز وجل قد أباح لنا الصيد الذي تتاله اليد، والرماح وفي حكمه ما أتت به الجارحة من آلة الصيد.

ج . حديث عدي بن حاتم، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها - فكل مما أمسكن عليك. وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره»^(٣)

(١) بداية المجتهد لابن رشد، ٦/٣

(٢) المائدة: ٩٤

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، ٨٨/٧، الحديث: ٥٤٨٧.

وجه الاستدلال من الحديث الشريف: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح في حديث عدي بن حاتم أكل ما صيد بالكلب المعلم، سواء أدركت ذكاته أم لا، لأن العقر تزكية للحيوان، وفي حكمه سائر الحيوانات.

د. حديث أبي ثعلبة الخشني، وفيه من قوله - عليه الصلاة والسلام - : «ما أصبت بقوسك فسم الله، ثم كل. وما صدت بكلك الذي ليس بمعلم، وأدركت ذكاته - فكل»^(١)

وجه الاستدلال من الحديث الشريف: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الاصطياد بالكلب غير المعلم لكن بشرط تزكية ما صاده بالذبح. وفي حمة سائر الحيوانات.

وقد استثنى الفقهاء من ذلك الخنزير، فلا يحل الاصطياد به، لأنه لا يجوز الانتفاع به^(٢).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، ١٥٣٢/٣، الحديث: ١٩٣٠

(٢) تبين الحقائق للزيلعي، ٥١/٦، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٣، الشبراملسي بذيل

نهاية المحتاج ٨ / ١١٤

الاصطيات بالكلب الأسود:

تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء على جواز الاصطيات بالكلاب المعلمة ما عدا الكلب الأسود. (١)

واختلفوا في الكلب الأسود، والبهيم الأسود، وهو ما لا بياض فيه، أو كان أسود بين عينيه نكتتان على قولين:

القول الأول: يرى جواز الاصطيات به.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية والشافعية

واستدلوا بعموم قوله تعالى (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) (٢)

ووجه الاستدلال: أن الله أباح الاصطيات بعموم الجوارح والكلاب جميعا، الأسود منها، وغيره. (٣)

القول الثاني: يرى عدم جواز الاصطيات به.

وإليه ذهب الحنابلة وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وقتادة. (٤)

(١) بداية المجتهد، ٧/٣، كشف القناع ٦ / ٢٢٢.

(٢) سورة المائدة / ٤.

(٣) بداية المجتهد، ٧/٣.

(٤) بداية المجتهد، ٧/٣، كشف القناع ٦ / ٢٢٢.

واستدلوا بما ورد في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: عليكم بالأسود البهيم ذي الطفتين ^(١) فإنه شيطان ^(٢)

وجه الاستدلال: أنهم قالوا: يحرم صيده، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. ^(٣)

سبب الخلاف:

وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم، وذلك أن عموم قوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) ^(٤) يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك. «وأمره - عليه الصلاة والسلام - بقتل الكلب الأسود البهيم» - يقتضي في ذلك القياس ألا يجوز اصطيداه على رأي من رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

الترجيح: والراجح . والله أعلم . هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز الاصطياد بالكلاب جميعا.

وأما النهي الوارد في الحديث فلا دلالة فيه على تحريم الاصطياد، لأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وذلك لأن الأمر بقتل الكلب الأسود لا يدل على حرمة الاصطياد به لانفكاك الجهة. والله أعلم.

(١) الطفية: خوصة المقل (المصباح المنير) ، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٢.

(٢) أخرجه مسلم (٣ / ١٢٠٠) .

(٣) بداية المجتهد، ٧/٣، كشاف القناع ٦ / ٢٢٢.

(٤) سورة المائدة / ٤ .

شروط الاصطياد بالحيوان:

اشترط الفقهاء في الحيوان الذي يتم الاصطياد به عدة شروط.

الشرط الأول: أن يكون الحيوان مُعَلِّمًا. سواء أكان كلباً؛ أم غيره من جميع الحيوانات والطيور، فما قبل التعليم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

واستدلوا لذلك:

أ. بقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح) ^(١)

ووجه الاستدلال: أن العموم الوارد في الآية الكريمة يدل على حل الاصطياد بجميع الجوارح، سواء اكانت من الكلاب أم كانت من غيرها.

ب . بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة - رضي الله عنه - : ما صدت بكلكم المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلكم غير معلم فأدركت ذكاته فكل ^(٢)

ووجه الاستدلال من الحديث الشريف: أن العلة في إباحة الاصطياد بالكلب هي التعليم، لأن قوله تعالى (مكلبين) مشترك لفظي، يشمل الكلب، ويشمل سائر الجوارح، وذلك أن لفظة " مكلبين " مشتقة من كَلَّبَ

(١) المائدة/٤

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، ١٥٣٢/٣، الحديث: ١٩٣٠

الجراح لا من لفظ الكلب، ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية، فعلى هذا يكون سبب الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة "مكلبين".^(١)

القول الثاني: يرى عدم جواز الاصطيد بما سوى الكلب من الجوارح، لا باز، ولا صقر، ولا غير ذلك، إلا ما أدركت ذكاته. وإليه ذهب مجاهد^(٢)

سبب الخلاف:

وسبب اختلافهم في هذا الباب أمران:

أحدهما: قياس سائر الجوارح على الكلاب. وذلك لأن لفظ "التكليب" معناه التعليم، فيشمل كل جارحة معلمة. وقد يكون المقصود من لفظة "مكلبين" أن المقصود به الكلب.

فمن ذهب إلى أن لفظة "مكلبين" مقصود بها الكلب، قال لا يجوز الاصطيد بغير الكلب من الجوارح، وهو ما فهمه مجاهد ومن وافقه.

ومن ذهب إلى أن المقصود بلفظة "مكلبين" إنما هو التعليم أي "مُعَلِّمين" قال إن الاصطيد يجوز بكل جارحة معلمة، سواء أكانت كلبا أم غيره من الجوارح، وهو قول جمهور الفقهاء.

(١) بداية المجتهد، ٨/٣

(٢) بداية المجتهد، ٨/٣

والسبب الثاني: هل شرط "الإمساك" الوارد في الآية الكريمة: أن يمسك الحيوان المعلم الصيد، بمعنى أنه لا يأكل منه حتى يسلمه لصاحبه الذي أرسله أم أن ذلك ليس بشرط؟

وإذا قلنا إن الإمساك شرط في صحة الاصطياد بالحيوان المعلم، فهل ذلك يوجد في الكلب وحده أم يوجد في غير الكلب؟

. فمن ذهب إلى أن الإمساك أي عدم الأكل من الصيد شرط مختص بالكلب وحده، قال لا يجوز الاصطياد بغير الكلب، وأنه لا يُقاس على الكلب غيره من الجوارح المعلمة.

ومن ذهب إلى أن الإمساك أي . عدم الأكل من الصيد . ليس شرطاً مختصاً بالكلب، بل يتوافر في غيره من سائر الجوارح المعلمة، قال يصح الاصطياد بالكلب وغيره من جميع الجوارح المعلمة. ^(١)

شروط الجارحة المعلمة:

أولاً: شرط الطاعة والازدجار: اتفق الفقهاء: الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط في الكلب المعلم أنه إذا أرسل أطاع وإذا زُجر انزجر ^(٢)

(١) بداية المجتهد، ٣/٨.

(٢) بدائع الصنائع للكاساني، ٥٣/٥، شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، ٢٣٤/٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ١٠٣، ١٠٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٣.

ومعنى الطاعة: فهم الكلب لأوامر صاحبه، بحيث إذا دعاه أتى، وإذا أرسله ذهب، وإذا زجره أي أمره بالامتناع عن شيء امتنع.

واستدلوا لذلك بقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكليين) (١)

وجه الاستدلال: قال الجصاص: الآية أفادت ثلاثة معانٍ:

أحدها: جواز الاصطياد بكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير.

والثاني: أن يكون من شرط ذلك أن يكون معلماً بقوله: (وما علمتم من الجوارح مكليين) (٢) ، وبقوله: (تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) (٣)

والثالث: أن يكون قتل الصيد بجارحة تحصل فيه. (٤)

ولأنَّ اللهَ أباحَ ما أَمْسَكَ الكَلْبُ على صائِدِهِ، فإذا أَكَلَ منها فقد أَمْسَكَ على نَفْسِهِ (٥)

ب . عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن

(١) المائدة/٤

(٢) المائدة/٤

(٣) المائدة/٤

(٤) شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، ٢٣٥/٧

(٥) المغني لابن قدامة، ٣٨٠/٩

وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل»^(١)

وجه الاستدلال من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أباح للسائل أن يأكل من صيد كلبه المعلم. وهذا نص صريح في الإباحة. ج. ولأن الإجماع قائم على أن التعليم في الجوارح مباح للأكل، فكان على عمومته في كل إمساك عقر أو لم يعقر^(٢)

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، وابن عبد البر، وابن العربي، وابن رشد، وابن القطان، والقرطبي^(٣)

ثانياً شرط الإمساك "عدم الأكل من الصيد"

تحرير محل النزاع:

اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يشترط في الكلب المعلم: الطاعة والانزجار.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، ٨٧/٧، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. الحديث رقم : ٥٤٨٤

(٢) الحاوي الكبير للماوردي، ٥٢/١٥

(٣) مراتب الإجماع لابن حزم، ص: ١٤٦، الاستنكار لابن عبد البر، ٢٧٧/٥، أحكام القرآن لابن العربي، ٣٧/٢، ابن رشد، بداية المجتهد، ٨/٣، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، ٣١٥/١، تفسير القرطبي، ٦٦/٦.

واختلفوا في شرط الإمساك أي عدم أكل الجارحة من الصيد الذي صادته على قولين:

القول الأول: يرى أصحابه أنه يُشترط في الجارحة الإمساك على صاحبها، أي عدم الأكل من الصيد.

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة. وبه قال إسحاق، والثوري، وهو قول ابن عباس. (١)

واستدلوا: بما روى **عدي بن حاتم** رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل» (٢)

(١) مختصر القدوري، ص: ٢٠٥، العناية للبابرتي، ١٠/١١، الفتاوى الهندية، ٤٢٢/٥، المجموع للنووي، ٩/٩٤، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، ٩/٣٢٩. المبدع لابن مفلح، ٩/٢١١، ٢١٢، الإنصاف للمرداوي، ١٠/٣٢٣، ٣٢٤، كشاف القناع للبهوتي، ٦/٢٢٤. المغني، ٩/٣٠، مصنف ابن أبي شيبة، ٤/٢٣٤.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، ٧/٨٧، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. الحديث رقم: ٥٤٨٤

ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط في الجارحة المعلمة الإمساك، وإباحة الصيد، مستثناة من أصل التحريم، فوجب المصير إلى الوقوف على حدِّ ما استثناه الشارع الحكيم.

وأما المعقول: فقالوا إن أكل الكلب من الصيد، أو أكلت الجارحة، فليس هذا بمُعَلَّم؛ لأن شرط التعليم في الجارحة ألا تكل من الصيد، فلا يُباح الأكل من الصيد. (١)

القول الثاني: يرى أصحابه إن شرط الإمساك . أي عدم الأكل من الصيد . مقصور على الكلب فقط دون سائر الجوارح.

وإليه ذهب الإمام مالك وهو القول القديم للإمام الشافعي، وهو قول سعيد بن مالك، وابن عمر وسليمان. (٢)

واستدلوا بحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله - فكل. قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل» (٣)

(١) الخلافات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، لأبي بكر البيهقي، ٢٩٣/٧، الحديث رقم ٥٢٨٣ الحاوي الكبير، ٨/١٥، ونهاية المطلب، ١٨/١١٢، والمجموع، ٩/١١٨، بحر المذهب للرويانى، ١٠٩/٤.

(٢) بداية المجتهد لابن رشد، ٩/٣، والمجموع، ٩/١١٨، بحر المذهب للرويانى، ١٠٩/٤.

(٣) أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٦١٢) ومسلم (١٥٣٢ / ٣)

**ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الأكل من صيد
الحيوان المعلم حتى ولو أكل من الصيد، ولم يمسه على صاحبه. (١)**

**ووجه المالكية ومن وافقهم حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيحين
بأنه محمول على النذب، أي إذا أمسك الكلب الذي أرسلته علي الصيد،
فأكل من الصيد فلا تأكل منه، قالوا إن الأمر بعدم الأكل مما أمسك
الكلب على نفسه محمول على النذب لا على النهي المفيد لتحريم
الصيد. (٢)**

(١) بداية المجتهد لابن رشد ، ٩/٣.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه ، ٤/٧٣، قال الأرنبوط " حديث صحيح دون
قوله: "وإن أكل منه"، فلم يذكره في حديث أبي ثعلبة الخشني غير داود بن عمرو -
وهو الأودي الشامي- وهو وإن وثقه ابن معين، وقال أحمد: مقارب الحديث، ما
أرى بحديثه بأساً، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو داود: صالح، وقال ابن
عدي: ولا أرى بروايته بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي
مرة: شيخ، وقال: ليس بالمشهور، وقال أحمد بن عبد الله العجلي: يكتب حديثه،
وليس بالقوي ومثله يكون حسن الحديث - خالفه من هو أوثق منه، فلم يذكروا فيه:
"وإن أكل منه" فقد رواه ربعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني - واسمه
عائذ الله بن عبد الله -، عن أبي ثعلبة، فلم يذكره، وكذلك رواه أبو أسماء الربعي،
عن أبي ثعلبة، فلم يذكره، ويخالفه أيضاً حديث عدي بن حاتم السالف برقم
(٢٨٤٨) وهو في "الصحيحين"، وفيه النص على عدم الأكل مما أكل منه الكلب،
ولهذا قال الإمام أحمد فيما نقله ابن القيم في "تهذيب السنن": يختلفون في حديث
أبي ثعلبة عن هشيم"

سبب الخلاف.

ويرجع سبب الخلاف في اشتراط إمساك الجارحة عن الصيد وعدمه، إلى أمرين:

الأمر الأول: اختلاف حديث عدي بن حاتم المتقدم، وفيه «فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه»^(١).

والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله - فكل. قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل»^(٢).

١. فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على النذب، وحديث أبي ثعلبة على الجواز - قال: ليس من شرط الحيوان المعلم ألا يأكل، فيباح الصيد الذي أكل منه الحيوان الجارح، لأن الأكل لا يقدر في صفة التعليم.

٢. ومن رجع حديث عدي بن حاتم؛ إذ هو حديث متفق عليه، وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه، ولذلك لم يخرج به الشيخان البخاري ومسلم، وقال: من شرط الإمساك ألا يأكل بدليل الحديث المذكور - قال: إن أكل الحيوان المعلم من الصيد لم يؤكل ما صاده، وبه جمهور الفقهاء

(١) سبق تخريجه

(٢) سبق تخريجه.

الترجيح:

والذي نراه راجحاً ت والله أعلم . هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز الأكل مما أكله، الحيوان المعلم، لأن تذكيته حينئذ لا تصح، ولأن ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم، هو خلاف النص في الحديث، وخلاف ظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ^(١)

وهذا نص كلام ابن رشد رحمه الله في ترجيح رأي الجمهور ، ثم يقول: ولأن للإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به، وهو العادة، ^(٢) ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام - : «فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». ^(٣)

الشرط الثاني: أن يجرح الحيوان الصيد في أي موضع من بدنه.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على حل الأكل مما صاده الحيوان المعلم، متى توافرت فيه شروط التعلم الثلاثة السابقة، وهي: شرط الطاعة، وتتبع الحيوان الجارح للصيد، والازدجار. ^(٤)

(١) المائدة/٤

(٢) بداية المجتهد لابن رشد، ٩/٣

(٣) سبق تخريجه.

(٤) بداية المجتهد لابن رشد، ٩/٣

واختلفوا في اشتراط جرح الحيوان المُعلم للصيد في أي موضع من بدنه
أو عدم اشتراط ذلك على قولين:

القول الأول: يرى أن جرح الحيوان المُعلم للصيد في أي موضع من بدنه
شرط لحل تذكية صيده وإباحة الأكل منه.

وإليه ذهب المالكية والحنابلة، وهو ظاهر الرواية والمفتي به عند الحنفية،
ومقابل الأظهر عند الشافعية. (١)

وبناء عليه: لو قتل الحيوان الجارح الصيد بصدمة، أو عض بلا جرح ،
فلا يحل أكله لفساد التذكية ، كالمعارض إذا قتل بعرضه أو ثقله، وكذا لو
أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه، أو جثم على صدره
وخنقه (٢)

واستدلوا:

١. بقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) (٣)

(١) ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ٢٩٩، والقوانين الفقهية ص ١٨٢، ١٨٣،
والفواكه الدواني ١ / ٤٥٨، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥١، ومغني المحتاج ٤ /
٢٧٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٤٥.

(٢) ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ٢٩٩، والقوانين الفقهية ص ١٨٢، ١٨٣،
والفواكه الدواني ١ / ٤٥٨، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥١، ومغني المحتاج ٤ /
٢٧٦، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٤٥.

(٣) المائدة ٤/

ووجه الاستدلال: أن الشارع الحكيم أطلق لفظة "الجرح" على الحيوان المعلم، فكان الشرط أن يجرح الحيوان المعلم الصيد، في أي موضع من بدنه.

ولأن هذا الجرح هو المقصود من العقر إذ لا يمكن إنهار الدم الواجب في التذكية بدون. ^(١)

قال الزيلعي في هذا المعنى: "ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وهو يخرج بالجرح عادة، ولا يتخلف عنه إلا نادرا، فأقيم الجرح مقامه، كما في الزكاة الاختيارية والرمي بالسهم، ولأنه إذا لم يجرحه صار موقوذة، وهي محرمة بالنص" ^(٢)

القول الثاني: يرى أنه لا يشترط في الحيوان المعلم أن يجرح الصيد، فلو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها، أو مات بصدمتها، أو بعضها، أو بقوة إمساكها من غير عقر حلت تذكيته وجاز الأكل منه.

وإليه ذهب: الشافعية في الأظهر عندهم، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أبي حنيفة، وقول أشهب من المالكية: ^(٣)

(١) تبيين الحقائق شرح الكنز ٦ / ٥١، ٥٢.

(٢) تبيين الحقائق شرح الكنز ٦ / ٥١، ٥٢.

(٣) ابن عابدين ٥ / ٣٩٩ - ٤٠٢، والقوانين الفقهية ص ١٨٢، ومغني المحتاج

٤ / ٢٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٢٤.

واستدلوا:

١. بقوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) ^(١)

وجه الاستدلال أن الآية الكريمة عامة في إباحة الأكل من كل ما أمسك الحيوان المعلم على صاحبه، ولم تشترط جرح الحيوان المعلم، ولو كان شرطاً لنص عليه الشارع الحكيم. ^(٢)

ب . ولأنه يعسر تعليم الحيوان ألا يقتل إلا بجرح فكان ذلك مشقة تحمل على التيسير في الصيد بجواز الأكل مما صاده الحيوان المعلم، ولو لم يجرحه. ^(٣)

الترجيح:

والراجح . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الشافعية في مقابل الأظهر، ومن وافقهم من القول بعدم اشتراط جرح الحيوان المعلم للصيد، لقوة مأخذه، ولعموم النص القرآني في جواز الأكل مما أمسك الحيوان المعلم دون التعرض للجرح أو عدمه. والله أعلم.

(١) سورة المائدة / ٤ .

(٢) مغني المحتاج ٤ / ٢٧٦ .

(٣) المرجع والمكان السابقين

الشرط الثالث: ألا يشتغل الحيوان بعمل آخر بعد الإرسال.

الحكمة من هذا الشرط، هي عدم انشغال الحيوان الجارح بأمر آخر غير الصيد، لأنه إذا انشغل بأمر آخر، لم يكن الاصطياد منسوباً إلى الإرسال.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: إن هذا الشرط لازم في الحيوان المعلم.

وإليه ذهب الحنفية والمالكية.

وبناء عليه: قالوا: لو أكل خبزا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل، ولو عدل عن الصيد يمناً أو يسرة، أو تشاغل في غير طلب الصيد، وفتر عن سننه، ثم اتبعه فأخذه، لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف، أو أن يزجره صاحبه ويسمي فيما يحتمل الزجر فينزجر، بخلاف ما إذا كمن واستخفى، كما يكمن الفهد على وجه الحيلة، لا للاستراحة، فلا يحتاج إلى إرسال مستأنف^(١)

وأن من أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة، ثم رجع عن الطلب، ثم عاد فقتله، فإن كان كالمطالب له يمينا وشمالا، وهو على طلبه فهو على إرساله الأول، وإن وقف لأجل الجيفة أو شم كلبا أو سقط البازي عجزا عنه، ثم رأياه فاصطاده، فلا يؤكل إلا بإرسال مستأنف^(٢).

القول الثاني: لا يرى ضرورة هذا الشرط، وإليه ذهب الشافعية.

(١) ابن عابدين ٥ / ٣٩٩. القوانين الفقهية ص ١٨٢.

(٢) المواق بهامش الخطاب ٣ / ٢١٦.

وبناء عليه: قالوا: لو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره، ولو إلى جهة غير الإرسال فأصابه ومات حل، لأنه يعسر تكليفه ترك العدول^(١)

الترجيح:

والراجح . والله أعلم، هو ما ذهب إليه الشافعية، وذلك لأن استلزام هذا الشرط فيه مشقة، بحيث يتعذر وجوده في الحيوان الجارح، حتى ولو كان معلماً، ولأن الإنسان نفسه قد ينشغل عما تتوجه همته إليه، ببعض الشواغل، فكيف بالحيوان؟

ولأن هذا الشرط لو كان واجبا للزم النص عليه من الشارع الحكيم، أما وإنه لم ينص عليه فهو عفو منه ورحمة. والله أعلم.

(١) مغني المحتاج ٤ / ٢٧٧.

الفصل الثالث

الصائد

اشتراط الفقهاء لصحة الصيد من الصائد عدة شروط، وهي نفس شروط التذكية، فلا داعي لإعادة ذكرها إلا أن الفقهاء زادوا في شروط الصيد شرطاً واحداً، وهو عدم الإحرام في صيد البر، وبيان ذلك فيما يلي:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الصيد الذي يُحْظَرُ على المُحْرِمِ، هو الحيوان البري، لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) ^(١) أي في حال التلبس بالإحرام .

وقوله تعالى (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) ^(٢) أي لا يحل لكم الصيد وأنتم على حال الإحرام.

كما اتفقوا على أن المحرم إذا صاد صيداً، فلا يحل له الأكل منه.

واختلفوا: هل يحل لغير المحرم الأكل من هذا الصيد الذي صاده أم لا؟ على قولين:

القول الأول: إنه يحرم على المحرم الأكل من هذا الصيد، ولا يحل لغيره أيضاً الأكل منه. وإليه ذهب المالكية.

(١) المائدة/٩٦.

(٢) المائدة/١.

واستدلوا بقوله تعالى (وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) (١)

وجه الاستدلال من الآية الكريمة: أن تحريم الاصطياد، يدل على تحريم الأكل، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه.

القول الثاني: إنه يجوز لغير المحرم الأكل مما صاده المسلم التلبس بالإحرام. وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الشافعية، والحنابلة وأبو ثور.

واستدلوا بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) (٢)

وجه الاستدلال: لما أحل الله تعالى أكل بهيمة الأنعام الوحشية إلا الصيد في حال الإحرام - دلّ على أن المحظور على المحرم هو الصيد، وأما الأكل فلا يشمل التحريم. لأن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه.

سبب الخلاف: قال ابن رشد في بيان سبب الخلاف: "وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور، وهو هل النهي يعود بفساد المنهي؟ أم لا؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب." (٣)

ومقصود ابن رشد رحمه الله: هو إن العلماء قد اختلفوا في دلالة النهي، هل تفيد فساد المنهي عنه، فيكون النهي شاملاً للصيد والأكل من المصيد؟

(١) المائدة/٩٦.

(٢) المائدة/١.

(٣) بداية المجتهد، ١٣/٣.

ام أن دلالة النهي لا تفيد فساد المنهي عنه، فيكون المنهي عنه هو الصيد فقط، وأما المصيد، فيحل الأكل منه.

فالجمهور ذهبوا إلى النهي عن الاصطياد لا يدل على حرمة الأكل من المصيد، استناداً على أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه.

والمالكية ذهبوا إلى أن النهي عن الاصطياد يدل على حرمة الأكل لشموله لهما معاً؛ أعنى: الاصطياد والأكل.

الترجيح:

والراجح . والله أعلم . هو ما ذهب إليه الجمهور من القول بعدم تحريم الأكل مما صاده المحرم، لقوة مأخذه والله أعلم

الخاتمة:

وفي ختام هذا البحث، أرجو أن أكون قد أوضحت لطالب العلم الشرعي، ما يتعلق بمفهوم التذكية، والذبح، وحكمه الشرعي وحكمة مشروعيته، وما يتعلق بالتذكية في حالي الاختيار والاضطرار، وشروطها، وشروط المذكي، وما يتعلق بالصيد من أحكام. كل هذا بأسلوب ميسر، وعبرة سهلة واضحة.

والله تعالى موفق، والهادي إلى سواء السبيل.

ا.د. مراد محمود حيدر

أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في القاهرة.

جسر السويس في: الرابع من ربيع الأول سنة ١٤٤٦ هـ.

المحتويات

أولاً: الشهادة والقضاء والتحكيم	٢
المبحث الأول	٧
التعريف بالشهادة وبيان بعض أحكامها الفقهية المقارنة	٧
المسألة الأولى	٧
التعريف بالشهادة وسببها ومشروعيتها وطبيعتها	٧
المسألة الثانية	١١
حكم الشهادة التكليفي تحملاً وأداءً	١١
المسألة الثالثة	١٨
شروط تحمل الشهادة	١٨
المسألة الرابعة	٢٠
شروط أداء الشهادة	٢٠
المسألة الخامسة	٣٩
حكم أخذ الأجرة على الشهادة	٣٩
المبحث الثاني	٤٢
التعريف بالقضاء وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة	٤٢
المسألة الأولى	٤٢
تعريف القضاء وبيان مشروعيته	٤٢
المسألة الثانية	٥٠
أحكام القضاء التكليفية	٥٠
المسألة الثالثة	٦١
أحكام القضاء العامة	٦١
المسألة الرابعة	٧٤
شروط الصلاحية لتولي القضاء	٧٤
المسألة الخامسة	٨٩

٨٩	تأثير الأحكام القضائية الحقوقية على الأحكام الدينية
٩٧	المبحث الثالث
٩٧	التعريف بالتحكيم وبيان بعض أحكامه الفقهية المقارنة
٩٧	المسألة الأولى
٩٧	تعريف التحكيم وبيان أنواعه وأهميته وحكمه الفقهي
١٠٢	المسألة الثانية
١٠٢	الفرق بين التَّحْكِيم وبين القضاء
١٠٧	المسألة الثالثة
١٠٧	صور التَّحْكِيم
١١٥	المسألة الرابعة
١١٥	لزوم التَّحْكِيم ونقضه
١١٩	ثانياً: كتاب الصيد والذباح
١٢٢	باب الذباح
١٢٣	تمهيد
١٢٤	في تعريف الذباح، والألفاظ ذات الصلة، وحكم الذبح، وحكمة مشروعيته ...
١٢٩	الفصل الأول
١٢٩	في بيان محل الذبح
١٣٠	المبحث الأول:
١٣٠	ما يُشترط فيه الذبح من الحيوان:
١٣١	المطلب الأول
١٣١	هل تعمل ذكاة الأم في جنينها؟
١٣٦	المطلب الثاني
١٣٦	هل الجراد تشترط له الذكاة؟
١٤٠	المطلب الثالث

الميتة المستثناة من التحريم.....	١٤٠
المبحث الثاني.....	١٤١
تأثير الذكاة في المحرمات متى أدركت حيّة.....	١٤١
المبحث الثالث.....	١٥١
تأثير الذكاة في الحيوانات التي يحرم أكلها.....	١٥١
باب الصيد.....	٢٥٢
الفصل الأول.....	٢٥٣
حقيقة الصيد وحكمه ومحلّه.....	٢٥٣
المبحث الأول.....	٢٥٣
حقيقة الصيد.....	٢٥٣
المبحث الثاني.....	٢٥٥
حكم الصيد.....	٢٥٥
المبحث الثالث.....	٢٥٨
محل الصيد.....	٢٥٨
الفصل الثاني.....	٢٧١
آلة الصيد.....	٢٧١
المبحث الأول.....	٢٧١
آلة الصيد الجامدة.....	٢٧١
المبحث الثاني.....	٢٨٤
الاصطياد بالحيوان.....	٢٨٤
الفصل الثالث.....	٣٠٥
الصائد.....	٣٠٥